

Wytyczne PPP

Tom I: Przygotowanie Projektów PPP

Tom II: Postępowanie PPP

Tom III: Umowa o PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

III

Publikacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2024 r., wersja 3.0

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Opracowanie: grudzień 2024 r.

Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) oświadcza, że treść opracowania ma charakter informacyjny i pełni funkcję rekomendacji opartych o krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

MFIPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejsze Wytyczne. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Opracowanie nie powinno być wprost stosowane, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia.

MFIPR upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFIPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Spis treści

Słownik Pojęć	6
Wprowadzenie	13
Część I Umowa o PPP - zagadnienia ogólne	16
1. Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP	17
2. Charakterystyka Umowy o PPP	21
2.1 Warunki konieczne Umowy o PPP	21
2.2 Istotne warunki Umowy o PPP	24
2.3 Strategia negocjacyjna	27
2.4 Okres Obowiązywania Umowy o PPP	28
2.5 Harmonogram.....	29
2.6 Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP	30
2.7 Umowa o PPP a PPP Instytucjonalne.....	33
2.8 Objasnienia podatkowe Ministra Finansów	34
2.9 Wpływ zobowiązań z Umowy o PPP na państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych.....	36
Część II Umowa o PPP - część szczegółowa.....	38
1. Postanowienia Ogólne	39
1.1 Preambuła i komparycja	39
1.2 Definicje i Interpretacja	41
1.3 Przedmiot Umowy. Ogólne zobowiązania stron	45
1.4 Okres Obowiązywania Umowy	47
1.5 Oświadczenia stron	49
1.6 Wkład Własny.....	52
1.7 Udostępnienie Nieruchomości	53
1.8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o PPP	54
1.9 Finansowanie Przedsięwzięcia	57
1.10 Umowa Bezpośrednia.....	61
1.11 Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP	63
1.12 Podwykonawcy.....	67
1.13 Niezależny Inżynier.....	70
1.14 Zmiany własnościowe Partnera Prywatnego (Spółki Projektowej).....	74
2. Okres Projektowania i Okres Budowy	75
2.1 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania	75

2.2 Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania.....	77
2.3 Procedura monitorowania i kontroli Prac Projektowych.....	77
2.4 Teren Robót.....	79
2.5 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót	80
2.6 Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Robót	82
2.7 Procedura monitorowania i kontroli Robót	83
3. Okres Utrzymania	87
3.1 Informacje ogólne	87
3.2 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania.....	88
3.3 Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania	98
4. Wynagrodzenie	100
4.1 Mechanizm Wynagradzania.....	100
4.2 Model Finansowy	107
5. Przypadki zewnętrzne	108
5.1 Istota i cel przypadków zewnętrznych	108
5.2 Przypadek kompensacyjny i przypadek dostosowania.....	110
5.3 Siła wyższa.....	117
5.4 Zmiana prawa.....	119
5.5 Polecenie zmiany	121
6. Procedura rozwiązywania sporów	123
6.1 Ogólne informacje	123
6.2 Konsultacje	124
6.3 Etap ekspercki	125
6.4 Postępowanie sądowe.....	125
7. Zmiany Umowy o PPP	127
7.1 Umowne przesłanki zmiany. Procedura zmiany Umowy	127
7.2 Ustawowe przesłanki zmiany Umowy o PPP	129
8. Ubezpieczenia	131
8.1 Ubezpieczenia	131
9. Zakończenie Umowy o PPP	135
9.1 Wypowiedzenie Umowy o PPP.....	135
9.2 Rozliczenie stron na wypadek wcześniejszego zakończenia Umowy o PPP.....	138
9.3 Zwrot Infrastruktury Publicznej.....	142
10. Prawa własności intelektualnej.....	144

10.1 Prawa autorskie, licencje	144
11. Postanowienia końcowe.....	147
11.1 Ochrona danych osobowych.....	147
11.2 Poufność	150
11.3 Zawiadomienia	150
11.4 Język i prawo właściwe.....	150
11.5 Forma i egzemplarze	150
12. Załączniki do Umowy o PPP	152

Słownik Pojęć

Pojęcie	Wyjaśnienie
Bankowalność	oznacza zdolność do pozyskania finansowania zewnętrznego dla Projektu PPP
Budowa	oznacza wybudowanie Infrastruktury Publicznej na Nieruchomości przekazanej Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny w zakresie opisanym w PFU i zgodnie z Dokumentacją Projektową
Decyzja Administracyjna	oznacza decyzję, pozwolenie administracyjne, uzgodnienie, zgodę, opinię lub inny akt wydawany przez organy administracji, którego uzyskanie jest niezbędne dla realizacji Projektu PPP
Dialog Konkurencyjny	oznacza dialog konkurencyjny w rozumieniu Ustawy PZP
Dokumentacja Projektowa	oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu Robót Budowlanych (w szczególności koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy)
Doradca / Zespół Doradców	oznacza doradców zewnętrznych, w tym m.in. doradców finansowych, prawnych i technicznych zaangażowanych przez Podmiot Publiczny
Dostępność	oznacza zapewnioną Użytkownikom na zasadach określonych w Umowie o PPP możliwość korzystania z Infrastruktury Publicznej
Duży Projekt	oznacza Projekt PPP o szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych równej lub wyższej niż 50 mln zł brutto
EPEC	oznacza Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (ang. <i>European PPP Expertise Centre</i>), którego członkami są Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie - udziałowcy Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Finansowanie	oznacza łącznie wszystkie formy finansowania Przedsięwzięcia
Generalny Wykonawca	oznacza podmiot, z którym Partner Prywatny zawiera umowę o Budowę Infrastruktury Publicznej albo zaprojektowanie i Budowę Infrastruktury Publicznej
Infrastruktura Publiczna	oznacza jakikolwiek składnik majątkowy Podmiotu Publicznego, który wykorzystywany będzie na potrzeby realizacji Projektu PPP
Instytucje Finansujące	oznacza każdy bank lub instytucję kredytową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, będącą stroną umowy kredytowej związanej z realizacją Umowy o PPP

Pojęcie	Wyjaśnienie
JST	oznacza jednostkę samorządu terytorialnego
Kluczowe Wskaźniki Efektywności / KPI (ang. Key Performance Indicators)	oznaczają mierniki należytego wykonania Umowy o PPP przez Partnera Prywatnego w zakresie ilości lub jakości Robót, Utrzymania i Zarządzania
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Mały Projekt	oznacza Projekt PPP o szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych niższej niż 50 mln zł brutto
Mechanizm Wynagradzania	oznacza sposób wynagrodzenia Partnera Prywatnego określony w Umowie o PPP, w tym m.in. Opłata za Dostępność, myto ukryte lub Opłaty od Użytkowników
Metoda Tradycyjna / Formuła Tradycyjna	oznacza sposób realizacji projektu przez Podmiot Publiczny na skutek udzielenia zamówienia publicznego lub kilku zamówień publicznych bez zastosowania modelu PPP
Model Finansowy	oznacza model finansowy przygotowany przez Partnera Prywatnego, stanowiący Załącznik do Umowy o PPP
Nieruchomość	oznacza działki gruntu, które powinny zostać szczegółowo opisane w Umowie o PPP, prawo do korzystania z których stanowić może wkład własny Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięcie
Niezależny Inżynier	oznacza podmiot – najczęściej instytucjonalny – działający na rzecz Projektu PPP, wyznaczony przez strony Umowy o PPP do wykonywania usług, określonych w Umowie o PPP oraz umowie z Niezależnym Inżynierem zawartej zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP, szczególnie dotyczącej Dużego Projektu
Ocena Efektywności	oznacza analizy dotyczące Projektu PPP wykonywane przez Podmiot Publiczny przed wszczęciem Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, mające na celu ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o PPP
Oferta	oznacza ofertę złożoną przez Partnera Prywatnego w Postępowaniu
Okres Budowy	oznacza czas na realizację Budowy, zdefiniowany w Umowie o PPP
Okres Obowiązywania Umowy	oznacza określony w Umowie okres od zawarcia Umowy i kończący się w dacie Zakończenia Umowy

Pojęcie	Wyjaśnienie
Okres Projektowania	oznacza okres liczony od zawarcia Umowy do zakończenia Prac Projektowych
Okres Utrzymania	oznacza okres liczony od zakończenia Budowy do Zakończenia Umowy
Operator	oznacza podmiot realizujący usługi Utrzymania lub Zarządzania
Opinia PPP	oznacza opinię dotyczącą zasadności realizacji Przedsięwzięcia wydawaną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie Ustawy o PPP
Opłata za Dostępność / OzD	oznacza wynagrodzenie Partnera Prywatnego płatne przez Podmiot Publiczny, uzależnione od Dostępności aktywa i jakości świadczonych usług, a nie rzeczywistego wykorzystania składnika Infrastruktury Publicznej
Opłaty od Użytkowników / OoU	oznacza sposób wynagradzania Partnera Prywatnego, w którym otrzymuje on prawo do pobierania opłat od Użytkowników za korzystanie z Infrastruktury Publicznej
Partner Prywatny	oznacza partnera prywatnego w rozumieniu Ustawy o PPP, z którym została zawarta Umowa o PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne / PPP	oznacza partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu Ustawy o PPP
Podmiot Publiczny	oznacza podmiot publiczny w rozumieniu Ustawy o PPP, który zawarł Umowę o PPP z Partnerem Prywatnym
Podwykonawca	oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, z którą Partner Prywatny zawrze umowę na wykonywanie określonego zakresu Umowy, w tym Generalny Wykonawca lub Operator
Postępowanie PPP / Postępowanie	oznacza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zostaje zawarta Umowa o PPP
PPP Instytucjonalne	oznacza Przedsięwzięcie realizowane w formie Spółki PPP
PPP Kontraktowe	oznacza Przedsięwzięcie realizowane przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy o PPP (bez Spółki PPP)
Prace Projektowe / Projektowanie	oznaczają prace obejmujące wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, innej dokumentacji technicznej w celu zrealizowania Budowy zgodnie z Umową PPP

Pojęcie	Wyjaśnienie
Progi Unijne	oznaczają wartości zamówień wskazane w art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
Program Funkcjonalno-Użytkowy / PFU	oznacza program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu Ustawy PZP oraz odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Projekt Hybrydowy	oznacza Projekt PPP z wykorzystaniem finansowania ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
Projekt PPP / Przedsięwzięcie	oznacza przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy o PPP
Punkty Karne	oznaczają określone w Umowie o PPP punkty karne za określony brak Dostępności lub niewykonanie, lub nienależyte wykonanie obowiązków
Roboty / Roboty Budowlane	oznaczają roboty budowlane prowadzone w celu zrealizowania Budowy
RODO	oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Rozporządzenie w sprawie Ryzyka	oznacza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie
Spółka PPP	oznacza spółkę Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, o której mowa w Ustawie o PPP
Spółka Projektowa	oznacza spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną w celu realizacji konkretnego Projektu PPP

Pojęcie	Wyjaśnienie
Standardy Utrzymania	oznaczają standardy Utrzymania Infrastruktury Publicznej, określone w Umowie o PPP
SWZ	oznacza specyfikację warunków zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy PZP
Teren Budowy	oznacza teren, w tym Nieruchomość i wszelkie inne tereny, na których wykonywane będą Roboty Budowlane określone w Umowie o PPP
Umowa Bezpośrednia	oznacza umowę pomiędzy stronami Umowy o PPP a Instytucjami Finansującymi (lub z wyznaczonym przez Instytucje Finansujące agentem działającym na ich rzecz), na podstawie, której uzgadnia się zasady współpracy z Instytucjami Finansującymi w trakcie realizacji Projektu PPP, w szczególności w przypadku wypowiedzenia Umowy o PPP w wyniku naruszenia jej postanowień przez Partnera Prywatnego
Umowa o PPP / Umowa	oznacza umowę dotyczącą Projektu PPP, zawieraną pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym
Usługa Finansowa	oznacza usługę polegającą na rozłożeniu w czasie płatności wynagrodzenia za Roboty Budowlane ze spłatą odroczoną na Okres Utrzymania
Ustawa o Finansach Publicznych	oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o PPP	oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa o Samorządzie Gminnym	oznacza ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa o Umowie Koncesji	oznacza ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa o VAT	oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa Prawo Budowlane	oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa PZP	oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Utrzymanie	oznacza wszelkie działania i czynności Partnera Prywatnego w celu wypełnienia Standardów Utrzymania Infrastruktury Publicznej oraz zapewnienia Dostępności Infrastruktury Publicznej

Pojęcie	Wyjaśnienie
Użytkownik	oznacza podmiot korzystający z Infrastruktury Publicznej (użytkownika końcowego)
Value for Money	oznacza efektywność realizacji projektu w modelu PPP w porównaniu do Metody Tradycyjnej
Value for People	oznacza zgodność projektu w modelu PPP z 17 celami zrównoważonego rozwoju zawartymi w dokumencie "Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju" (ang. <i>Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development</i>) przyjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Wynagrodzenie	oznacza ogół płatności należnych Partnerowi Prywatnemu z tytułu realizacji Przedsięwzięcia, określonych szczegółowo w Umowie o PPP
Wytyczne Tom I	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przygotowania Projektów PPP
Wytyczne Tom II	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przeprowadzenia Postępowania PPP
Wytyczne Tom III	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Umowy o PPP
Wytyczne Tom IV	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Zarządzania Umową o PPP
Zakończenie Umowy	oznacza zakończenie Umowy o PPP niezależnie od jego podstawy
Zamawiający	oznacza zamawiającego w rozumieniu Ustawy PZP
Zamknięcie Finansowe	oznacza zawarcie umów dotyczących uzyskania przez Partnera Prywatnego Finansowania, w łącznej kwocie wystarczającej do należytej realizacji Projektu PPP
Zamknięcie Komercyjne	oznacza zawarcie pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym Umowy o PPP
Zarządzanie	oznacza wszelkie działania i czynności Partnera Prywatnego w celu należytego zarządzania Infrastrukturą Publiczną oraz usługami, które powinny zostać sprecyzowane w Umowie o PPP
Zarządzanie Umową o PPP	oznacza ogół działań i czynności Podmiotu Publicznego w zakresie zarządzania procesami związanymi z wykonywaniem Umowy o PPP, w tym monitoring i kontrolę należytej jakości robót i usług, w tym zarządzanie zmianami, ryzykiem, roszczeniami i płatnościami oraz Zakończeniem Umowy

Pojęcie	Wyjaśnienie
Zespół Projektowy PPP / Zespół Projektowy / Zespół	oznacza zespół Podmiotu Publicznego powołany do przygotowania, realizacji i monitorowania Projektu PPP

Wprowadzenie

Wytyczne Tom III stanowią omówienie typowej Umowy o PPP w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowanych w oparciu o Opłatę za Dostępność i nie dotyczą Umów o PPP w trybie postępowania koncesyjnego ani w modelu PPP Instytucjonalnego.

Wytyczne Tom III zostały podzielone na dwie Części. Część I dotyczy zagadnień ogólnych odnoszących się do Umowy o PPP. Systematyka Części II odpowiada poszczególnym zagadnieniom oraz ich kolejności, które znajdują odzwierciedlenie w standardowej Umowie o PPP.

Tam, gdzie jest to konieczne, w celu ułatwienia rozumienia Wytycznych Tom III w kontekście praktyk międzynarodowych, posłużono się w nawiasach terminologią w języku angielskim odpowiadającą zastosowanej terminologii w języku polskim.

Wytyczne Tom III zawierają treść podstawową oraz ramki wyróżnione w tekście, wskazujące na treści szczególnie istotne. Ramki są oznaczone w następujący sposób:

Tytuł ramki	Ikona	Znaczenie
Definicja		wskazanie treści wybranych definicji z Umowy o PPP
Dobre praktyki		wskazanie najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia międzynarodowe i krajowe
Małe Projekty		wskazanie różnicy w podejściu do realizacji Projektów o wartości poniżej 50 mln PLN
Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I-IV		wskazanie Części i Punktów w Wytycznych Tom I, Wytycznych Tom II i Wytycznych Tom IV, w których szczegółowo wyjaśnione są zagadnienia poruszane w Wytycznych Tom III
Przykładowe Postanowienia		wskazanie przykładowych postanowień Umów o PPP
Przykłady		wskazanie praktycznych przykładów
Rozwiązanie Alternatywne		wskazanie alternatywnego rozwiązania w stosunku do przedstawionego w Wytycznych Tom III
Uwaga		wskazanie kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę

Źródła Informacji



wskazanie dodatkowych źródeł informacji
rozszerzających treści zawarte w Wytycznych
Tom III

Korzystanie z Wytycznych Tom III

Odbiorcy Wytycznych Tom III powinni mieć na względzie, że proponowane rozwiązania będą podlegały weryfikacji i dostosowaniu w kontekście konkretnego Projektu PPP i jego uwarunkowań, a przede wszystkim w kontekście podziału zadań i ryzyk właściwego dla danego Projektu PPP oraz jego wielkości. Z tej przyczyny należy podkreślić, że przy stosowaniu Wytycznych Tom III konieczne jest uwzględnienie również specyfiki danego sektora, oczekiwań Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących.

Wytyczne Tom III nie zawierają wyczerpującego katalogu rozwiązań możliwych do przyjęcia w Umowach o PPP, a służą raczej zobrazowaniu typowych regulacji w nich zawartych. Wytyczne Tom III wskazują na ogólne zasady i cele poszczególnych elementów Umowy, jednocześnie nie przesądzając konkretnych rozwiązań i konstrukcji prawnych, które powinny zostać wykorzystane w Umowie o PPP. Niemniej, w oparciu o dotychczasową praktykę rynkową, także na rynku międzynarodowym, w Wytycznych Tom III zawarto przykłady wybranych postanowień oraz definicji stosowanych zwykle w Umowach o PPP. Mogą być one pomocne w przygotowaniu przez Podmiot Publiczny Umowy o PPP dla konkretnego Przedsięwzięcia. Niekiedy wskazano również rozwiązanie alternatywne w stosunku do rozwiązań podstawowych, które są czasami stosowane w Umowach o PPP.

Formułując postanowienia Umowy o PPP, należy pamiętać, że powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami kontraktu są tak istotne, że muszą być analizowane zawsze z uwzględnieniem innych postanowień Umowy. Dotyczy to w szczególności zagadnień wpływających na rozkład ryzyk w Projekcie PPP.

Wskazanie powiązanych Części i Punktów w Tomach I, II i IV, w których znajdują się odniesienia do zagadnień poruszanych w Tomie III, ma miejsce tylko wówczas, gdy zagadnienia te są wyjaśnione całościowo w pozostałych Tomach i mają istotne znaczenie dla zrozumienia treści zawartej w Tomie III.

Niniejsze Wytyczne Tom III stanowią zaktualizowaną, trzecią wersję Wytycznych z 2018 r. Obecna wersja odzwierciedla aktualną sytuację na rynku PPP w Polsce, w tym wprowadzone zmiany w przepisach prawa z otoczenia PPP oraz bazuje na dotychczasowych doświadczeniach rynku polskiego i zagranicznego w zakresie modelowych rozwiązań stosowanych w Umowach o PPP.

Podstawowe założenia do Wytycznych Tom III

Dla zobrazowania konkretnych rozwiązań, Wytyczne Tom III zakładają następujące, ogólne warunki realizacji Projektu PPP:

- 1) przygotowanie Projektu PPP w sposób zgodny z Wytycznymi Tom I;
- 2) realizacja Przedsięwzięcia w formule finansowania projektowego (ang. *project finance*), z udziałem Spółki Projektowej;
- 3) wybór Partnera Prywatnego w Postępowaniu prowadzonym w trybie Dialogu Konkurencyjnego na podstawie przepisów Ustawy PZP, zgodnie z Wytycznymi Tom II;

- 4) Mechanizm Wynagradzania oparty o Opłatę za Dostępność (z wyjątkiem Części I oraz wybranych przykładów, które zawierają odniesienia do Projektów opartych o inne Mechanizmy Wynagradzania);
- 5) większość ryzyka projektowania, Budowy i Dostępności znajduje się po stronie Partnera Prywatnego, a ryzyko popytu ponosi Podmiot Publiczny;
- 6) brak Opłat od Użytkowników;
- 7) Oferty nie zawierają elementów odnoszących się do jakościowych kryteriów oceny Ofert podlegających subiektywnej ocenie Podmiotu Publicznego (np. koncepcja projektowa).

Przygotowanie Umowy o PPP dotyczącej projektu realizowanego w oparciu o inne założenia, wymagać będzie odpowiednich modyfikacji. Stanowiska sformułowane w Wytocznych Tom III mogą bowiem okazać się nieadekwatne do rozwiązań, które znajdą zastosowanie w Projekcie realizowanym w oparciu o inne założenia.

Część I

Umowa o PPP - zagadnienia ogólne

1. Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 5 - Kluczowe czynniki sukcesu Projektu PPP na Etapie Przygotowawczym
Tom I: Część II Punkt 2.1 – Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego
Tom I: Część II Punkt 3 – Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP
Tom II: Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Postępowania PPP
Tom II: Punkt 3.1.3 – Komisja Przetargowa
Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności
Tom IV: Część I Punkt 2 – Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP

Umowa o PPP stanowi podstawowe narzędzie zarządzania relacjami pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym. Jest źródłem praw i obowiązków stron. Dlatego też to od jakości Umowy o PPP zależy w głównej mierze powodzenie Projektu i efektywne nim zarządzanie. Jest wiele czynników, które mają wpływ na rezultat w postaci czytelnej, kompleksowej i skutecznej Umowy PPP. Wytyczne Tom III wskazują najważniejsze z nich.



Korzystanie z wytycznych

Z uwagi na bardzo bogate doświadczenia PPP na rynkach rozwiniętych Projekty PPP doczekały się wielu wytycznych, zarówno rządowych, jak też pochodzących z innych instytucji jak EPEC, banki rozwoju (EBOiR, Bank Światowy), czy organizacje branżowe. W związku z tym zostały wypracowane pewne standardy międzynarodowe, które są coraz częściej uwzględniane w Projektach PPP w Polsce, między innymi w oparciu o dotychczas publikowane Wytyczne PPP Tom I – IV. Prawidłowej implementacji wytycznych do Umowy o PPP pomaga wsparcie Doradców, którzy jednocześnie powinni uwzględnić w projekcie Umowy specyfikę danego Projektu.



Spójna i czytelna treść postanowień

Umowa o PPP stanowi narzędzie służące stronom przez cały Okres Obowiązywania Umowy. Powinien być to w związku z tym dokument przygotowany bardzo starannie, spójny, czytelny, powodujący jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczy to nie tylko wewnętrznej spójności samej treści Umowy o PPP, lecz również spójności z jej załącznikami (np. co do definicji i określenia zobowiązań stron). Zaleca się, aby te same zagadnienia nie były powielane w odrębnych dokumentach Umowy o PPP.

PRZYKŁAD



Umowa o PPP przewiduje w części głównej procedurę monitorowania i zgłaszania uwag przez Podmiot Publiczny do Dokumentacji Projektowej zgodnie z Wytycznymi PPP. PFU przygotowane przez doradcę technicznego Podmiotu Publicznego zawiera całkowicie inne procedury odbiorowe, bez uwzględnienia specyfiki Projektów PPP. Niespójność może zostać usunięta na gruncie uwag Partnerów Prywatnych na etapie Dialogu Konkurencyjnego.



Uwzględnienie regulacji niezbędnych z punktu widzenia Bankowości

Sukcesem Umowy o PPP jest to, że zawiera wszystkie postanowienia, istotne z punktu widzenia Bankowości Projektu PPP. Tylko taka Umowa pozwoli bowiem na pozyskanie Finansowania.



Uwzględnienie aktualnych warunków rynkowych i komercyjnych

Warunki komercyjne Umów o PPP to na przykład terminy, okresy, wysokości kar umownych, limity odpowiedzialności, limity kar umownych, okresy naprawcze, wskaźniki waloryzacji Wynagrodzenia, brzmienie niektórych definicji np. siły wyższej, katalog przypadków kompensacyjnych.

Każdorazowo powinno być analizowane, jakie standardy są najbardziej powszechne na rynku w momencie prowadzenia Postępowania PPP. W tym celu Podmiot Publiczny często korzysta ze wsparcia Doradców, którzy powinni posiadać wiedzę na temat aktualnych uwarunkowań rynkowych w podobnych projektach.



Właściwie opisany podział ryzyka

Umowy o PPP powinny w sposób wyczerpujący określać podział ryzyka i skutki wynikające z przyjęcia danego ryzyka przez stronę Umowy o PPP. Dla właściwego opisanego ryzyka nie powinno stosować się w Umowie o PPP matrycy ryzyka. Na poziomie kontraktowym przyjęcie ryzyka oznacza bowiem określone zobowiązanie i odpowiedzialność za jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Podobnie w przypadku ryzyka dzielonego, nie wystarczy wskazać, że jest ono dzielone między stronami. Należy wskazać co to oznacza z punktu widzenia odpowiedzialności stron. Często w matrycy ryzyka wskazuje się na przykład, że ryzyko Siły Wyższej dzielone jest pomiędzy Partnera Prywatnego i Podmiot Publiczny w proporcji 50/50. Umowa o PPP powinna w takim przypadku określać, w jakim zakresie strony ponoszą skutki siły wyższej, a w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy - regulować kwestię rozliczenia za wykonane Prace Projektowe i Roboty.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Niewykonanie Umowy przez Strony spowodowane Siłą Wyższą będzie usprawiedliwione i takie niewykonanie nie będzie stanowić niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w zakresie, w jakim Partner Prywatny nie będzie w stanie wykonywać któregoś ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu wystąpienia lub skutków Siły Wyższej, Partner Prywatny będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania do czasu ustania trwania tego przypadku Siły Wyższej i jego skutków. Podmiot Publiczny nie będzie uprawniony do naliczenia Punktów Karnych, z powodu niewykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej.



Uwzględnienie wniosków z Oceny Efektywności

Umowa o PPP jest opracowywana po etapie przygotowawczym Projektu PPP i tym samym znane są wnioski oraz rekomendacje zawarte w Ocenie Efektywności. Umowa o PPP, w tym PFU i Standardy Utrzymania, muszą uwzględniać zasadne rekomendacje i wnioski z analiz zaakceptowane przez Zespół Projektowy.



Uwzględnienie wniosków z Dialogu Konkurencyjnego

Umowa o PPP stanowi przez cały okres Postępowania PPP żywy dokument podlegający bieżącym modyfikacjom, zmianom, uzupełnieniom w trakcie Dialogu Konkurencyjnego. Z punktu widzenia dobrze skonstruowanej Umowy o PPP istotne jest właściwe przeanalizowanie oraz odpowiednie uwzględnienie słusznych z punktu widzenia celów Projektu postulatów Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących. Zdarza się, że w celu usprawnienia prac nad Umową o PPP Podmioty Publiczne oczekują sformułowania od Partnerów Prywatnych uczestniczących w Dialogu Konkurencyjnym proponowanych zmian do projektu Umowy o PPP wraz z komentarzem zawierającym uzasadnienie proponowanych zmian.



Zapewnienie odpowiedniej elastyczności Umowy o PPP

Z uwagi na długoterminowość Umowy o PPP ważne jest, aby zawierała ona możliwie najszerszy katalog dopuszczalnych jej zmian, tak aby umożliwić stronom w przyszłości efektywne dostosowywanie wzajemnych relacji do zmieniających się okoliczności.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym projekcie Umowa o PPP zobowiązywała Partnera Prywatnego do zatrudnienia minimalnej liczby pracowników na umowę o pracę pod rygorem kary umownej i dalej wypowiedzenia Umowy o PPP z winy Partnera Prywatnego. Wymaganie to miało realizować jeden z celów Podmiotu Publicznego w zakresie zmniejszenia bezrobocia w gminie. W toku realizacji Umowy powstała możliwość zastosowania nowych technologii pozwalających

na zmniejszenie liczebności kadry. Co więcej, z uwagi na otoczenie makroekonomiczne zatrudnianie takiej liczby pracowników było zupełnie nieuzasadnione z perspektywy efektywności finansowej. Partner Prywatny wnioskował o zmianę Umowy w powyższym zakresie. Podmiot Publiczny uznał, że taka zmiana jest z przyczyn formalnych niemożliwa i z uwagi na zmniejszenie kadry przez Partnera Prywatnego wypowiedział Umowę o PPP. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura na skutek przedterminowego rozwiązania Umowy przez ponad rok, do momentu wyboru kolejnego operatora była nieczynna, a Podmiot Publiczny zobowiązany był do rozliczenia się z Partnerem Prywatnym za wykonane Prace Projektowe i Roboty (z potrąceniem kary umownej należnej od Partnera Prywatnego).



Właściwe zdefiniowanie pojęć

Sekcja Definicji jest narzędziem służącym do właściwego nawigowania po tekście Umowy o PPP i ma pozwolić na łatwiejsze jej zrozumienie. Dlatego też definicje powinny być tak intuicyjne, na ile to możliwe. Właściwe zdefiniowanie pojęć pozwala na sprawniejsze przygotowywanie innych dokumentów związanych z Projektem (z ich wykorzystaniem).

2. Charakterystyka Umowy o PPP

2.1 Warunki konieczne Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.3 – Systematyka Projektów PPP i Koncesji

Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

Tom II: Punkt 6.5.4 – Istotne postanowienia Umowy o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Umowa o PPP jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP. Zgodnie z tym przepisem "przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego".

Zgodnie z Ustawą o PPP Umowa o PPP musi obligatoryjnie zawierać następujące regulacje (*essentialia negotii*):

- 1) zawarcie Umowy o PPP przez podmioty posiadające właściwy status prawny w rozumieniu Ustawy o PPP, tj. spełnienie przez jedną stronę umowy przesłanki uznania jej za Podmiot Publiczny (art. 2 pkt 1 Ustawy o PPP) oraz spełnienie przez drugą stronę umowy przesłanki uznania jej za Partnera Prywatnego (art. 2 pkt 2 Ustawy o PPP);
- 2) zobowiązanie Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP, tj.:
 - budowy lub remontu obiektu budowlanego;
 - świadczenia usług;
 - wykonania dzieła, w szczególności wyposażenia składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność; lub
 - innego świadczenia

które połączone będzie z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, wykorzystywanym do realizacji Przedsięwzięcia lub jest z nim związany;

- 3) zobowiązanie Podmiotu Publicznego do zapłaty Wynagrodzenia (art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP);
- 4) zobowiązanie Podmiotu Publicznego do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia – zawarcie tego rodzaju zobowiązań w Umowie o PPP (np. dotyczących wniesienia wkładu własnego w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o PPP przez Podmiot Publiczny) realizuje cel PPP, polegający na wspólnej realizacji Przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP);

- 5) zobowiązanie Partnera Prywatnego do poniesienia przez niego lub przez osobę trzecią w całości albo w części wydatków na realizację Przedsięwzięcia – jest to de facto zobowiązanie Partnera Prywatnego do zapewnienia Finansowania (własnego lub pozyskanego od Instytucji Finansującej) (art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP);
- 6) uzależnienie Wynagrodzenia przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej Dostępności przedmiotu Przedsięwzięcia (tj. Infrastruktury Publicznej) (art. 7 ust. 2 Ustawy o PPP) – w przypadku Opłaty za Dostępność mamy do czynienia z drugą ze wskazanych sytuacji. Podmiot Publiczny zobowiązany będzie wówczas do zapłaty Wynagrodzenia niezależnie od faktycznego wykorzystania Infrastruktury Publicznej przez Użytkowników (ryzyko popytu pozostaje po stronie Podmiotu Publicznego);
- 7) określenie skutków nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązań zawartych w Umowie o PPP, w szczególności kar umownych lub obniżenia Wynagrodzenia (art. 7 ust. 3 Ustawy o PPP);
- 8) określenie maksymalnej wysokości oraz warunków zmiany Opłat od Użytkowników, jeżeli planowane jest ich pobieranie w Przedsięwzięciu przez Partnera Prywatnego (art. 7 ust. 5 Ustawy o PPP);
- 9) określenie zasad i szczegółowego trybu przeprowadzania przez Podmiot Publiczny bieżącej kontroli Przedsięwzięcia oraz kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia (np. Nieruchomości, która została udostępniona Partnerowi Prywatnemu w celu realizacji Przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego Podmiotu Publicznego) (art. 8 ust. 1 Ustawy o PPP);
- 10) określenie skutków niepodjęcia przez Partnera Prywatnego działań mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego wykorzystywanego przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia do właściwego stanu technicznego (w przypadku, gdy prowadzona kontrola wykaże, iż ten składnik majątkowy znajduje się w stanie technicznym wskazującym na jego nieprawidłowe wykorzystywanie) (art. 8 ust. 2 Ustawy o PPP);
- 11) określenie zasad, szczegółowego trybu oraz częstotliwości bieżącego raportowania przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu o stanie realizacji Przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego wykorzystywanego przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia (art. 8 ust. 3 Ustawy o PPP);
- 12) określenie przeznaczenia składnika majątkowego wniesionego przez Podmiot Publiczny, wykorzystywanego przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia (np. przeznaczenie Nieruchomości polegające na Budowie na niej torowiska tramwajowego i jego Utrzymaniu) (art. 9 ust. 2 Ustawy o PPP);
- 13) określenie zasad przekazania Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego składnika majątkowego wniesionego przez Podmiot Publiczny, wykorzystywanego przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia, gdy jest on wykorzystywany w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem (art. 9 ust. 2 Ustawy o PPP);
- 14) wymagania wynikające z Ustawy PZP dla umowy o zamówienie publiczne (jeżeli do wyboru Partnera Prywatnego zastosowano przepisy PZP, zob. Część I Punkt 2.6 Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP), albo wynikające z Ustawy o Umowie Koncesji dla umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi (jeżeli do wyboru Partnera Prywatnego zastosowano przepisy Ustawy o Koncesji);

15) wymagania właściwe dla Spółki PPP, jeżeli Projekt PPP realizowany jest w ramach PPP Instytucjonalnego (art. 14-16 Ustawy o PPP).

UWAGA



Essentialia negotii (elementy przedmiotowo istotne czynności prawnej) są podstawowymi składnikami każdej umowy, określającymi jej typ. Stanowią one o minimalnej i niezbędnej treści umowy, aby była ona wiążąca dla stron. Brak uwzględnienia w Umowie o PPP wymienionych powyżej obligatoryjnych jej elementów, co do zasady, skutkować będzie ryzykiem nieważności Umowy o PPP (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r., sygn. akt II CKN 726/00).

Przykładowa szczegółowa systematyka Umowy o PPP została przedstawiona w Części II i zawiera typowe jej punkty.

UWAGA



Poza elementami przedmiotowo istotnymi (*essentialia negotii*) Umowa o PPP reguluje szereg innych kwestii znanych również w klasycznych umowach o zamówienie publiczne. Przykładowo wstępna część Umowy o PPP, obejmująca komparację (oznaczenie stron), nie różni się znacząco od umów zawieranych w wyniku przeprowadzenia tradycyjnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowy o PPP zazwyczaj zawierają preambułę, określającą m.in. zgodny zamiar stron oraz cele Umowy lub poszczególnych jej postanowień, co ułatwia późniejszą wykładnię Umowy o PPP.

Zwykle poza wyraźnie określonymi w Umowie przypadkami (np. przypadki kompensacyjne, czy siła wyższa) Partner Prywatny odpowiedzialny jest za należyte wykonanie Robót, ich sfinansowanie oraz za zapewnienie Standardów Utrzymania, Zarządzanie i Dostępność Infrastruktury Publicznej (większość ryzyka związanego z Projektowaniem, Budową oraz Utrzymaniem jest po stronie prywatnej).

Uregulowanie części takich szczegółowych zagadnień wynika z woli stron korzystających ze swobody umów. Warto jednak zwrócić uwagę, że w Ustawie o PPP wskazano niektóre elementy Umowy o PPP, które mogą zostać uregulowane w Umowie o PPP odmiennie niż wynika to z Ustawy o PPP (np. Umowa o PPP może odmiennie regulować ustawowy termin na wykonanie przez Partnera Prywatnego prawa pierwokupu do Nieruchomości, będącej wkładem własnym Podmiotu Publicznego w przypadku jej sprzedaży przez Podmiot Publiczny lub Spółkę PPP – zob. art. 12 ust. 1 Ustawy o PPP).

Ponadto, wymogi co do treści umowy o zamówienie publiczne określone w przepisach Ustawy PZP nie mają częściowo zastosowania do Umowy o PPP. Szerzej na ten temat w Części I Punkt 2.6 Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP.

2.2 Istotne warunki Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.4 – Analizy prawne

Tom I: Część II Punkt 3.5 – Analizy podatkowe

Tom II: Punkt 6.5.4 – Istotne postanowienia Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 1 – Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Poza warunkami koniecznymi Umowy o PPP (*essentialia negotii*) zawiera ona postanowienia uzgodnione pomiędzy stronami podczas negocjacji na zasadzie swobody kontraktowania. Obejmują one ważne kwestie komercyjne oraz postanowienia istotne z punktu widzenia Bankowości. Poniżej przedstawiono listę kluczowych regulacji Umowy o PPP będących przedmiotem negocjacji.



Zakres Prac Projektowych oraz Robót

Czy PFU właściwie adresuje zakres Prac Projektowych oraz Robót, czy nie ogranicza możliwości optymalizacji technologicznej i kosztowej oraz zastosowania know-how, a tym samym uzyskania przewag konkurencyjnych przez Partnerów Prywatnych.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP obejmującym kompleks budynków użyteczności publicznej Podmiot Publiczny dysponował bardzo szczegółową koncepcją projektową, która zawierała dokładne wymagania m.in. co do technologii, sposobu wykonania Robót, materiałów. Podmiot Publiczny wdrożył szczegółowe rozwiązania z koncepcji projektowej do PFU.

Wykonawcy podnosili, że PFU powinien raczej zawierać doszczegółowienie opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego, a w sytuacji, w której bardzo konkretne rozwiązania techniczne są określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, brak jest miejsca na optymalizację przez Partnera Prywatnego przyjmowanych rozwiązań na etapie Projektowania. Tymczasem wykorzystanie know-how Partnera Prywatnego i optymalizacja rozwiązań powinna być istotna dla Podmiotu Publicznego w ramach realizacji Projektu PPP.

Ponadto w PFU znalazły się także wymagania, które były rozbieżne i niespójne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o Zamówieniu (np. w zakresie liczby pomieszczeń czy miejsc parkingowych).

Na gruncie postulatów podnoszonych przez Partnerów Prywatnych podczas Dialogu Konkurencyjnego Podmiot Publiczny dokonał potrzebnych zmian w treści PFU, co pozwoliło na wdrożenie szeregu optymalizacji oszacowanych na 10 mln PLN.

Między innymi na etapie Prac Projektowych wybrany Partner Prywatny zaproponował budowę jednego parkingu podziemnego z niezależnymi wejściami z każdego z budynków w miejsce pierwotnych kilku osobnych parkingów.



Zakres Utrzymania i KPI

Czy Standardy Utrzymania właściwie adresują zakres Utrzymania oraz czy KPI są dostosowane do specyfiki Projektu PPP oraz potrzeb Podmiotu Publicznego.

Czy KPI określone przez Podmiot Publiczny stanowią listę zamkniętą, są mierzalne i są precyzyjnie opisane.

Czy KPI nie są nadmiernie wygórowane, biorąc pod uwagę realne potrzeby i dostępność finansową Podmiotu Publicznego.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora drogowego obejmującym drogi gminne Podmiot Publiczny uwzględnił w Standardach Utrzymania standardy utrzymania zimowego publikowane przez GDDKiA w odniesieniu do dróg krajowych. W rezultacie w wyniku rozmów prowadzonych w ramach Dialogu Konkurencyjnego Podmiot Publiczny wyodrębnił te odcinki dróg, na których szczególnie zależało mu na podniesieniu standardów (m.in. z uwagi na częste wypadki na tych odcinkach zimą), a w pozostałym zakresie obniżył standard w sposób adekwatny do swoich realnych potrzeb. Pozwoliło to na otrzymanie Ofert z racjonalnym poziomem cen.



Zakres przypadków kompensacyjnych

Czy zdarzenia i ryzyka, na które Partner Prywatny nie ma wpływu i nie jest w stanie nimi zarządzać zostały uwzględnione jako przypadki kompensacyjne oraz czy procedura ustalania przypadku kompensacyjnego uwzględnia jego wpływ na koszty Projektu oraz harmonogram.

DOBRE PRAKTYKI



Zdarza się, że Podmioty Publiczne, w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych w projekcie, przyznają Partnerowi Prywatnemu prawo do wydłużenia terminów w harmonogramie bez uprawnienia do odszkodowania wynikającego z takiego wydłużenia terminów (np. wynikającego z kosztów zabezpieczenia Terenu Budowy w przypadku znaleziska archeologicznego). Powoduje to ryzyko niemożliwe do oszacowania na etapie składania Oferty. W rezultacie Partner Prywatny zobowiązany będzie założyć stosowny bufor finansowy na zabezpieczenie takiego ryzyka, co niepotrzebnie podniesie wartość Oferty.

Dobłą praktyką jest uwzględnienie w skutkach przypadków kompensacyjnych również ich kosztów.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP projekt Umowy o PPP przewidywał przeniesienie ryzyka zmiany stóp procentowych na Partnera Prywatnego. Partner Prywatny podczas dialogu wskazywał, że w projektach PPP standardem jest przyjęcie ryzyka stopy procentowej przez Podmiot Publiczny. Ryzyko zmiany stóp procentowych w przedsięwzięciu PPP jest ryzykiem z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia, a jego waga jest istotna. Tym samym nieprzyjęcie ryzyka zmiany stóp procentowych przez Podmiot Publiczny oznaczałoby, że Partner Prywatny ma ponosić ryzyko, na które nie ma wpływu, ani też nie jest w stanie ocenić jego wartości. Podmiot Publiczny zmienił podejście podczas negocjacji i przyjął ryzyko zmiany stóp procentowych w oparciu o indeksację WIBOR.



Kary umowne i Punkty Karne

Czy kary umowne/Punkty Karne zostały ustalone w sposób adekwatny – kary umowne mają mieć charakter motywujący, odszkodowawczy, a nie wyłącznie represyjny. Ponadto, z osiągnięciem określonego poziomu kar umownych powinna wiązać się możliwość zakończenia Umowy o PPP przez każdą ze stron ze wszystkimi konsekwencjami (np. dodatkowymi karami na okoliczność zakończenia Umowy o PPP z winy jednej ze stron). Powyższe ma za zadanie przeciwdziałać kontynuowaniu Umowy o PPP w przypadku, gdy brak jest rokowań co do powodzenia Projektu PPP.



Mechanizm Wynagradzania

Czy Mechanizm Wynagradzania w sposób prawidłowy uwzględnia właściwości i założenia Projektu. Czy poszczególne komponenty Opłaty za Dostępność są indeksowane w sposób adekwatny i odzwierciedlający cechy Projektu (np. czy koszyk waloryzacyjny i wagi wskaźników zostały ustalone w sposób uwzględniający cechy konkretnego Projektu PPP i sektora).

PRZYKŁAD



W przykładowym Projekcie PPP obejmującym budowę budynku użyteczności publicznej stal stanowiła jeden z kluczowych materiałów budowlanych. Podmiot Publiczny w projekcie Umowy o PPP zaproponował waloryzację części Opłaty za Dostępność (opłaty za nakłady inwestycyjne) w oparciu o wskaźnik wzrostu cen usług konsumpcyjnych (CPI). W trakcie Dialogu Konkurencyjnego zaproponowano koszyk waloryzacyjny złożony ze wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz wartości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.



Przesłanki wypowiedzenia Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny

Czy przesłanki wypowiedzenia są dostosowane do specyfiki projektu oraz czy został przewidziany wystarczający okres na zaniechanie naruszeń w celu kontynuowania Umowy o PPP.

Czy wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń (w tym przypadku siły wyższej) uprawnia strony do przedterminowego zakończenia Umowy o PPP.



Zmiany Umowy o PPP

Czy Umowa o PPP jest wystarczająco elastyczna, aby mogła być dostosowana do zmieniających się okoliczności w trakcie trwania Umowy o PPP. Czy postanowienia Umowy o PPP w sposób prawidłowy uwzględniają przepisy Ustawy PZP mające zastosowanie do zmiany Umowy o PPP.



Limit odpowiedzialności. Limity kar umownych

Czy Umowa o PPP uwzględnia limit odpowiedzialności Partnera Prywatnego oraz limity kar umownych skorelowane z przesłankami wypowiedzenia Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny.



Umowa Bezpośrednia

Czy Umowa o PPP umożliwia zawarcie Umowy Bezpośredniej i przewiduje możliwość wprowadzenia koniecznych zmian do Umowy o PPP.



Rozliczenie na wypadek przedterminowego Zakończenia Umowy o PPP

Czy Umowa o PPP przewiduje adekwatne rozliczenie za poniesione nakłady z uwzględnieniem adekwatnych kar umownych dla każdej ze stron w zależności od przyczyn zakończenia Umowy o PPP.



Rozstrzyganie Sporów

Czy Umowa o PPP przewiduje sposób rozstrzygania sporów uwzględniający podejście koncyliacyjne.

2.3 Strategia negocjacyjna

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom II: Punkt 3.3 – Strategia negocjacyjna

Tom II: Punkt 6 – Negocjacje

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.5 – Negocjacje

Podmiot Publiczny w obszarach prawnych i komercyjnych powinien mieć wypracowane podejście wyjściowe. Podejście to powinno zostać omówione i wypracowane w ramach Zespołu Projektowego PPP w oparciu o aktualne na dany moment warunki rynkowe oraz standardy sektorowe. Dzięki temu Podmiot Publiczny jest równorzędnym partnerem w dyskusjach z Partnerami Prywatnymi podczas Dialogu Konkurencyjnego i jest w stanie wypracować warunki Umowy o PPP uwzględniające zarówno własne cele, jak i aktualne otoczenie rynkowe.

DOBRE PRAKTYKI



Podmiot Publiczny, rozpoczynając negocjacje, powinien mieć rozeznanie co do warunków rynkowych i komercyjnych Umowy o PPP akceptowanych w danym momencie na rynku – m.in. w obszarze wysokości kar umownych, limitów odpowiedzialności, waloryzacji wynagrodzenia, podziału zadań i ryzyk. Ponadto, Podmiot Publiczny powinien mieć rozpoznaną specyfikę sektora, którego dotyczy Projekt PPP. Warto mieć na uwadze, że warunki akceptowane przez rynek mogą zmieniać się w czasie. Informacje w tym zakresie Podmiot Publiczny powinien pozyskać na etapie Oceny Efektywności, w tym w ramach badania rynku. Ponadto, należy zapewnić odpowiednią elastyczność Umowy o PPP na potrzeby zmieniających się warunków w przyszłości.

Dobłą praktyką jest zidentyfikowanie przez Zespół Projektowy PPP warunków komercyjnych aktualnie najbardziej powszechnych na rynku umów o prace projektowe, roboty budowlane, PPP, czy w danym sektorze. Pozwoli to na merytoryczną dyskusję z Partnerami Prywatnymi podczas negocjacji.

DOBRE PRAKTYKI



W Projektach PPP o wysokim stopniu ustandaryzowania, w których Podmiot Publiczny jest dobrze przygotowany do Dialogu Konkurencyjnego, ma jasno sprecyzowane potrzeby i wymagania oraz dysponuje pełną dokumentacją Postępowania, w tym projektem Umowy o PPP, odpowiadającym standardom rynkowym, dobrą praktyką jest skrócenie okresu przewidzianego na Dialog Konkurencyjny. W takich projektach bowiem nie jest konieczne przeprowadzanie kilku tematycznych rund dialogu.

2.4 Okres Obowiązywania Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-IV



Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom I: Część II Punkt 3.4 – Analizy prawne

Tom I: Część II Punkt 3.5 – Analizy podatkowe

Tom I: Część II Punkt 3.8.2 – Założenia dla analiz ekonomiczno-finansowych
Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej
Tom IV: Część I Punkt 4 – Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP
Tom IV: Część II Punkt 2.2 – Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP

Umowa o PPP, jako umowa o zamówienie publiczne, jest zawierana na czas oznaczony (art. 434 ust. 1 Ustawy PZP). Co do zasady, umowy o zamówienie publiczne powinny być zawierane na okres do 4 lat. Zamawiający może jednak zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągle na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione dostępnością finansową Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty (art. 434 ust. 2 Ustawy PZP).

Ze względu na długi okres spłaty nakładów w przypadku Projektów PPP, Umowy o PPP zawierane będą na okresy znacznie przekraczające 4 lata – zwykle okresy Umów o PPP wynoszą pomiędzy 10 – 30 lat.

Podmiot Publiczny ustalając okres, na jaki powinna zostać zawarta Umowa o PPP, powinien kierować się również uzyskaniem jak najlepszej efektywności Projektu PPP w kontekście zarówno Value for Money, jak również Value for People. W tym celu należy brać pod uwagę między innymi:

- potrzeby Podmiotu Publicznego w zakresie świadczonych usług publicznych, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym;
- przewidywany okres trwałości Infrastruktury Publicznej, w tym potrzeby w zakresie istotnych remontów Infrastruktury Publicznej;
- możliwość w miarę dokładnego oszacowania kosztów Projektu PPP w planowanym Okresie Obowiązkiwania Umowy;
- prognozowaną sytuację finansową Podmiotu Publicznego pod kątem dostępności finansowej w celu płatności OzD.

2.5 Harmonogram

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 4 – Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania PPP
Tom I: Część I Punkt 5.1 – Realistyczny harmonogram, odpowiednie planowanie i organizacja procesu przygotowania Projektu PPP
Tom IV: Część II Punkt 2.1.3 – Harmonogram działań
Tom IV: Część II Punkt 3.2 – Harmonogram Etapu Inwestycyjnego

Harmonogram załączony wraz z Ofertą stanowi załącznik do Umowy o PPP. Powinien określać nie tylko termin zakończenia Robót Budowlanych, ale również terminy osiągnięcia kluczowych dla projektu etapów, tj. tzw. kamieni milowych.

Z reguły kamienie milowe określa się na Okres Budowy (np. pozyskanie pozwolenia na budowę, terminy wykonania Robót ulegających zakryciu, realizacji określonego w Umowie o PPP etapu Robót). Jest to istotne, dlatego że w trakcie procesu inwestycyjnego występują zdarzenia mające wpływ na termin realizacji Robót. Jeżeli dojdzie do przekroczenia terminów w sposób istotny i ewidentnie wpływający na termin końcowy z winy Partnera Prywatnego (np. kilka miesięcy), Podmiot Publiczny powinien mieć możliwość przedterminowego Zakończenia Umowy już na tym etapie (zob. szerzej Część II Punkt 9.1 Wypowiedzenie Umowy o PPP).

2.6 Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom II: Punkt 2.4 – Ustawa o PPP a Ustawa PZP i Ustawa o Umowie Koncesji

Odesłanie w Ustawie o PPP do przepisów Ustawy PZP

Jeżeli Umowa o PPP stanowi umowę o zamówienie publiczne (art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP), to do takiej Umowy o PPP znajdują zastosowanie przepisy Ustawy PZP w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP. Przepisy Ustawy PZP regulują między innymi kwestię przedmiotu umowy o zamówienie publiczne oraz jej obligatoryjnych postanowień.

Ustawa PZP definiuje zamówienie jako umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy Robót Budowlanych, dostaw lub usług (art. 7 pkt 32 Ustawy PZP). Umowa ta, zgodnie z art. 436 pkt 1-2 Ustawy PZP, powinna w każdym wypadku zawierać przynajmniej postanowienia określające planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub Robót Budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub Robót Budowlanych, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, oraz warunki zapłaty wynagrodzenia.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 433 Ustawy PZP niedopuszczalne są następujące postanowienia w Umowie o PPP:

- odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
- możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

UWAGA



W Umowach o PPP zazwyczaj przewiduje się instrumenty uprawniające Podmiot Publiczny do ograniczenia zakresu prac Partnera Prywatnego (np. polecenie zmiany). W takim przypadku konieczne jest wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczeń Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny na etapie złożenia Oferty wycenia swoje Wynagrodzenie w oparciu o przedstawiony w Umowie o PPP i innych dokumentach Postępowania PPP zakres Projektu. Wynagrodzenie uwzględnia również wstępnie ustalone warunki Finansowania adekwatne do skali Projektu oraz jego otoczenia rynkowego. Ponadto, przed złożeniem Oferty Partner Prywatny wiążąco uzgadnia warunki z Podwykonawcami.

W związku z tym, zmniejszenie zakresu Prac Projektowych lub Robót mogłoby skutkować koniecznością zmiany powyższych uzgodnień z Instytucjami Finansowymi oraz Podwykonawcami. Oprócz tego, Partner Prywatny mógłby nie być zainteresowany realizacją Projektu o istotnie mniejszej skali niż zakładana.

Odpowiedzialność solidarna członków konsorcjum

Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP do Umów PPP nie stosuje się art. 445 ust. 1 Ustawy PZP wprowadzającego solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia, niemniej jednak odpowiedzialność ta może zostać przewidziana w Umowie o PPP.

Zabezpieczenie należytego wykonania

Omawiana regulacja przepisu art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP wyłącza również zastosowanie art. 452 i 453 Ustawy PZP dotyczących ustalania wysokości (w tym maksymalnej wysokości) zabezpieczenia należytego wykonania oraz zasad jego zwrotu. Podmiot Publiczny może te zasady uregulować odrębnie w Umowie o PPP z uwagi na charakterystykę Projektów PPP (projekty wieloletnie, brak płatności w Okresie Projektowania oraz w Okresie Budowy, rozłożenie płatności Wynagrodzenia w Okresie Utrzymania). Na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o PPP stosowanych w Projektach PPP zob. Część II Punkt 1.8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o PPP.

Pozostałe wyłączenia

Zgodnie z art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP do Umowy o PPP nie stosuje się art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437-440, art. 443, art. 447 oraz art. 463-465 Ustawy PZP. Wyłączenia te obejmują omówione poniżej trzy grupy zagadnień.



Kary umowne i waloryzacja Wynagrodzenia

Umowa o PPP nie musi zawierać określonych w art. 436 pkt 3 i 4 Ustawy PZP postanowień dot. łącznej maksymalnej wysokości kar umownych oraz waloryzacji Wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek danin publicznych, minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym itp.

UWAGA



Z uwagi na Bankowość limitowanie kar umownych jest często uwzględniane w Umowach o PPP. W innych przypadkach uzyskanie finansowania dłużnego dla realizacji Projektu PPP może okazać się niemożliwe.

Nie ma także obowiązku uwzględniania w Umowie o PPP uregulowanych w art. 439 Ustawy PZP zasad waloryzacji Wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

UWAGA



Ze względu na długoterminowy charakter Umowy o PPP i Bankowość w Umowach o PPP przewiduje się waloryzację części Opłaty za Dostępność dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz Utrzymania (zob. Część II Punkt 4.1 Mechanizm Wynagradzania).



Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Przepis art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP wyłącza stosowanie do Umowy o PPP także art. 95 i art. 438 Ustawy PZP dotyczących obligatoryjnego wymagania od Partnera Prywatnego stosowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Wynika to bowiem ze specyfiki Projektów PPP, które zazwyczaj realizuje Spółka Projektowa poprzez przekazanie określonych zadań i ryzyk związanych z Budową, Utrzymaniem i Zarządzaniem (ang. *flow-down*) Generalnemu Wykonawcy i Operatorowi. To Podwykonawcy dysponują określonym potencjałem kadrowym (personelem), niezbędnym do realizacji powierzonych im prac. Tym samym Spółka Projektowa nie musi samodzielnie zatrudniać personelu niezbędnego do realizacji Budowy, Utrzymania czy Zarządzania, co powoduje, iż omawiane przepisy Ustawy PZP nie odpowiadają charakterystyce realizacji Projektów PPP.



Umowa o PPP a zamówienie na roboty budowlane

Zgodnie ze wspomnianym art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP, do Umowy o PPP nie mają zastosowania:

- 1) przepis art. 437 Ustawy PZP zawierający szereg szczegółowych wymagań co do treści umowy dotyczącej zamówienia na roboty budowlane (w szczególności dotyczących obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i związanych z nią dokumentów, jak również zasad i terminów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom);
- 2) przepis art. 443 Ustawy PZP dotyczący sposobu zapłaty wynagrodzenia w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (zapłata w częściach po wykonaniu części zamówienia lub udzielenie zaliczki);
- 3) przepis art. 447 Ustawy PZP dotyczący obowiązku przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (warunku wypłaty wynagrodzenia wykonawcy);

- 4) przepis art. 463 Ustawy PZP ustanawiający zakaz ukształtowania umowy o podwykonawstwo w sposób mniej korzystny od umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia;
- 5) przepis art. 464 Ustawy PZP dotyczący obowiązku przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, elementów treści tej umowy, trybu zgłaszania zastrzeżeń do projektu i obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo ostatecznie zawartej;
- 6) przepis art. 465 Ustawy PZP dotyczący zasad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Ratio legis art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP jest fakt, iż w przypadku Projektów PPP często inwestorem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego będzie Partner Prywatny. Zaangażowanie Podmiotu Publicznego w Okresie Projektowania i w Okresie Budowy sprowadzać się będzie w takim przypadku do weryfikacji wykonania postawionego przed Partnerem Prywatnym celu. Podmiot Publiczny nie zawiera natomiast z Partnerem Prywatnym umowy o roboty budowlane, zawiera z nim bowiem Umowę o PPP. Umowa o roboty budowlane zawierana jest przez Partnera Prywatnego z Generalnym Wykonawcą (jako Podwykonawcą Partnera Prywatnego).

Powyższe regulacje Ustawy PZP odnoszące się do zamówień na roboty budowlane nie będą miały zastosowania do Umowy o PPP, jako że nie jest ona umową o roboty budowlane w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a inną umową nazwaną. Dotyczy to szczególnie regulacji Ustawy PZP obejmujących rozliczania przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (które w Umowach o PPP zwykle nie jest płatne w Okresie Budowy) i odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za płatność wynagrodzenia Podwykonawcom (skoro Podmiot Publiczny w Okresie Budowy nie płaci Wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu, nie powinien zostać zmuszony na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z Partnerem Prywatnym do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy). Odpowiedzialność za płatność wynagrodzenia Podwykonawcom spoczywa na inwestorze, którym jest Partner Prywatny. Zatem to on powinien być wyłącznie odpowiedzialny za wynagrodzenie Podwykonawców, tj. Generalnego Wykonawcy i Operatora oraz dalszych Podwykonawców (pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym brak jest relacji inwestor – wykonawca, jaka ma miejsce w klasycznych umowach o roboty budowlane).

2.7 Umowa o PPP a PPP Instytucjonalne

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.3 – Systematyka Projektów PPP i Koncesji

W PPP Kontraktowym realizacja Przedsięwzięcia następuje na podstawie Umowy o PPP, zawartej pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, która w sposób kompleksowy ustala podział ryzyka pomiędzy stronami.

Przedsięwzięcia realizowane w formie Spółki PPP w modelu PPP Instytucjonalnego różnią się od PPP Kontraktowego przede wszystkim tym, że:

- Partner Prywatny i Podmiot Publiczny zakładają spółkę celową (akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością), tj. Spółkę PPP; bądź też

- Partner Prywatny obejmuje udziały/akcje w istniejącej spółce Podmiotu Publicznego (która po objęciu udziałów/akcji staje się Spółką PPP).

Struktura kontraktowa w ramach PPP Instytucjonalnego pomiędzy partnerami (wspólnikami) może być oparta o trzy główne umowy (tj. Umowę o PPP, umowę pomiędzy wspólnikami Spółki PPP i umowę Spółki PPP) albo ograniczać się do dwóch dokumentów transakcyjnych tj. Umowy o PPP i umowy Spółki PPP. W tym drugim przypadku Umowa o PPP reguluje w sposób kompleksowy relacje pomiędzy wspólnikami Spółki PPP i podział ryzyka pomiędzy nimi.

W PPP Instytucjonalnym w pierwszej kolejności zawierana jest Umowa o PPP i na jej podstawie umowa Spółki PPP. W celu zapewnienia właściwego transferu ryzyk, Umowa o PPP z reguły przewiduje, że Podmiot Publiczny jest wspólnikiem mniejszościowym. Umowa o PPP powinna uwzględniać zobowiązania stron do zawarcia umowy Spółki PPP. Relacje pomiędzy wspólnikami Spółki PPP mogą zostać uregulowane albo w oddzielnej umowie pomiędzy wspólnikami, albo bezpośrednio w Umowie o PPP. W pierwszym przypadku Umowa o PPP powinna zawierać kluczowe elementy (wytyczne do) umowy pomiędzy wspólnikami Spółki PPP, w tym w zakresie ładu korporacyjnego. W drugim przypadku Umowa o PPP powinna regulować wszystkie niezbędne kwestie dotyczące relacji pomiędzy wspólnikami Spółki PPP.

Należy pamiętać, że w modelu PPP Instytucjonalnego – w odróżnieniu od PPP Kontraktowego – to Spółka PPP (a nie Partner Prywatny) dokonuje prawidłowego przeniesienia ryzyk kontraktowych na dalsze podmioty (ang. *flow-down*). Spółka PPP zawiera zatem wszystkie umowy projektowe niezbędne w celu realizacji Przedsięwzięcia, w tym umowę z Generalnym Wykonawcą, Operatorem, czy umowy dotyczące Finansowania.

UWAGA



W przypadku realizacji Przedsięwzięcia w ramach PPP Instytucjonalnego nie jest konieczne zawieranie czy negocjowanie wraz z Umową o PPP umów podwykonawczych. Są to umowy, które dotyczą poszczególnych etapów realizacji Przedsięwzięcia, za których wykonanie powinna odpowiadać Spółka PPP. Dlatego też umowy takie zawiera i negocjuje Spółka PPP po zawarciu Umowy o PPP. Negocjowanie czy zawieranie umów wykonawczych wraz z Umową o PPP jest zatem przedwczesne i niepotrzebnie komplikujące Postępowanie PPP.

2.8 Objasnienia podatkowe Ministra Finansów

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.5 – Analizy podatkowe

W dniu 1 grudnia 2017 r., korzystając z ustawowych uprawnień, Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe pn. "Rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym". Objaśnienia podatkowe zostały wydane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika

w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go stosowną ochroną przewidzianą w tej ustawie.

Jak wynika z objaśnień podatkowych dotyczą one wybranych kwestii rozliczania przez Partnera Prywatnego na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych transakcji realizowanych w ramach Umów o PPP w rozumieniu Ustawy o PPP.

Mając na względzie, że PPP może być realizowane w wariantach różniących się w znacznej mierze stopniem przeniesienia na stronę prywatną ryzyka związanego z Budową, Finansowaniem i Utrzymaniem przedmiotu Umowy o PPP, w objaśnieniach podatkowych wyraźnie wskazano, że objęto nimi jeden przykładowy wariant PPP, w którym Podmiot Publiczny zleca Partnerowi Prywatnemu, na podstawie Umowy o PPP, usługę projektową obejmującą zaprojektowanie obiektu oraz usługę budowlaną (budowlano-montażową), obejmującą wybudowanie obiektu, a także usługę Utrzymania (eksploatacji) i Zarządzania obiektem wybudowanym na Nieruchomości będącej przez cały okres obowiązywania Umowy (zazwyczaj) własnością Podmiotu Publicznego. Ponadto, w ramach Umowy o PPP, Partner Prywatny zobowiązuje się do zapewnienia finansowania "etapu Robót" poprzez rozłożenie płatności wynagrodzenia za ten etap w czasie. Przyjęto, że Partner Prywatny ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy obiekt zostaje przekazany Podmiotowi Publicznemu. Wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia należne Partnerowi Prywatnemu stanowi Opłata za Dostępność, płatna przez Podmiot Publiczny dopiero w Okresie Utrzymania (po oddaniu obiektu do użytkowania), w cyklicznych okresach rozliczeniowych, przez okres wskazany w Umowie o PPP. Taka konstrukcja zakłada, że okresowa płatność (Opłata za Dostępność) na rzecz Partnera Prywatnego pokrywa nie tylko bieżące Utrzymanie obiektu, ale także zawiera odpowiednią część Wynagrodzenia za czynności wykonane w Okresie Budowy dotyczące zaprojektowania oraz wybudowania obiektu, a także, jeżeli strony tak postanowiły, zawiera opłatę za Usługę Finansową.

Objaśnienia podatkowe dotyczą zatem wariantu PPP, w którym Partner Prywatny świadczy na rzecz Podmiotu Publicznego następujące usługi:

- 1) usługę projektową;
- 2) usługę budowlaną (budowlano-montażową);
- 3) usługę Utrzymania (eksploatacji) i Zarządzania obiektem;
- 4) Usługę Finansową.

W świetle objaśnień podatkowych, każda z tych usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na odrębnych zasadach.

Umowa o PPP może także przewidywać dokonywanie przez jej strony płatności pozostających poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Do takich płatności należą przykładowo kary umowne i odszkodowania (ale również: wadium wniesione w Postępowaniu, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, inne zabezpieczenia wnoszone przez Partnera Prywatnego - niezależnie od ich formy).

Umowa o PPP może umożliwiać dokonywanie przez strony potrąceń wzajemnych wierzytelności. Należy przyjąć, że operacje polegające na potrąceniu (kompensacie) wzajemnych należności mają charakter wyłącznie finansowy (rozliczeniowy) i w żadnej mierze nie wpływają na treść faktur wystawianych przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego z tytułu Umowy o PPP, w tym na wysokość wykazywanych w nich kwot, podstawę opodatkowania podatkiem VAT z tytułu wykonywanych przez strony czynności lub kwotę należnego podatku VAT.

W kontekście VAT istotnym zagadnieniem jest mechanizm *split payment*. W lipcu 2019 r. ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasady określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. *split payment*) kwoty netto oraz podatku VAT, w wyniku którego płatność podatku VAT następuje na odrębny rachunek, a Partner Prywatny nie jest uprawniony do swobodnego dysponowania tymi środkami. Począwszy od 1 listopada 2019 r. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pod groźbą sankcji jest obowiązkowe. Dotyczy to transakcji spełniających następujące cechy:

- 1) dokonywanych pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty; oraz
- 2) obejmujących nabycie towarów lub usług wymienionych w projektowanym załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

Mechanizmu *split payment* nie stosuje się w przypadku dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu Umowy o PPP, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był stroną Umowy o PPP (tj. Partnerem Prywatnym, z którym Podmiot Publiczny zawarł Umowę o PPP, lub jednoosobową spółką Partnera Prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni, z którą Podmiot Publiczny zawarł Umowę o PPP, zob. art. 108a ust. 1e Ustawy o VAT).

Art. 13 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wskazuje jednoznacznie, że przepis art. 108a ust. 1e Ustawy o VAT – tj. wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu *split payment* – ma zastosowanie również do płatności realizowanych w zakresie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartych w wyniku Postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.9 Wpływ zobowiązań z Umowy o PPP na państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej

Tom II: Punkt 9.1 – Przygotowanie do zawarcia Umowy o PPP

Umowa o PPP podlega ocenie pod kątem wpływu na państwowy dług publiczny, na zasadach uregulowanych w art. 18a Ustawy o PPP oraz pod kątem klasyfikacji statystycznej.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy o PPP zobowiązania wynikające z Umów o PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy Partner Prywatny ponosi:

- większość ryzyka Budowy; oraz
- większość ryzyka Dostępności lub ryzyka popytu;

z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i Finansowanie przez Podmiot Publiczny oraz alokacja aktywów po Zakończeniu Umowy. Oznacza to,

że zobowiązania strony publicznej z Umowy o PPP (np. zobowiązanie Podmiotu Publicznego do płatności Opłaty za Dostępność) nie będą klasyfikowane jako tytuł dłużny w rozumieniu art. 72 Ustawy o Finansach Publicznych, jeżeli przesłanki określone w art. 18a ust. 1 Ustawy o PPP zostaną spełnione. Przy ocenie spełnienia tych przesłanek należy posłużyć się regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie Ryzyka.

W odniesieniu do metodologii statystycznego ujęcia Umów o PPP, stosowanego przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat uwzględnić należy stanowisko Eurostatu dotyczące kwestii wrażliwych z punktu widzenia ujęcia statystycznego Umowy o PPP wyrażone w treści opracowania pt. "A Guide to the Statistical Treatment of PPPs, September 2016" (Przewodnik EPEC).

W kwestii pozabilansowego charakteru Umów o PPP należy wskazać na pewną cechę rynku polskiego, polegającą na tym, że często zasadniczą motywacją realizacji Projektów PPP dla Podmiotów Publicznych jest brak wpływu zobowiązań z Umowy o PPP na dług publiczny, pomimo że model PPP nie zawsze jest adekwatny dla wybranego przez Podmiot Publiczny projektu (przede wszystkim z perspektywy celów, zakresu, założeń czy innych istotnych cech takiego projektu).



- Przewodnik EPEC, A Guide to the Statistical Treatment of PPPs, wrzesień 2016, https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf
- Nieoficjalne tłumaczenie ww. Przewodnika EPEC, kwiecień 2017 r., <https://www.ppp.gov.pl/sites/default/files/2025-08/PRZEWODNIK-PL-GUS-FINAL-7042017.pdf>
- Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gg-16-001>
- Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2019 edition, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c?t=1564735784000>
- Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2022 edition, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/16029761/KS-GQ-23-002-EN-N.pdf/77a75b07-61c3-7d34-5243-70d09bc00e44?version=3.0&t=1677163672121>

Część II

Umowa o PPP - część szczegółowa

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Preambuła i komparycja

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.1 – Podstawowe cechy modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 1.2 – Uczestnicy Projektów PPP

Tom II: Punkt 2.1 – Podstawy prawne współpracy w ramach PPP

Preambuła

Preambuła jest wstępną częścią Umowy, umieszczoną przed właściwymi jej postanowieniami. Preambuła przedstawia kontekst Projektu i ogólne cele Umowy o PPP. Treść preambuły może być istotna przy rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji postanowień Umowy.

Preambuła może zawierać deklaracje dotyczące długoterminowych celów strategicznych, które strony pragną realizować (np. cele zrównoważonego rozwoju).

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Zważywszy, że:

- 1) następujące zadania publiczne stanowią zadania własne Podmiotu Publicznego: [...];
- 2) celem Stron jest wspólna realizacja następującego Przedsięwzięcia: [...];
- 3) Podmiot Publiczny dokonał analizy wariantów realizacji Przedsięwzięcia jako optymalny, wybierając partnerstwo publiczno-prywatne;
- 4) w ocenie Podmiotu Publicznego współpraca z wybranym w trybie konkurencyjnym Partnerem Prywatnym, który dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, przyniesie Podmiotowi Publicznemu oraz społeczeństwu istotną korzyść;
- 5) Podmiot Publiczny przeprowadził Postępowanie w trybie [...];
- 6) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta [...];
- 7) istotne znaczenie dla Stron ma stabilność i trwałość Przedsięwzięcia.

Komparycja

Komparycja to wstępny element dokumentu Umowy, który zawiera szczegółowe oznaczenie stron Umowy, ich nazwę/firmę oraz formę prawną. Jest to kluczowy komponent formalny, który określa, kto dokładnie jest zobowiązany na podstawie umowy, co ma fundamentalne znaczenie w przypadku ewentualnych sporów. Informacje zawarte w komparycji powinny być precyzyjne i jednoznaczne, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień co do tożsamości stron.

Komparycja wskazuje również osoby reprezentujące strony. Należy zapewnić, aby osoby podpisujące Umowę o PPP w imieniu stron były do tego odpowiednio umocowane. Dokumenty

wykazujące umocowanie powinny stanowić załączniki do Umowy o PPP (w szczególności pełnomocnictwa).

Jednym z najpoważniejszych ryzyk związanych z błędną komparycją jest możliwość uznania umowy za nieważną. Jeśli strony nie są prawidłowo zidentyfikowane, sąd może uznać, że umowa nie spełnia podstawowych wymogów formalnych i w rezultacie jest nieważna. Przykładem może być sytuacja, gdy w komparycji błędnie podano firmę lub formę prawną jednej ze stron, co może prowadzić do wniosku, że Umowa nie została zawarta przez odpowiednie podmioty.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Przykład 1:

UMOWA

zawarta w dniu [...] roku w [...] pomiędzy:

Gminą [...] z siedzibą w [...], przy ul. [...], [...], NIP [...], REGON [...]:

reprezentowaną przez [...] – [Wójt / Burmistrz / Prezydenta Miasta],

przy kontrasygnacie [...] – **skarbnika Gminy [...]**

a

[...] spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...], przy ul. [...], [...], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...], NIP [...], REGON [...], reprezentowaną przez:

[...] – [funkcja]

Przykład 2:

UMOWA

zawarta w dniu [...] roku w [...] pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra [...], adres: Ministerstwo [...], ul. [...], [...], NIP: [...] w imieniu, którego działa [...] - dyrektor departamentu [...], na podstawie pełnomocnictwa nr [...] z [...], którego kopia stanowi załącznik do Umowy

a

[...] spółka akcyjną z siedzibą w [...], przy ul. [...], [...], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...], o kapitale zakładowym w wysokości [...] opłaconym w całości, NIP [...], REGON [...], reprezentowaną przez:

[...] – [funkcja]

UWAGA



W przypadku Umów o PPP, które podpisywane będą przez strony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego datą zawarcia takiej Umowy będzie data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron. W takim przypadku w komparycji Umowy można nie umieszczać informacji o dacie jej zawarcia.

UWAGA



Zgodnie z ustawami regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (tj. Ustawą o Samorządzie Gminnym, ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa), jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Brak kontrasygnaty nie czyni czynności prawnej (oświadczenia woli) nieważną, lecz pozbawia ją skuteczności, co oznacza, że może ona ulec konwalidacji poprzez późniejsze udzielenie kontrasygnaty. Tym samym, Umowa o PPP zawarta bez kontrasygnaty skarbnika nie wywołuje skutków prawnych (nie jest egzekwowalna), jednakże po złożeniu kontrasygnaty przez skarbnika przekształci się w Umowę, na podstawie której strony będą mogły skutecznie dochodzić swoich praw i obowiązków. W przypadku rozpoczęcia wykonywania Umowy o PPP i późniejszej kontrasygnaty Umowy o PPP przez skarbnika, wykonane prace będą traktowane jako prace wykonane w oparciu o wiążącą i egzekwowalną przez strony Umowę (za które należne jest wynagrodzenie) – kontrasygnata ma skutek wsteczny (*ex tunc*).

ŹRÓDŁA INFORMACJI



<https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow>

1.2 Definicje i Interpretacja

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.1 – Podstawowe cechy modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 1.2 – Uczestnicy Projektów PPP

Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom II: Punkt 6.5.4 – Istotne postanowienia Umowy o PPP

Definicje

Podczas przygotowywania projektu Umowy o PPP należy zwrócić uwagę na konieczność precyzyjnego zdefiniowania wykorzystywanych w Umowie pojęć i ich konsekwentne stosowanie w treści Umowy o PPP. Wszystkie definicje mogą zostać zawarte jako pierwszy punkt Umowy o PPP (po preambule i komparycji), albo zostać zebrane w załączniku do Umowy o PPP.

W Postępowaniach PPP często uczestniczą Partnerzy Prywatni zagraniczni, którzy na swoje potrzeby wewnętrzne oraz w komunikacji między stronami i zagranicznymi Instytucjami Finansującymi przy Zarządzaniu Umową o PPP posługują się tłumaczeniem Umowy o PPP. Poniżej przedstawiamy kluczowe terminy, które z reguły zawierane są w Umowach o PPP wraz z tłumaczeniami na język angielski.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA 		
Akt Wandalizmu (Act of Vandalism)	Awaria (Failure)	Brak Dostępności (Lack of Availability)
Decyzja Środowiskowa (Environmental Permit)	Decyzje Administracyjne (Administrative Decisions)	Dokumentacja Powykonawcza (As-Built Documentation)
Dokumentacja Projektowa (Design Documentation)	Dokumentacja Wykonawcza (Detailed Design Documentation)	Dostępność (Availability)
Finansowanie (Financing)	Harmonogram (Schedule)	Infrastruktura Publiczna (Public Infrastructure)
Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Key Performance Indicators / KPIs)	Kwota Rozliczenia (Settlement Amount)	Mechanizm Wynagradzania (Payment Mechanism)
Model Finansowy (Financial Model)	Nakłady Inwestycyjne (Capital Expenditures)	Nieruchomość (Property)
Niezależny Inżynier (Independent Engineer)	Odbiór (Acceptance)	Okres Budowy (Construction Period)
Okres Projektowania (Design Period)	Okres Utrzymania (Maintenance Period)	Oplata za Finansowanie (Financing Fee)

Opłata za Nakłady Inwestycyjne (Capital Expenditures Fee)	Opłata za Rozłożenie w Czasie (Deferred Payment Fee)	Opłata za Utrzymanie (Maintenance Fee)
Partner Prywatny (Private Partner)	Podmiot Publiczny (Public Entity)	Polecenie Zmiany (Change Order)
Pozwolenie Na Budowę (Building Permit)	Pozwolenie Na Użytkowanie (Use Permit)	Program Funkcjonalno-Użytkowy (Functional and Utility Programme)
Projekt Budowlany (Construction Design)	Przedsięwzięcie (Project)	Przypadek Dostosowania (Adjustment Event)
Przypadek Kompensacyjny (Compensation Event)	Punkt Karny (Penalty Point)	Roboty Budowlane (Construction Works)
Siła Wyższa (Force Majeure)	Standardy Utrzymania (Maintenance Standards)	Teren Robót (Construction Site)
Umowa Bezpośrednia (Direct Agreement)	Utrzymanie (Maintenance)	Wada (Defect)
Wada Istotna (Material Defect)	Wkład Własny (Contribution)	Wynagrodzenie (Remuneration)
Zabezpieczenie Należytego Wykonania (Performance Security)	Zmiana Prawa (Change in Law)	Znalezisko (Finding)
Organ Administracji (Administration Authority)	Procedura Rozwiązywania Sporów (Dispute Resolution Procedure)	Protokół Ostatecznego Zakończenia (Final Completion Certificate)
Protokół Wstępnego Zakończenia Initial Completion Certificate	SWZ/Specyfikacja Warunków Zamówienia (ToR/Terms of Reference)	Zespół Niezależnych Ekspertów (Dispute Adjudication Board)

Interpretacja

Umowa o PPP powinna określać podstawowe zasady interpretacji, jak również określać hierarchię dokumentów składających się na Umowę o PPP, tj. który dokument będzie miał rozstrzygające znaczenie w przypadku rozbieżności.

W ramach klauzuli poświęconej zasadom interpretacji często wskazuje się zasadę, zgodnie z którą Podmiot Publiczny odpowiada jedynie za ryzyka wyraźnie mu przypisane w Umowie o PPP.

Zasady interpretacji określone w Umowie o PPP będą istotne nie tylko z perspektywy jej wykonywania, ale również w przypadku sporu rozstrzyganego przez sąd.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Do interpretacji postanowień Umowy zastosowanie będą miały następujące zasady, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej:

- 1) Odniesienia do części, punktów, ustępów lub załączników oznaczają odniesienia do części, punktów, ustępów lub załączników Umowy. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
- 2) Zastosowanie w Umowie tytułów poszczególnych części, punktów, ustępów oraz załączników ma na celu jedynie ułatwienie w posługiwaniu się Umową i intencją stron jest, aby pozostały bez wpływu na jej interpretację.
- 3) Umowa, załączniki do Umowy, Oferta oraz SWZ będą traktowane jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające i objaśniające. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, strony przyjmują następujący porządek ich pierwszeństwa:
 - Umowa;
 - załączniki do Umowy bez Oferty;
 - Oferta;
 - SWZ wraz z odpowiedziami na pytania wykonawców oraz wyjaśnieniami Podmiotu Publicznego.
- 4) Słowa użyte w liczbie pojedynczej oznaczają również liczbę mnogą oraz słowa użyte w liczbie mnogiej oznaczają również liczbę pojedynczą, o ile z kontekstu nie wynika wyraźnie inaczej.
- 5) Zobowiązania każdej ze stron wykonywane są na jej koszt i ryzyko, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
- 6) Ilekroć w Umowie mowa jest o powzięciu przez Partnera Prywatnego wiedzy lub uzyskaniu informacji na temat określonych okoliczności przyjmuje się, że Partner Prywatny powziął wiedzę lub uzyskał informację o wystąpieniu takich okoliczności w chwili, gdy jakkolwiek osoba wykonująca na rzecz Partnera Prywatnego czynności związane z tymi okolicznościami lub uprawniona do reprezentacji Partnera Prywatnego powzięła lub mogła powziąć wiedzę o wystąpieniu takich okoliczności.
- 7) Ilekroć w Umowie użyte jest sformułowanie "powinien" w jakiegokolwiek formie lub rodzaju, oznacza to zobowiązanie do określonego świadczenia.
- 8) Podmiot Publiczny odpowiada jedynie za ryzyka wyraźnie mu przypisane w Umowie.

UWAGA



W Umowach o PPP, w których porządek pierwszeństwa dokumentów uwzględnia nadrzędność Umowy o PPP, Podmiot Publiczny przed podpisaniem Umowy o PPP zobowiązany będzie do włączenia do ostatecznej treści Umowy o PPP w sposób bardzo skrupulatny wszystkich odpowiedzi na pytania do SWZ, modyfikujących Umowę o PPP oraz treść Oferty. Może być to przedmiotem dyskusji i sporów pomiędzy stronami.

W przypadku, gdy Podmiot Publiczny nie sporządził tekstu jednolitego Umowy o PPP można przyjąć następującą hierarchię dokumentów: "Umowa, załączniki do Umowy, Oferta oraz SWZ będą traktowane jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające i objaśniające. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, strony przyjmują następujący porządek ich pierwszeństwa:

- Oferta;
- SWZ wraz z odpowiedziami na pytania wykonawców oraz wyjaśnieniami Podmiotu Publicznego;
- Umowa;
- załączniki do Umowy bez Oferty".

Należy mieć jednak na względzie, że w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania, może ono prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy tekstem głównym Umowy o PPP, a dokumentami do niego załączonymi (np. Oferta, SWZ). Dlatego też sporządzenie tekstu jednolitego Umowy o PPP przed jej podpisaniem jest rozwiązaniem rekomendowanym.

1.3 Przedmiot Umowy. Ogólne zobowiązania stron

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.1 – Podstawowe cechy modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 1.2 – Uczestnicy Projektów PPP

Tom I: Część I Punkt 1.4 – Podział ryzyka

Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom I: Część II Punkt 1.1 – Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego oraz wstępne określenie źródeł ich finansowania

Tom II: Punkt 2.1 – Podstawy prawne współpracy w ramach PPP

Tom II: Punkt 6.5.4 – Istotne postanowienia Umowy o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.6 – Umowa Bezpośrednia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia za Wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a Podmiot Publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

W sekcji dotyczącej przedmiotu Umowy opisuje się podstawowe zobowiązania stron tj. zobowiązanie Partnera Prywatnego do wykonania Prac Projektowych, Budowy, Utrzymania i ich sfinansowania w zamian za zapłatę Wynagrodzenia.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Na podstawie Umowy Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z postanowieniami Umowy, a Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zapłaty Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia oraz do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w sposób przewidziany w Umowie, w szczególności poprzez wniesienie wkładu w postaci [...] z przeznaczeniem na cele wynikające z Umowy.
- 2) Partner Prywatny odpowiedzialny jest za należyte wykonanie Prac Projektowych oraz Robót. Zakres Prac Projektowych oraz Robót wymaganych do realizacji Budowy został określony w załączniku pt. PFU. Odpowiedzialność Podmiotu Publicznego w zakresie Prac Projektowych oraz Robót ograniczona jest wyłącznie do przypadków wyraźnie w Umowie określonych.
- 3) Partner Prywatny odpowiedzialny jest za zapewnienie Standardów Utrzymania oraz Dostępności. Zakres czynności Partnera Prywatnego przewidzianych w ramach Utrzymania i Dostępności oraz sankcje za ich niedotrzymanie określa załącznik pt. Standardy Utrzymania. Odpowiedzialność Podmiotu Publicznego w zakresie Utrzymania i Dostępności ograniczona jest wyłącznie do przypadków wyraźnie w Umowie określonych.
- 4) Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia niezależnie od faktycznego wykorzystania Infrastruktury Publicznej przez Użytkowników.
- 5) Zwrot Infrastruktury Publicznej nastąpi w sposób zgodny z załącznikiem pt. Wymagania przy zwrocie Infrastruktury Publicznej.

UWAGA



Jako przykłady niewłaściwego opisywania przedmiotu Umowy można wskazać:

- niejasne postanowienia PFU lub zbyt ogólne PFU, na podstawie którego Partner Prywatny nie jest w stanie ustalić zakresu jego zobowiązań i wymogów Podmiotu Publicznego;
- zakres techniczny niedostosowany do specyfiki projektu oraz rzeczywistych potrzeb Podmiotu Publicznego (np. przesadnie wysokie wymagania Podmiotu Publicznego co do standardu budynków komunalnych);
- niejasny podział ryzyk (w szczególności, gdy np. zobowiązania w zakresie utrzymania są dzielone pomiędzy strony).

UWAGA



Przedmiotem Umowy o PPP nie jest Infrastruktura Publiczna tylko zobowiązania stron. W Umowach o PPP często spotyka się nieprawidłowe opisywanie przedmiotu Umowy poprzez odniesienie do aktywa, które jest wytwarzane w ramach Przedsięwzięcia.

1.4 Okres Obowiązywania Umowy

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom II: Punkt 9.1 – Przygotowanie do zawarcia Umowy o PPP

Tom II: Punkt 9.2 – Zamknięcie Finansowe

Tom IV: Część II Punkt 2.6.3 – Spełnienie warunków wejścia w życie Umowy o PPP

Podmiot Publiczny w Umowie o PPP określa Okres Obowiązywania Umowy w oparciu o wyniki Oceny Efektywności, w tym badań rynkowych (zob. Część I Punkt 2.5 Okres Obowiązywania Umowy o PPP). Na Okres Obowiązywania Umowy o PPP składa się Okres Projektowania, Okres Budowy oraz Okres Utrzymania.

W ramach formułowania postanowień Umowy o PPP dotyczących Okresu Obowiązywania Umowy, należy wziąć pod uwagę skutki dla Okresu Obowiązywania Umowy w przypadku, gdy dochodzi do opóźnień czy zwłoki w zakończeniu Budowy. Może do tego dojść z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego (np. polecenie zmiany), Partnera Prywatnego (np. zwłoka) lub z innych przyczyn niezależnych od stron (np. przypadek kompensacyjny, czy siła wyższa).

Warto zaznaczyć, że w przypadku zwłoki w zakończeniu Budowy (tj. z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego) najczęściej naliczana jest Partnerowi Prywatnemu kara umowna za zwłokę w realizacji Robót. Jeżeli do takiego wydłużenia dochodzi z innych przyczyn (za które nie odpowiada Partner Prywatny), to kara taka nie jest nakładana.

DOBRE PRAKTYKI



Wysokość kary umownej powinna zostać określona w sposób proporcjonalny i celowościowy, tak aby spełniała funkcję prewencyjną i kompensacyjną, a nie wyłącznie represyjną. Jednocześnie nie może być nadmierna, ponieważ będzie to skutkować wyższą ceną ofertową (Partner Prywatny, wyliczając cenę będzie, przyjmować określone założenia co do ewentualnych kar umownych) oraz finalnie może skutkować niemożnością dochodzenia kar umownych w pełnej wysokości na skutek – w przypadku sporu – zastosowania przez sąd instytucji miarkowania kary.

W przypadku przedłużenia Okresu Budowy, Okres Obowiązywania Umowy ulega również wydłużeniu (o czas wynikający z przedłużenia Budowy), przy czym Okres Utrzymania pozostaje bez zmian.

Koszty związane z przyczynami wydłużenia są rozliczane jednorazowo między stronami (np. rozliczenie przypadku kompensacyjnego). Naliczane są ewentualne kary umowne, a Opłata za Dostępność pozostaje w niezmienionej wysokości.

W przypadku, gdy przedłużenie Okresu Budowy nie jest spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Partnera Prywatnego, możliwe jest podejście, w którym Okres Obowiązywania Umowy nie ulegnie wydłużeniu, natomiast strony dokonają aktualizacji Modelu Finansowego. Oznacza to, że Partner Prywatny otrzyma wyższą cykliczną Opłatę za Dostępność, jednakże w krótszym okresie.

UWAGA



Wybór określonego podejścia zależeć będzie od oceny konkretnych potrzeb i możliwości finansowych Podmiotu Publicznego oraz konkretnego Przedsięwzięcia.

UWAGA



Możliwe jest podejście, w którym Partner Prywatny nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, lecz Okres Obowiązywania Umowy nie ulega wydłużeniu, Okres Utrzymania jest proporcjonalnie skrócony, a wysokość Opłaty za Dostępność pozostaje w niezmienionej wysokości. Tym samym konsekwencją finansową dla Partnera Prywatnego jest to, że suma Opłat za Dostępność jest niższa.

Regulacje dotyczące Okresu Obowiązywania Umowy czasem, w celu uniknięcia wątpliwości, obejmują postanowienia dotyczące tych części Umowy, które będą obowiązywać po jej wygaśnięciu (między innymi na skutek jej rozwiązania przed upływem Okresu Obowiązywania Umowy). Poniżej przedstawiono przykład takiej regulacji.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Bez względu na rozwiązanie Umowy, postanowienia punktów:

- 1) gwarancja jakości/rękojmia (o ile będą miały zastosowanie);
- 2) kary umowne;
- 3) procedura rozwiązywania sporów;
- 4) poufność informacji;
- 5) prawa własności intelektualnej;
- 6) dane osobowe;

pozostają w mocy oraz te postanowienia lub część postanowień Umowy, których zastosowanie jest niezbędne w celu należytego wykonania przez Strony zobowiązań określonych w postanowieniach Umowy wskazanych w lit. (1) – (6) powyżej oraz interpretacji postanowień Umowy wskazanych w lit. (1) - (6) powyżej.

Umowa o PPP może zostać zawarta pod warunkami zawieszającymi, co będzie oznaczać, że okres Umowy o PPP zacznie biec dopiero po spełnieniu się tych warunków. W takim przypadku Umowa o PPP powinna określić termin, do którego warunki zawieszające powinny zostać spełnione.

Jako przykłady warunków wejścia w życie Umowy o PPP lub jej części można wskazać:

- doprowadzenie do Zamknięcia Finansowego przez Partnera Prywatnego;
- zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Partnera Prywatnego;
- zawarcie Umowy Bezpośredniej;
- pozytywny wynik inwentaryzacji lub audytu technicznego, przeprowadzonego po zawarciu Umowy o PPP (jeżeli nie zostały przeprowadzone przed złożeniem ofert);
- udzielenie zabezpieczeń przez Podmiot Publiczny, o ile zostały przewidziane w Umowie o PPP;
- złożenie oświadczeń lub dokumentów określonych w Umowie o PPP (np. opinia w przedmiocie zgodności Umowy o PPP z prawem, wydana na żądanie Instytucji Finansujących);
- zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu Hybrydowego.

Umowy o PPP określają, jakie konkretnie ich postanowienia wchodzi w życie po spełnieniu ww. warunków, a jakie obowiązują z momentem Zamknięcia Komercyjnego.

1.5 Oświadczenia stron

Oświadczenia stron powinny obejmować standardowe klauzule mające na celu zapewnienie, że Umowa została zawarta i podpisana przez strony w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do nich.

Partner Prywatny składa najczęściej oświadczenia co do możliwości finansowych i technicznych realizacji Przedsięwzięcia, braku przesłanek upadłości czy likwidacji Spółki Projektowej, oraz w zakresie prawidłowej reprezentacji Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny składa najczęściej oświadczenia dotyczące stanu składników majątkowych wnoszonych do Przedsięwzięcia (Nieruchomości) oraz przekazywanych informacji lub dokumentów wiążących Partnera Prywatnego (np. posiadana przez Podmiot Publiczny Dokumentacja Projektowa lub badania gruntowe).

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Podmiot Publiczny oświadcza, że w dacie zawarcia Umowy o PPP:

- 1) realizacja Przedsięwzięcia jest zadaniem własnym Podmiotu Publicznego;
- 2) Podmiot Publiczny zabezpieczył środki na pokrycie zobowiązań Podmiotu Publicznego z tytułu zapłaty Wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu w całym Okresie Utrzymania Infrastruktury Publicznej, zamieszczając planowane limity wydatków i zobowiązań z tego tytułu w wieloletniej prognozie finansowej Podmiotu Publicznego; *[Uwaga: niniejsze oświadczenie składać będą JST]*
- 3) osoby reprezentujące Podmiot Publiczny posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać zawarte przez Podmiot Publiczny na podstawie Umowy;
- 4) Podmiot Publiczny uzyskał wszystkie zatwierdzenia, uchwały, zgody i upoważnienia, wymagane zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi przepisami lub regulaminami Podmiotu Publicznego lub na innej podstawie w celu należytego zawarcia i wykonania Umowy;
- 5) Umowa została zawarta i podpisana przez Podmiot Publiczny w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Podmiotu Publicznego wykonalne w stosunku do niego;
- 6) nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne, arbitrażowe dotyczące Podmiotu Publicznego, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy i Podmiot Publiczny nie ma wiedzy o istnieniu podstaw do wystąpienia takich postępowań w przyszłości;
- 7) posiada prawo do dysponowania Nieruchomością, na której posadowiona będzie Infrastruktura Publiczna;
- 8) Nieruchomość jest wolna od praw lub roszczeń osób trzecich, których dochodzenie, zabezpieczenie lub egzekucja mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Partnerowi Prywatnemu korzystanie z Nieruchomości w sposób niezbędny do wykonania Umowy;
- 9) nie zostały na Nieruchomości rozpoznane takie zanieczyszczenia, czy też działania, zdarzenia, zaniechania, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
- 10) nie rozpoznano w obrębie Nieruchomości żadnych Złazisk;
- 11) w obrębie Nieruchomości nie znajduje się żadna podziemna infrastruktura techniczna, kolizyjna z Budową, poza wykazaną w dokumentach Podmiotu Publicznego;
- 12) dokumenty i informacje zawarte w dokumentach Podmiotu Publicznego są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Partner Prywatny oświadcza, że w dacie zawarcia Umowy o PPP:

- 1) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa;

- 2) wykonuje swoją działalność zgodnie z przepisami prawa, w szczególności posiada zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia, jeżeli są niezbędne do wykonania Umowy;
- 3) osoby reprezentujące Partnera Prywatnego posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonywania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać zawarte przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy;
- 4) Umowa została zawarta i podpisana przez Partnera Prywatnego w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Partnera Prywatnego wykonalne w stosunku do niego;
- 5) zawarcie i wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nie stoi w sprzeczności ani nie skutkuje naruszeniem postanowień aktów założycielskich Partnera Prywatnego, umów, których Partner Prywatny jest stroną, ani orzeczeń sądów lub sądów arbitrażowych lub innego organu, lub Decyzji Administracyjnych albo innych aktów Organów Administracji, którym Partner Prywatny podlega;
- 6) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz będzie dysponować środkami finansowymi i osobami zdolnymi do wykonania Umowy;
- 7) nie złożono żadnego wniosku, nie podjęto żadnej uchwały ani nie zwołano żadnego zgromadzenia w celu likwidacji lub upadłości Partnera Prywatnego lub Wspólników Partnera Prywatnego, w szczególności nie powołano syndyka, likwidatora ani innej osoby działającej w podobnym charakterze w odniesieniu do całości bądź jakiegokolwiek części majątku Partnera Prywatnego lub wspólników Partnera Prywatnego oraz wedle wiedzy Partnera Prywatnego nie są podejmowane żadne kroki w celu powołania takiej osoby;
- 8) Partner Prywatny oraz wspólnicy Partnera Prywatnego nie są niewypłacalni ani niezdolni do wykonywania swych zobowiązań w terminie ich wymagalności i nie zachodzi ryzyko ich niewypłacalności;
- 9) nie toczą się przeciwko niemu, członkom jego organów ani przeciwko jego wspólnikom, ani z ich udziałem postępowania sądowe ani administracyjne, arbitrażowe, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy i Partner Prywatny nie ma wiedzy o istnieniu podstaw do wystąpienia takich postępowań w przyszłości.

UWAGA



W zależności od specyfiki Projektu PPP (np. sektor, rynek regulowany, otoczenie prawne) mogą być wymagane dodatkowe oświadczenia stron. Przykładem takich oświadczeń mogą być zapewnienia wynikające z przepisów art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Strony ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość swoich oświadczeń. W przypadku powstania szkody na skutek niezgodnego z prawdą oświadczenia, strona, które je złożyła, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Oznacza to,

że strona dochodząca odszkodowania będzie musiała wykazać szkodę, którą poniosła na skutek złożenia przez drugą stronę fałszywego oświadczenia.

W Umowie o PPP złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym może stanowić przypadek kompensacyjny. Warto również nadmienić, że oświadczenia Podmiotu Publicznego powinny być oświadczeniami "stanowczymi" a nie oświadczeniami "według najlepszej wiedzy Podmiotu Publicznego", z tego względu, że Partner Prywatny, składając ofertę, polegać będzie na oświadczeniach Podmiotu Publicznego i ich niezgodność ze stanem faktycznym powinna umożliwiać podniesienie przez Partnera Prywatnego stosownego roszczenia.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny oświadcza, według swojej najlepszej wiedzy, że na Nieruchomości nie znajdują się zanieczyszczenia, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Powyższe stanowi niewłaściwą praktykę w zakresie oświadczeń Podmiotu Publicznego. Jeżeli w toku realizacji Umowy okazałoby się, że na Nieruchomości znajdują się jednak zanieczyszczenia, Podmiot Publiczny przy tak skonstruowanym oświadczeniu mógłby zasłaniać się brakiem wiedzy. W takim przypadku Partner Prywatny w celu uzyskania odszkodowania od Podmiotu Publicznego musiałby nie tylko wykazać szkodę jaką poniósł w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia, ale również wykazać, że Podmiot Publiczny wiedział o zanieczyszczeniu.

1.6 Wkład Własny

Jeżeli Podmiot Publiczny lub Partner Prywatny wnoszą do Przedsięwzięcia wkłady własne w rozumieniu Ustawy o PPP, wówczas Umowa o PPP zawiera postanowienia regulujące ich wniesienie do Przedsięwzięcia oraz zasady korzystania z nich przez Partnera Prywatnego.

Wkład własny jest wnoszony do Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny w jednej z form przewidzianych w przepisie art. 9 ust. 1 Ustawy o PPP, tj. w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy, przy czym Umowa o PPP może również stanowić samodzielną podstawę do udostępnienia wkładu przez Podmiot Publiczny (najczęściej wkładem będzie Nieruchomość lub dokumentacja projektowa Podmiotu Publicznego).

Z zasady zawieranie odrębnej umowy w celu umożliwienia korzystania ze składnika majątkowego przez Partnera Prywatnego nie będzie uzasadnione, o ile nie przesądzą o tym szczególne wymagania. Jeżeli jednak wniesienie wkładu nastąpi na podstawie odrębnej umowy, powinna ona przewidywać automatyczne rozwiązanie bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony w przypadku wygaśnięcia Umowy o PPP.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o PPP po zakończeniu czasu trwania Umowy o PPP, Partner Prywatny przekazuje Podmiotowi Publicznemu składnik majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji Przedsięwzięcia, chyba że Umowa o PPP stanowi inaczej.

UWAGA



Udostępnienie wkładu na podstawie odrębnej umowy może wiązać się z następującym ryzykiem:

- powstaniem sprzeczności pomiędzy treścią Umowy o PPP, a odrębną umową;
- różnicą pomiędzy Okresem Obowiązywania Umowy, a okresem obowiązywania umowy odrębnej.

UWAGA



W celu udostępnienia Partnerowi Prywatnemu wkładu dla celów należytego wykonania Umowy o PPP nie jest konieczne zawieranie umowy odrębnej od Umowy o PPP. Większość wytycznych międzynarodowych oraz wzorów umów stosowanych w innych jurysdykcjach również nie przewiduje odrębnych umów dotyczących udostępniania wkładu dla celów realizacji Przedsięwzięcia PPP.

1.7 Udostępnienie Nieruchomości

Co do zasady, w przypadku Projektów PPP Nieruchomość udostępniana jest przez Podmiot Publiczny, choć regulacje Ustawy o PPP nie wykluczają realizacji Projektu PPP na Nieruchomości stanowiącej od początku własność Partnera Prywatnego (sytuacje takie są jednak bardzo rzadkie, dlatego nie podlegają szerszej analizie w Wytycznych).

Umowa o PPP powinna określać warunki wydania Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny oraz zakres korzystania z Nieruchomości przez Partnera Prywatnego.

Z uwagi na fakt, iż Partner Prywatny będzie realizował inwestycję na cudzym gruncie, Umowa o PPP powinna zawierać również upoważnienie udzielone przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane (chyba, że dochodzi do sprzedaży Nieruchomości – w takim przypadku takie oświadczenie oczywiście jest zbędne).

Nieruchomość, jako składnik majątkowy będący przeważnie własnością Podmiotu Publicznego, jest udostępniana Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Umowy o PPP.

Wyjątkowo, w warunkach specyficznych dla danego Przedsięwzięcia, niektóre Umowy o PPP mogą przewidywać, że korzystanie z Nieruchomości nastąpi na podstawie odrębnej umowy nazwanej lub nienazwanej, określającej warunki udostępnienia Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu. Takie rozwiązanie dotyczy jednak sytuacji, w której Podmiot Publiczny wnosi do Przedsięwzięcia wkład własny w postaci Nieruchomości lub innego składnika majątkowego (zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PPP).

PRZYKŁAD



Jeżeli Podmiot Publiczny zdecyduje się wnieść wkład własny w postaci Nieruchomości w drodze sprzedaży Nieruchomości, to niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w której to umowie strony powinny ustalić dodatkowo zasady odkupu Nieruchomości przez Podmiot Publiczny (jeżeli nie przewidziano w Umowie o PPP, że Nieruchomość pozostaje w majątku Partnera Prywatnego). Forma aktu notarialnego jest formą wymaganą do sprzedaży Nieruchomości.

1.8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP Tom I-IV



Tom II: Punkt 9.1 – Przygotowanie do zawarcia Umowy o PPP

Umowa o PPP może zawierać klauzule dotyczące zabezpieczenia należytego jej wykonania. Zabezpieczenie należytego wykonania służy zabezpieczeniu i ewentualnemu zaspokojeniu roszczeń Podmiotu Publicznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego, a w szczególności roszczeń Podmiotu Publicznego wobec Partnera Prywatnego o zapłatę wszelkich kwot i kar umownych przewidzianych w Umowie.

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem Umowy o PPP, chyba że Podmiot Publiczny określi inny termin w dokumentach zamówienia. Wniesienie zabezpieczenia przed zawarciem Umowy o PPP jest szczególnie zasadne, gdy Partner Prywatny jest zobowiązany do osiągnięcia Zamknięcia Finansowego do określonej daty, a niewywiązanie się z tego zobowiązania w terminie będzie uprawniać Podmiot Publiczny do wypowiedzenia Umowy o PPP oraz żądania od Partnera Prywatnego kary umownej z tego tytułu.

UWAGA



Ustawa o PPP wyłącza obowiązek stosowania wybranych przepisów Ustawy PZP dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o PPP (art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453). Możliwość rezygnacji Podmiotu Publicznego z zastosowania zabezpieczenia wynika z tego, że Partner Prywatny nie otrzymuje jednorazowej płatności za Prace Projektowe i Roboty, a pierwszą Opłatę za Dostępność otrzymuje dopiero po zakończeniu Budowy. Poza tym Podmiot Publiczny ma możliwość pomniejszania Wynagrodzenia Partnera Prywatnego z tytułu braku Dostępności lub o kary umowne z powodu nieosiągnięcia wymaganej jakości Utrzymania, na bieżąco.

W praktyce jednak Umowy o PPP uwzględniają konieczność przedłożenia przez Partnera Prywatnego zabezpieczenia należytego wykonania w odniesieniu do Prac Projektowych oraz Robót.

Zabezpieczenie przewidywane Umową o PPP powinno być proporcjonalne i adekwatne również dla danego etapu Projektu PPP, aby niepotrzebnie nie podnosić jego kosztów. Dlatego też z uwagi na inną wartość zobowiązań Partnera Prywatnego w zależności od zakresu zobowiązań Partnera

Prywatnego na danym etapie, Umowy o PPP przewidują odrębne zabezpieczenia należytego wykonania o różnych wartościach w danych okresach Umowy o PPP albo zmianę wysokości zabezpieczenia w czasie trwania Umowy o PPP w zależności od okresu.

Co prawda w przepisie art. 450 Ustawy PZP przewidziane zostały różne dopuszczalne formy zabezpieczenia, jednakże w Umowach o PPP zabezpieczenie przewidywane jest zazwyczaj w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W przypadku gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, Umowa o PPP powinna przewidywać obowiązek przedłożenia gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie.

Umowa o PPP powinna wymagać, aby gwarancja podlegała prawu polskiemu (co nie wyklucza, aby gwarant był podmiotem zagranicznym).

Należy mieć na względzie, że pozyskanie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na długi okres może nie być efektywne czy nawet możliwe. Umowa o PPP powinna przewidywać taką okoliczność i umożliwić Partnerowi Prywatnemu przedkładanie gwarancji na krótszy okres przy jednoczesnym zobowiązaniu Partnera Prywatnego do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu nowej gwarancji w uzgodnionym terminie przed wygaśnięciem poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o PPP.

Wymaganie zabezpieczenia na etapie Utrzymania nie jest potrzebne i nie powinno być stosowane, ponieważ kary umowne z tytułu nieosiągnięcia KPI będą potrącane z Opłaty za Dostępność płatnej Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny. Wyjątkiem, kiedy wymaganie zabezpieczenia na etapie Utrzymania będzie zasadne, jest sytuacja, w której infrastruktura jest własnością Podmiotu Publicznego oraz zakres Utrzymania jest ograniczony (np. do tzw. *soft maintenance*) i Partner Prywatny udzielił gwarancji jakości/rękojmi na wytworzoną infrastrukturę. W takiej sytuacji Podmiot Publiczny może wymagać również zabezpieczenia pokrywającego okres gwarancji jakości/rękojmi.

DOBRE PRAKTYKI



Wysokość zabezpieczenia na etapie Prac Projektowych powinna odpowiadać wartości Prac Projektowych i tym samym powinna być niższa niż zabezpieczenia na etapie Robót. Wartość zabezpieczenia (np. 5% wartości Prac Projektowych) powinna odzwierciedlać aktualne na moment Zamknięcia Komercyjnego warunki rynkowe.

Jeżeli w Umowie o PPP przewidziana została gwarancja jakości/rękojmi w części Okresu Utrzymania, wówczas wysokość zabezpieczenia powinna zostać obniżona w sposób adekwatny do wartości ewentualnych roszczeń.

Jeżeli Umowa o PPP nie przewiduje gwarancji jakości/rękojmi (z uwagi na możliwość potrącania Punktów Karnych z tytułu nienależytego Utrzymania), zabezpieczenie zostaje zwrócone po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Warto zwrócić uwagę, że nadmierne wymagania co do wysokości zabezpieczeń będą miały odzwierciedlenie w cenach ofertowych, ponieważ Partnerzy Prywatni przenoszą *de facto* koszt zabezpieczenia na Podmiot Publiczny.

Podmiot Publiczny może również wymagać, aby – w przypadku gwarancji – Instytucja Finansująca posiadała określony rating finansowy przyznawany przez agencje ratingowe, np. S&P, Fitch

lub Moody's. Nie wszystkie instytucje udzielające gwarancji (zwłaszcza gwarancji ubezpieczeniowych) mają ratingi, w związku z czym należy również dopuścić gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydawane przez instytucje niemające ratingu, jednakże za uprzednim zaakceptowaniem takiej instytucji przez Podmiot Publiczny.

Ze względu na abstrakcyjny charakter gwarancji, Podmiot Publiczny powinien dopuszczać gwarancje bankowe wystawiane przez Instytucje Finansujące na zlecenie nie tylko Partnera Prywatnego, ale również jego Podwykonawców (oczywiście z zastrzeżeniem, że Podmiot Publiczny będzie beneficjentem takiej gwarancji).

Należy pamiętać, że maksymalną wysokość zabezpieczenia oraz zasady jego zwrotu mogą być dowolnie uregulowane w Umowie o PPP, bowiem zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP, w przypadku Projektu PPP nie znajdują zastosowania art. 452 i 453 Ustawy PZP, które regulują te kwestie. Ponadto, Podmiot Publiczny może wcale nie wymagać przedłożenia zabezpieczenia.

DOBRE PRAKTYKI



Dobrą Praktyką jest uwzględnianie właściwości Projektu PPP przy formułowaniu oczekiwań co do form zabezpieczeń należytego wykonania Umowy o PPP.

Niewskazane jest zatem wymaganie od Partnera Prywatnego będącego Spółką Projektową przedkładania gwarancji wystawionej przez spółkę-matkę Partnera Prywatnego. Takie podejście jest sprzeczne z ideą realizacji projektów w modelu *project finance* (więcej na temat *project finance* w Części II Punkcie 1.9 Finansowanie Przedsięwzięcia). Należy wskazać, że poza zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, które będzie zabezpieczać część roszczeń Podmiotu Publicznego oraz możliwością potrącania z Opłaty za Dostępność, standardem jest, że sama Spółka Projektowa dysponuje zabezpieczeniami udzielonymi przez jej Podwykonawców (którymi często są spółki z grupy). Ponadto, w projektach zawierających finansowanie dłużne Projekt PPP jest na bieżąco kontrolowany przez Instytucje Finansujące (działające przez doradcę technicznego Instytucji Finansujących).

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Przykładowe postanowienia dotyczące zmiany kwot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o PPP:

- 1) Podmiot Publiczny potwierdza, że w dniu zawarcia Umowy Partner Prywatny wniósł na rzecz Podmiotu Publicznego Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych).
- 2) W terminie [...] dni od dnia uzyskania Pozwolenia na Budowę, Partner Prywatny zwiększy kwotę Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania do łącznej wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych).
- 3) Nie wcześniej niż po upływie [okres gwarancji] miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności Partner Prywatny zmniejszy kwotę Zabezpieczenia Należytego Wykonania bądź przedstawi nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania do wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych).

1.9 Finansowanie Przedsięwzięcia

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 1.1 – Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego oraz wstępne określenie źródeł ich finansowania

Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej

Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom II: Punkt 9.2 – Zamknięcie Finansowe

Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Zamknięcie Finansowe

Finansowanie projektowe

W Projekcie PPP z Opłatą za Dostępność, w którym Finansowanie zapewnia Partner Prywatny, z reguły Finansowanie oparte jest na modelu finansowania pojedynczego projektu (ang. *project finance*). Jest to Finansowanie bez tzw. regresu do sponsora (wspólników/akcjonariuszy Spółki Projektowej). Oznacza to, że źródłem spłaty takiego Finansowania oraz zwrotu zaangażowanego kapitału są przepływy pieniężne generowane w Projekcie PPP.

Instytucja Finansująca udziela zatem Finansowania w ramach i na potrzeby konkretnego Projektu PPP w oparciu o jego analizę finansową, techniczną i prawną. Ocena wiarygodności Projektu PPP przez Instytucje Finansujące obejmuje ocenę Bankowości Umowy o PPP, a także wykonawców robót czy usług utrzymaniowych oraz umów z ww. podwykonawcami spółki celowej.

Tym samym, kryteria udzielenia takiego Finansowania nie będą oparte na aktualnej sytuacji bilansowej Partnera Prywatnego (który w takiej konfiguracji pozostaje spółką specjalnego przeznaczenia tzw. *special purpose vehicle*, nieprowadzącą regularnej działalności gospodarczej), a na ocenie Przedsięwzięcia, Modelu Finansowego, treści Umowy o PPP i innych dokumentów dotyczących konkretnego, zindywidualizowanego Projektu PPP.

Jakkolwiek w zakresie samego Finansowania Umowa o PPP reguluje przede wszystkim zobowiązania Partnera Prywatnego do zapewnienia Finansowania w Projekcie PPP, to z punktu widzenia możliwości uzyskania Finansowania tj. Bankowości Projektu PPP, cała treść Umowy o PPP powinna być kształtowana przy założeniu, że dla Projektu PPP pozyskiwane będzie Finansowanie w strukturze *project finance*.

PRZYKŁAD



W przykładowym Projekcie Hybrydowym Podmiot Publiczny ocenił, że z uwagi na poziom dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 40% nakładów inwestycyjnych Bankowość Umowy o PPP nie jest bardzo istotna i zrezygnował z szeregu postanowień Umowy o PPP takich jak limit odpowiedzialności czy możliwość zawarcia Umowy Bezpośredniej. Nałożenie nieograniczonej odpowiedzialności na Partnera Prywatnego było podejściem daleko odbiegającym od standardów rynkowych, ponieważ Generalni Wykonawcy czy Operatorzy nie godzą się na przyjmowanie takiej nielimitowanej odpowiedzialności - nie tylko w kontraktach komercyjnych, ale również w zamówieniach publicznych. Powyższe oznaczało, że Partner

Prywatny nie był w stanie przenieść nieograniczonego ryzyka na Podwykonawcę i tym samym ryzyka te musiały pozostać w Spółce Projektowej. Skutkiem takiego podejścia był brak możliwości pozyskania finansowania dłużnego przez Partnera Prywatnego, albowiem pozostał z ryzykami, którymi nie był w stanie w żaden sposób zarządzać.

W konsekwencji Partner Prywatny zmuszony był uzupełnić brakującą część Finansowania wyłącznie poprzez finansowanie kapitałowe, co podniosło koszty jego Oferty, a tym samym Projektu PPP i skutkowało złożeniem tylko jednej oferty. Pozostali Wykonawcy nie dysponowali wystarczającym kapitałem własnym, aby sfinansować Projekt. Zmniejszyło to konkurencyjność Postępowania.

Postanowienia Umowy dotyczące Finansowania

W zakresie ogólnych postanowień dotyczących Finansowania Przedsięwzięcia, Umowa o PPP zawiera zobowiązania Partnera Prywatnego do zapewnienia Finansowania Projektu PPP i określa termin Zamknięcia Finansowego. Okres na Zamknięcie Finansowe jest z reguły dyskutowany podczas negocjacji. Umowa o PPP powinna przewidywać możliwość przedłużenia okresu przewidzianego na Zamknięcie Finansowe. Po bezskutecznym upływie tego terminu Podmiot Publiczny powinien mieć uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o PPP. Umowa o PPP z reguły przewiduje karę umowną w przypadku, gdy do Zamknięcia Finansowego nie doszło z przyczyn nieleżących po stronie Podmiotu Publicznego. Należy mieć na względzie, że Instytucje Finansujące są związane warunkami Finansowania, uzgodnionymi przed złożeniem Oferty również przez określony w nich okres, zatem w pewnym momencie kolejne zmiany terminu Zamknięcia Finansowego będą skutkować zmianą warunków Finansowania.

DOBRE PRAKTYKI



Dobłą praktyką jest, aby w przypadku, gdy przedłużenie terminu Zamknięcia Finansowego wynika z winy Podmiotu Publicznego i Podmiot Publiczny podejmie decyzję o kolejnym przedłużeniu terminu na Zamknięcie Finansowe, to wówczas to on powinien wziąć na siebie ryzyko zmiany warunków Finansowania. Kwestię tę można również uwzględnić w ramach klauzuli zmiany Umowy.

Ponieważ ryzyko zapewnienia Finansowania leży po stronie Partnera Prywatnego, Umowa o PPP zakłada, że w przypadku zmiany warunków Finansowania Wynagrodzenie Partnera Prywatnego nie ulegnie zmianie.

Umowa o PPP powinna określać obowiązki informacyjne Partnera Prywatnego w zakresie dokumentów Finansowania (np. przekazanie informacji od Instytucji Finansujących o udzieleniu finansowania w celu potwierdzenia Zamknięcia Finansowego).

Zmiana stóp procentowych

W większości Projektów PPP finansowanych w formule finansowania pojedynczego projektu (ang. *project finance*), występuje problem związany z ryzykiem ekspozycji Partnera Prywatnego na zmiany wysokości zmiennych stóp procentowych oznaczonych w Ofercie (np. zmiany wskaźnika WIBOR), które w Projektach PPP jest typowym ryzykiem alokowanym po stronie Podmiotu Publicznego.

Problematyka zabezpieczenia ryzyka ekspozycji Partnera Prywatnego na zmiany wysokości stopy procentowej lub kursów walut należy do złożonych zagadnień, ze względu na możliwe różne podejścia przy szczegółowym regulowaniu tego zagadnienia w Umowie o PPP.

W Umowach o PPP w Polsce ryzyko stóp procentowych mitygowane z reguły jest w oparciu o indeksację WIBOR. Wówczas zmiany wynagrodzenia Partnera Prywatnego mają miejsce w oparciu o proste i obiektywne wskaźniki i Podmiot Publiczny nie jest zobowiązany do kontroli zastosowanych mechanizmów.

Innym sposobem zabezpieczenia ryzyka zmiany stóp procentowych jest zawieranie tzw. transakcji zabezpieczających (ang. *hedging*). Wówczas koszty transakcji zabezpieczających ponoszone są przez Podmiot Publiczny.

Zmiana Finansowania

Umowa o PPP powinna regulować również kwestie dotyczące zmiany Finansowania. Pojęcie zmiany Finansowania w kontekście Projektów PPP należy rozumieć szeroko tj. zarówno jako zmianę warunków istniejącego (pierwotnego) Finansowania, jak również pozyskanie nowego Finansowania przez Partnera Prywatnego lub zmianę proporcji pomiędzy poszczególnymi źródłami Finansowania (np. kredytem i wkładami kapitałowymi podmiotów posiadających udziały/akcje w Spółce Projektowej), z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Modelu Finansowym.

Najczęściej zmiana finansowania ma miejsce po zakończeniu Okresu Budowy, ponieważ większość istotnych ryzyk związanych z Budową i makroekonomicznych zostało już zidentyfikowanych.

Sytuacją, która może wymagać uregulowania w Umowie o PPP, jest kwestia podziału zysku ze zmiany warunków Finansowania tj. zmiany, która w ujęciu netto (po odjęciu powiązanych kosztów zmiany) będzie prowadzić do zysku Partnera Prywatnego lub jego wspólników/akcjonariuszy w stosunku do wartości ujętej w Modelu Finansowym przed dokonaniem zmiany. Taką wartością może być np. wartość bieżąca netto (NPV) dla wkładu kapitałowego podmiotów posiadających udziały/akcje w Spółce Projektowej lub wartość netto planowanych dystrybucji do wspólników/akcjonariuszy. Konkretna proporcja podziału zysku ze zmiany Finansowania będzie przedmiotem negocjacji w ramach konkretnego projektu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Dużym Projekcie dotyczącym instalacji wytwarzania wodoru Partner Prywatny, przygotowując Model Finansowy oraz Ofertę, uwzględnił refinansowanie po zakończeniu Budowy. Model Finansowy przewidywał zatem korzyści wynikające z refinansowania. W związku z tym, że Partner Prywatny uwzględnił refinansowanie w Ofercie, to w wyniku przeprowadzonego refinansowania po zakończeniu Budowy nie ma podstaw do podziału zysku ze zmiany warunków Finansowania.

Proces zmiany warunków Finansowania będzie w większości przypadków inicjowany przez Partnera Prywatnego. W określonych sytuacjach (np. dostępność preferencyjnych źródeł finansowania) inicjatywa dotycząca zmiany finansowania może leżeć po stronie Podmiotu Publicznego. W takim przypadku decyzja o refinansowaniu nadal powinna należeć do Partnera Prywatnego, z uwagi na ewentualne skutki takiej zmiany co do warunków dotychczasowego finansowania.

Zabezpieczenia Finansowania

Umowa o PPP powinna zawierać zgodę Podmiotu Publicznego na zastosowanie instrumentów zabezpieczeń umów kredytowych dotyczących Finansowania i określać możliwe formy takich zabezpieczeń, jak np.:

- zastaw na udziałach Spółki Projektowej;
- przelew wierzytelności pieniężnych z Umowy;
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

MAŁE PROJEKTY



W Małych Projektach w Polsce model *project finance* zwykle nie jest stosowany. Często Partnerem Prywatnym będzie podmiot funkcjonujący na rynku realizujący również inne zadania lub konsorcjum z udziałem takich podmiotów. W takim wypadku Finansowanie Projektu PPP przedstawiać się będzie inaczej niż w modelu *project finance*.

Prawdopodobny jest znacznie większy udział finansowego wkładu własnego Partnera Prywatnego. Skłonność do ekspozycji kredytowej Partnera Prywatnego będzie znacznie mniejsza niż w finansowaniu projektowym. Dług związany z finansowaniem dłużnym obciążał będzie bilans przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego. Wystąpią także inne instrumenty zabezpieczeń Instytucji Finansującej i Podmiotu Publicznego.

Kontrola nad spółką Partnera Prywatnego będzie znacznie mniejsza niż w przypadku *project finance*. Partner Prywatny na określonym etapie (np. po wykonaniu Robót) nie będzie mógł zbyć Projektu PPP (np. poprzez zbycie udziałów w Spółce Projektowej) innemu przedsiębiorcy, jak mógłby pod pewnymi warunkami uczynić w przypadku *project finance*.

UWAGA



Projekty PPP oparte o Opłatę za Dostępność mogą być realizowane jako Projekty Hybrydowe (więcej na ten temat por. Wytyczne Tom I oraz Wytyczne Tom II). Beneficjentem środków unijnych w takich przypadkach będzie najczęściej Podmiot Publiczny. Kwestia ta powinna być uregulowana w postanowieniach ogólnych Umowy o PPP.

Realizacja Projektu Hybrydowego wymaga od stron podjęcia szeregu dodatkowych czynności, związanych przede wszystkim z pozyskaniem dofinansowania oraz prawidłowego rozliczenia Projektu. Montaż finansowy Projektu PPP, obejmujący środki unijne, powinien w przejrzysty sposób określać zasady rozliczenia tych środków (np. w ramach zakładanego przez beneficjenta harmonogramu płatności).

1.10 Umowa Bezpośrednia

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa
Tom II: Punkt 9.2 – Zamknięcie Finansowe
Tom IV: Część II Punkt 1.6 – Umowa Bezpośrednia
Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Zamknięcie Finansowe

Umowa o PPP z reguły przewiduje możliwość zawarcia Umowy Bezpośredniej przez strony Umowy o PPP oraz Instytucje Finansujące. Umowa Bezpośrednia oznacza umowę, na podstawie której uzgadniane są zasady współpracy pomiędzy tymi stronami. Takie zasady współpracy będą szczególnie pomocne wówczas, kiedy Partner Prywatny nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy o PPP.

Umowa Bezpośrednia regulować będzie w szczególności:

- ewentualne zgody Podmiotu Publicznego na ustanowienie instrumentów zabezpieczeń na rzecz Instytucji Finansujących;
- sposób dokonywania płatności z tytułu Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego (np. możliwości dokonywania przez Podmiot Publiczny płatności należnych Partnerowi Prywatnemu bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Finansującą);
- konieczność informowania, a niekiedy również zgody Instytucji Finansującej, na wprowadzanie zmian w Umowie o PPP, np. w zakresie wpływającym na harmonogram wypłaty Wynagrodzenia;
- obowiązki informacyjne Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego względem Instytucji Finansujących;
- obowiązki informacyjne Instytucji Finansujących względem Podmiotu Publicznego;
- procedury naprawcze, w ramach których Instytucje Finansujące mogą podejmować działania mające na celu usunięcie przyczyn dających Podmiotowi Publicznemu prawo wypowiedzenia Umowy o PPP;
- zasady zmiany Partnera Prywatnego lub Podwykonawców;
- zawieszenie prawa do wypowiedzenia Umowy o PPP przez jej strony oraz naliczania kar przez Podmiot Publiczny podczas okresu naprawczego.

UWAGA



Zawieszenie naliczania kar w okresie naprawczym nie ma na celu ograniczenia uprawnień Podmiotu Publicznego. Celem takiego mechanizmu – podobnie jak zawieszenia prawa wypowiedzenia Umowy – jest umożliwienie stronom kontynuowania Projektu PPP. Dla Podmiotu Publicznego dużo trudniejsze w skutkach mogłoby być wypowiedzenie Umowy. Oznaczałoby to

bowiem konieczność dokonania rozliczeń z dotychczasowym Partnerem Prywatnym oraz kontynuowanie Projektu PPP samodzielnie lub we współpracy z nowym Partnerem Prywatnym, co z kolei wymagałoby przeprowadzenia Postępowania PPP.

Należy w tym miejscu mieć na względzie trudności związane z kontynuacją Projektu PPP przez nowego Partnera Prywatnego, w tym ryzyka związane ze stanem Infrastruktury Publicznej na moment jej przekazania nowemu Partnerowi Prywatnemu.

Tym samym wszelkie zawieszenia wykonywania określonych praw Podmiotu Publicznego w okresie naprawczym należy oceniać z punktu widzenia korzyści wynikających z kontynuowania Projektu PPP. Tym samym powstrzymanie się od naliczania kar ma funkcję naprawczą, która nie jest przysporzeniem po stronie Partnera Prywatnego, lecz próbą umożliwienia kontynuacji Projektu PPP i uniknięcia dalej idącej szkody po stronie Podmiotu Publicznego.

Zakres Umowy Bezpośredniej jest co do zasady ustandaryzowany. Nie ma konieczności dokładnego wskazywania w Umowie o PPP obszarów, jakie Umowa Bezpośrednia będzie regulować, pozostawiając w tym zakresie swobodę stronom w zależności od uwarunkowań konkretnego Projektu PPP i konkretnej Umowy o PPP.

Treść Umowy Bezpośredniej negocjowana jest na etapie Zamknięcia Finansowego z konkretnymi Instytucjami Finansującymi. Dlatego też Umowa o PPP nie powinna regulować relacji pomiędzy stronami Umowy o PPP i Instytucjami Finansującymi.

Umowy o PPP czasem zawierają załącznik w postaci przewidywanych przez strony istotnych warunków Umowy Bezpośredniej. Załącznik taki powinien zawierać przykładowy i poglądowy katalog regulacji (lista otwarta).

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Umowa o PPP określała dokładnie (lista zamknięta) zakres Umowy Bezpośredniej. W rezultacie przy negocjowaniu warunków Umowy Bezpośredniej Podmiot Publiczny, pomimo że rozumiał zasadność proponowanych rozwiązań, stał na stanowisku, że nie może ich zaakceptować z uwagi na okoliczność, że rozwiązania te wykraczają poza katalog przyjęty w Umowie o PPP. Ostatecznie – po przeprowadzeniu stosownych analiz uznano, że proponowane rozwiązania stanowią dopuszczalną zmianę Umowy o PPP, co wymagało dodatkowo zawarcia aneksu do Umowy o PPP. W efekcie zawężenie zakresu Umowy Bezpośredniej w Umowie o PPP spowodowało niepotrzebne utrudnienia i wątpliwości oraz konieczność przeprowadzania dodatkowych analiz i ponoszenia kosztów z tym związanych. Istniało również ryzyko braku możliwości zawarcia Umowy Bezpośredniej o wymaganej treści, gdyby wynik analiz nie był pozytywny. Oznaczałoby to brak możliwości pozyskania Finansowania dłużnego dla Projektu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora budynków użyteczności publicznej Umowa o PPP określała dokładnie procedury naprawcze podejmowane w okresie naprawczym przy udziale Instytucji Finansujących, które standardowo regulowane są w Umowie Bezpośredniej. W rezultacie procedury opisane w Umowie PPP nie uwzględniały procedur Instytucji Finansujących i, między innymi, terminy przewidziane w Umowie o PPP na określone działania Instytucji Finansujących były nieprawidłowe. W celu zawarcia Umowy Bezpośredniej konieczna była zatem zmiana Umowy o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Strony Umowy o PPP mogą zawrzeć Umowę Bezpośrednią. Umowa Bezpośrednia będzie w szczególności regulować następujące kwestie:

- zgody Podmiotu Publicznego na określone instrumenty zabezpieczeń;
- przekaz kwoty rozliczenia w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy o PPP;
- obowiązki informacyjne Stron;
- procedurę programu naprawczego;
- zakaz przedterminowego zakończenia Umowy o PPP przez Strony Umowy o PPP przed wdrożeniem procedur naprawczych;
- zakaz naliczania kar umownych przez Strony Umowy o PPP w okresie naprawczym.

Warunki szczegółowe Umowy Bezpośredniej zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami i Podmiotem Finansującym podczas ustalania treści Umowy Bezpośredniej.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 10a Ustawy o PPP postanowienia Umowy Bezpośredniej dotyczące przeniesienia na osobę trzecią całości lub części obowiązków Partnera Prywatnego nie mogą być sprzeczne z Umową o PPP.

1.11 Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.9.3 – Systemy zarządzania informacją

Tom IV: Część II Punkt 1.9.4 – Listy sprawdzające

Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Wstępne określenie Standardów Utrzymania

Tom IV: Część II Punkt 3.1 – Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU

Tom IV: Część II Punkt 3.3 – Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

Tom IV: Część II Punkt 4.1 – Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej

Kontrola

Umowa o PPP powinna wdrażać przewidziane w przepisie art. 8 Ustawy o PPP uprawnienie Podmiotu Publicznego do bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego oraz kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego do realizacji Przedsięwzięcia.

Umowa o PPP powinna zawierać szczegółowe zasady oraz tryb kontroli sprawowanej przez Podmiot Publiczny. Dokładne określenie zakresu kontroli oraz procedur pozwoli na uniknięcie sporów między stronami w tym zakresie na etapie wykonywania Umowy o PPP.

Umowa o PPP powinna określać zasady wykonywania kontroli przez Podmiot Publiczny w celu weryfikacji należytego wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego. Kontrola taka realizowana jest na różnych poziomach – poprzez weryfikację i zgłaszanie uwag do kluczowych dokumentów projektowych, w tym projektu budowlanego, po kontrole wyrywkowe wykonywania obowiązków w zakresie np. utrzymywania Standardów Utrzymania.

Wykonywanie przez Partnera Prywatnego obowiązków wynikających z Umowy o PPP, w tym w zakresie Utrzymania i Zarządzania, może być monitorowane przez Podmiot Publiczny poprzez wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie oraz o częstotliwości wedle uznania Podmiotu Publicznego. Dotyczy to w szczególności stanu technicznego Infrastruktury Publicznej, która zwykle wraz z Zakończeniem Umowy wróci do Podmiotu Publicznego.

DOBRE PRAKTYKI



Za dobrą praktykę należy uznać sporządzanie przez Podmiot Publiczny protokołu z kontroli oraz umożliwienie złożenia zastrzeżeń do protokołu przez Partnera Prywatnego.

Ustawa o PPP mówi o bieżącej kontroli, co nie oznacza, że Podmiot Publiczny powinien przeprowadzać ją w sposób nadmiernie (nieadekwatnie) uciążliwy. Określając zakres uprawnień kontrolnych oraz tryb prowadzenia kontroli, należy mieć na względzie, aby działania Podmiotu Publicznego były adekwatne dla prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności w ramach Umowy o PPP.

Przy określaniu zakresu i częstotliwości kontroli oraz obowiązków raportowania Podmiot Publiczny musi brać pod uwagę własne możliwości w tym zakresie – zbyt daleko idące obowiązki będą się również wiązać z nadmiernym angażowaniem personelu Podmiotu Publicznego, który będzie musiał te kontrole przeprowadzać oraz weryfikować raporty okresowe. Podmiot Publiczny powinien również zastanowić się, jakie kontrole (oraz w jakim zakresie i z jaką częstotliwością) będą przeprowadzać organy administracji publicznej (np. Urząd Dozoru Technicznego), tak aby ich kontrole nie dublowały się z kontrolami przeprowadzanymi przez Podmiot Publiczny na podstawie Umowy o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Podmiot Publiczny w całym Okresie Obowiązywania Umowy dysponuje uprawnieniami kontrolnymi, co do oceny należytego wykonywania obowiązków Partnera Prywatnego, wynikających z Umowy.
- 2) Podmiot Publiczny będzie wykonywał swoje uprawnienia wynikające z niniejszego punktu w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Partnera Prywatnego.
- 3) Partner Prywatny jest zobowiązany umożliwić właściwym Organom Administracji dokonanie kontroli Terenu Budowy, Infrastruktury Publicznej oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej Przedsięwzięcia, do której dostępu zażąda Organ Administracji, a do której posiadania Partner Prywatny zobowiązany jest zgodnie z Umową lub na podstawie przepisów prawa. Partner Prywatny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Podmiot Publiczny o wszelkich planowanych i faktycznie realizowanych kontrolach prowadzonych przez właściwe Organy Administracji i umożliwić przedstawicielom Podmiotu Publicznego udział w czynnościach kontrolnych.
- 4) W ramach wykonywania czynności kontrolnych Podmiot Publiczny upoważniony jest do:
 - kontroli prowadzenia Prac Projektowych w siedzibie projektanta, w siedzibie Partnera Prywatnego, na Terenie Budowy lub w innym miejscu, w którym prowadzone są Prace Projektowe;
 - wejścia na teren Nieruchomości lub do obiektu w celu dokonania kontroli prac w zakresie Robót Budowlanych lub Utrzymania;
 - uczestniczenia w testach, kontrolach lub badaniach lub w inny sposób wykonywania swoich praw i zobowiązań wynikających z Umowy i przepisów prawa;
 - kontroli Terenu Robót;
 - wglądu do Dokumentacji Projektowej i dokumentacji budowy, wszelkich ksiąg, dokumentów, opracowań, notatek, instrukcji itp. sporządzonych przez Partnera Prywatnego na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz wykonywania ich kopii.

Powyższe uprawnienia Podmiotu Publicznego nie skutkują zobowiązaniem Partnera Prywatnego do uzyskania posiadania jakichkolwiek rzeczy, będących w posiadaniu innych osób. Partner Prywatny dołoży starań, aby (o ile jest to możliwe) zapewnić Podmiotowi Publicznemu dostęp do takich rzeczy.
- 5) Podmiot Publiczny, przy wykonywaniu praw przysługujących mu zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, nie spowoduje bezzasadnie opóźnień ani zakłócenia biegu Prac Projektowych, Robót Budowlanych lub Utrzymania, lub wykonywania przez Partnera Prywatnego innych zobowiązań wynikających z Umowy.
- 6) Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań przez Partnera Prywatnego wynikających z niniejszej Umowy, z uwagi na wykonywanie przez Podmiot Publiczny uprawnień kontrolnych, nie będzie skutkowało nałożeniem na Partnera Prywatnego Punktów Karnych.

- 7) Podmiot Publiczny obowiązany jest realizować czynności kontrolne w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków przez Partnera Prywatnego.
- 8) Z wyjątkiem stanu zagrożenia życia lub zdrowia wszystkie kontrole prowadzone będą przez Podmiot Publiczny na podstawie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, określającego termin prowadzenia kontroli oraz osoby kontrolujące. Powiadomienie będzie doręczone Partnerowi Prywatnemu na trzy Dni Robocze przed planowaną kontrolą.

Skutkiem braku efektywnej kontroli wykonywania Umowy o PPP mogą być m.in. opóźnienie w zakończeniu Budowy i oddaniu Infrastruktury Publicznej do użytkowania, brak bieżącej weryfikacji KPI, brak nakładania Punktów Karnych czy pogarszanie się jakości Infrastruktury Publicznej. Efektywne kontrole mogłyby pomóc wcześniej zidentyfikować np. ryzyko opóźnienia i wdrożyć stosowne działania w ramach programu naprawczego.

Raportowanie

Umowa o PPP powinna uwzględniać obowiązek Partnera Prywatnego przeprowadzania regulowanego przepisem art. 8 ust. 3 Ustawy o PPP bieżącego raportowania Podmiotowi Publicznemu o stanie realizacji Przedsięwzięcia i stanie składnika majątkowego wykorzystywanego do realizacji Przedsięwzięcia.

Umowa o PPP zawiera szczegółowe zasady, tryb i częstotliwość raportowania. Monitorowanie Robót Budowlanych oraz następnie Utrzymania odbywa się poprzez przedkładanie Podmiotowi Publicznemu comiesięcznych oraz rocznych raportów. Raportowanie odgrywa kluczową rolę na etapie Utrzymania ze względu na potrzebę zgłaszania przez Partnera wszystkich zdarzeń, które są podstawą do naliczania punktów karnych i informowania Podmiotu Publicznego o liczbie Punktów Karnych w danym miesiącu, co przekłada się na obniżenie wartości Wynagrodzenia.

Wzory raportów stanowią załącznik do Umowy o PPP, a ich treść uzależniona jest od specyfiki Przedsięwzięcia oraz potrzeb Podmiotu Publicznego. Raporty mogą zawierać nie tylko informacje dotyczące samego Przedsięwzięcia, ale również dotyczące Partnera Prywatnego (np. podstawowe dane finansowe).

DOBRE PRAKTYKI



Umowa o PPP może przewidywać, że raportowanie będzie wykonywane za pośrednictwem specjalnej platformy IT. Platforma ta może również służyć kalkulacji Punktów Karnych oraz za jej pośrednictwem Podmiot Publiczny może zgłaszać naruszenia Standardów Utrzymania.

Umowa o PPP może również nakładać na Partnera Prywatnego obowiązek monitorowania opinii użytkowników (poprzez umożliwienie użytkownikom Infrastruktury Publicznej wypełniania ankiet i zgłaszania skarg).

Podobnie jak zakres kontroli, zakres oraz częstotliwość raportowania powinny być dostosowane do konkretnego Projektu PPP.

Brak wywiązywania się przez Partnera Prywatnego z obowiązków raportowania, w tym błędy lub brak wykazania określonych zdarzeń, powinien być w proporcjonalny sposób sankcjonowany w Umowie o PPP (np. poprzez zwielokrotnienie Punktów Karnych).

W przypadku, gdy konkretne informacje dla celów statystycznych lub na potrzeby informacyjne w Projektach Hybrydowych potrzebne są Podmiotowi Publicznemu, można to uwzględnić w zakresie informacji, które raportuje Partner Prywatny (np. liczba obsłużonych klientów w określone dni).

UWAGA



W przypadku Projektów Hybrydowych kontrola i obowiązki w zakresie raportowania Partnera Prywatnego powinny być rozszerzone o wymogi właściwej instytucji zarządzającej, związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu. W szczególności Partner Prywatny powinien poddać się kontrolom uprawnionych do tego instytucji oraz współpracować z Podmiotem Publicznym przy rozliczaniu projektu w sposób wynikający z umowy o dofinansowanie i systemu realizacji danego programu operacyjnego.

W przypadku, kiedy beneficjentem jest Podmiot Publiczny, to on odpowiedzialny jest za prawidłowe wykorzystanie dofinansowania, ale bez współpracy z Partnerem Prywatnym nie będzie to możliwe.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Partner Prywatny będzie przekazywał Podmiotowi Publicznemu raporty miesięczne oraz roczne o zakresie wskazanym w Załączniku pt. Wzory raportów.
- 2) Raporty roczne muszą być przekazywane, co najmniej w formie pisemnej, z podpisem przedstawiciela Partnera Prywatnego, upoważnionego do reprezentacji.
- 3) Strony, w razie potrzeby, odrębnie ustalą format przekazywanych sprawozdań, przy czym ustalenie tej formy nie będzie wymagało zmiany Umowy. Strony dopuszczają przekazywanie raportów przez Partnera Prywatnego w formie elektronicznej, umożliwiającej Podmiotowi Publicznemu samodzielny, zdalny dostęp na podstawie hasła i kodu, doręczonego przez Partnera Prywatnego.
- 4) Wszelkie przypadki skutkujące nałożeniem Punktów Karnych powinny być odnotowane w ewidencji prowadzonej przez Partnera Prywatnego w terminie trzech Dni Roboczych od dnia uzyskania przez Partnera Prywatnego informacji o zaistnieniu takiego zdarzenia. Ewidencja będzie prowadzona w formie elektronicznej, umożliwiającej Podmiotowi Publicznemu samodzielny, zdalny dostęp na podstawie hasła i kodu, doręczonego przez Partnera Prywatnego.

1.12 Podwykonawcy

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom II: Punkt 4.3 – Kryteria Oceny Podmiotowej

Tom II: Punkt 4.4 – Dokumenty i oświadczenia Partnerów Prywatnych

Umowa PPP powinna zawierać postanowienia regulujące kwestie podwykonawstwa na etapie wykonywania Umowy o PPP, w szczególności w zakresie zmian Podwykonawcy (Generalnego Wykonawcy).

UWAGA



Partner Prywatny samodzielnie decyduje o swojej strukturze podmiotowej, w jakiej weźmie udział w Postępowaniu i będzie wykonywał Umowę o PPP (czy samodzielnie, czy np. w konsorcjum, czy też przez Spółkę Projektową). Na tę decyzję mogą mieć wpływ takie czynniki jak specyfika sektora, wartość Przedsięwzięcia, wymogi Podmiotu Publicznego w zakresie warunków udziału w Postępowaniu czy planowany sposób finansowania Projektu PPP. Zazwyczaj Partnerzy Prywatni decydują się na udział w Postępowaniu (oraz wykonywanie Umowy o PPP) przez Spółkę Projektową (lub na mocy art. 7a Ustawy o PPP utworzą spółkę dla realizacji Umowy o PPP, której jedynymi współnikami są Partnerzy Prywatni biorący udział w postępowaniu). Wówczas realizować będą Projekt PPP na podstawie umów z Podwykonawcami, którymi często są wspólnicy Spółki Projektowej. Nie jest to jednak regułą.

W celu spełnienia warunków udziału w Postępowaniu (np. w zakresie doświadczeń przy projektowaniu, budowie czy utrzymaniu), Spółka Projektowa polega zazwyczaj na potencjale podmiotów trzecich (samodzielnie, jako spółka celowa utworzona dla realizacji konkretnego projektu nie dysponuje takim doświadczeniem).

UWAGA



Spółki Projektowe zazwyczaj polegają na potencjale podmiotów z grupy kapitałowej, ale także korzystają z zasobów podmiotów niepowiązanych kapitałowo czy organizacyjnie z Partnerem Prywatnym, które posiadają specjalistyczne doświadczenia (np. w zakresie projektowania) wymagane w danym postępowaniu. Stąd też kwestia podwykonawstwa, w szczególności na etapie realizacji Umowy o PPP nabiera kluczowego znaczenia, zarówno z perspektywy Partnera Prywatnego, jak i Podmiotu Publicznego.

Z perspektywy Podmiotu Publicznego kluczowe jest to, aby poprzez odpowiednie postanowienia umowne zapewnić, że Umowę o PPP będą wykonywać Podwykonawcy posiadający wymagane doświadczenie, a przede wszystkim te podmioty, na potencjał których Partner Prywatny (Spółka Projektowa) powoływał się w celu spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. W szczególności, ważne jest, aby podmiot udostępniający zasoby na etapie Postępowania brał faktyczny udział w realizacji danej części Przedsięwzięcia – np. jako Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, bowiem to ten podmiot dysponuje doświadczeniem i zasobami dla wykonania takiej części Projektu. Sama struktura zaangażowania takiego podmiotu wydaje się być drugorzędna (tj. czy podmiot udostępniający zasoby stanie się podwykonawcą Partnera Prywatnego lub Spółki Projektowej lub Generalnego Wykonawcy).

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Podmiot Publiczny w ogłoszeniu wymagał, aby Partner Prywatny wykazał się doświadczeniem w zakresie zaprojektowania oraz wybudowania co najmniej 2 dróg publicznych o długości min. 20 km. Partner Prywatny w celu spełnienia tego warunku polegał na potencjale spółki z grupy posiadającej takie łączne doświadczenie. Na etapie wykonywania Umowy o PPP, Partner Prywatny ze względu na nieprawidłowe wykonywanie zadań przez dotychczasowego Podwykonawcę, na etapie budowy, postanowił dokonać jego zmiany na podmiot posiadający adekwatne doświadczenie. Ze względu na etap wykonywania Umowy o PPP (Okres Projektowania i Okres Budowy), wystarczające jest, aby nowy Podwykonawca wykazał się wymaganym przez Podmiot Publiczny doświadczeniem wyłącznie w zakresie wykonywanych Robót.

UWAGA



W przeciwieństwie do umów o roboty budowlane realizowanych na podstawie przepisów PZP, Podwykonawcy Partnera Prywatnego nie korzystają ze specyficznej ochrony przewidzianej dla podwykonawców przepisami PZP, to jest Podmiot Publiczny nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców Partnera Prywatnego. Wynika to wprost z art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP, który wyłącza stosowanie art. 465 Ustawy PZP do Umów o PPP (zob. Część I Punkt 2.3 Istotne warunki Umowy o PPP) oraz art. 7b Ustawy o PPP, która wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy.

Z punktu widzenia Partnera Prywatnego (oraz Instytucji Finansujących), ze względu na długoterminowy charakter Umowy o PPP, ważne jest to, aby zapewnić mu możliwość zmiany Podwykonawcy w toku wykonywania Umowy o PPP (np. jeśli dany Podwykonawca nieprawidłowo wykonuje Umowę o PPP lub w toku realizacji Utrzymania, dochodzi do zaprzestania działalności).

Umowa o PPP powinna przewidywać mechanizm i procedury umożliwiające zmianę Podwykonawcy na podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie (tj. adekwatnie do momentu realizacji Umowy).

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby Partner Prywatny powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, Partner Prywatny jest zobowiązany wykazać Podmiotowi Publicznemu, iż proponowany nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca Partnera Prywatnego, na którego zasoby Partner Prywatny powoływał się w trakcie Postępowania.

UWAGA



Specyfika realizacji Projektów PPP przez Spółkę Projektową oraz Podwykonawców (np. przez Generalnego Wykonawcę) może skutkować tym, że Partner Prywatny będzie oczekiwał umożliwienia złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy o PPP (np. w formie gwarancji bankowej) przez Generalnego Wykonawcę. Z perspektywy Podmiotu Publicznego, kluczowy jest zakres, warunki oraz wysokość gwarancji, a więc złożenie takiej gwarancji przez Podwykonawcę nie powinno być wykluczone w Umowie o PPP.

1.13 Niezależny Inżynier

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-IV



Tom IV: Część II Punkt 1.9.1 – Analizy i opinie niezależnych ekspertów

Niezależny Inżynier (nazwa nie jest zdefiniowana w przepisach prawa; używa się również określeń "inżynier kontraktu", "niezależny doradca") to podmiot działający na rzecz Projektu PPP, podejmujący działania związane zarówno z bieżącym, rzetelnym administrowaniem Umową o PPP, jak i z zapobieganiem sporom, łagodzeniem ich na wczesnym etapie, a także rozstrzyganiem spraw, w których wymiana sprzecznych stanowisk stron nie doprowadziła do konsensusu.

W przypadku, gdy strony przewidziały udział Niezależnego Inżyniera w Umowie o PPP, powinna ona regulować następujące kwestie:



Funkcje Niezależnego Inżyniera w Projekcie

PRZYKŁAD



Funkcje Niezależnego Inżyniera w Umowach PPP:

- koordynujące (np. ocena i opiniowanie harmonogramu realizacji Umowy, uczestniczenie w zebraniach koordynacyjnych, prowadzenie dokumentacji spotkań, inspekcji i dyskusji itp.);
- kontrolne (np. monitorowanie postępów przygotowywania Dokumentacji Projektowej, kontrola zgodności prowadzonych Robót, w tym materiałów, wykonawstwa i jakości z Umową o PPP);
- monitorowanie postępów Robót w stosunku do harmonogramów itp.;
- dotyczące rozstrzygania kwestii do uzgodnienia pomiędzy stronami (np. Wydawanie rozstrzygnięć Niezależnego Inżyniera w odniesieniu do przypadków zewnętrznych, wskazywanie działań jakie należy podjąć w celu złagodzenia skutków wystąpienia siły wyższej);

- konieczności zmiany projektu budowlanego lub projektu wykonawczego itp.;
- dotyczące rozstrzygania kwestii spornych (jako etap poprzedzający wszczęcie procedury rozwiązywania sporów).

UWAGA



Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach rozstrzygnięcie Niezależnego Inżyniera może modyfikować prawa i obowiązki stron, skutkujące niekiedy koniecznością zmiany Umowy o PPP. Przy wykonywaniu ww. funkcji Niezależny Inżynier powinien działać w sposób bezstronny, w oparciu o profesjonalną wiedzę, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.



Sposób ustanawiania Niezależnego Inżyniera

Sposób wyboru Niezależnego Inżyniera określa Umowa o PPP. W tym zakresie możliwe są różne podejścia. Najczęściej proponuje się zawarcie umowy trójstronnej z udziałem Niezależnego Inżyniera, Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego. W Umowach o PPP często zawiera się regulację, zgodnie z którą wyboru dokonuje Partner Prywatny w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym. Podmiot Publiczny powinien określić w Umowie o PPP rolę oraz pozycję Niezależnego Inżyniera oraz jasno przypisać zadania, których realizacji oczekuje się w ramach Umowy PPP, w szczególności w procedurze rozstrzygania sporów.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE



Gdy Podmiot Publiczny chce zachować wpływ na wybór Niezależnego Inżyniera i samodzielnie dokonać jego wyboru (np. wskazując na okoliczności wynikające z przepisów PZP i płatności wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej – tj. Inżyniera), to w takim przypadku Umowa o PPP powinna (i) szczegółowo określić procedurę wyboru Inżyniera przez Podmiot Publiczny (np. zastosowanie trybu negocjacyjnego), (ii) zawierać minimalne warunki i kryteria udziału w takim postępowaniu (np. zobowiązanie Podmiotu Publicznego, że będzie wymagał od Inżyniera wykazania odpowiedniego doświadczenia w danym sektorze oraz odpowiedniego potencjału kadrowego, a także wykazania braku konfliktu interesów w stosunku do obu stron Umowy), oraz (iii) zobowiązywać Podmiot Publiczny, że dokona wyboru z uwzględnieniem kryteriów cenowych oraz pozacenowych. W konsekwencji przyjęcia takiego modelu Umowa o PPP będzie określać szczegółowo rolę Niezależnego Inżyniera, a wzór umowy z Niezależnym Inżynierem (lub jej istotne postanowienia) będą stanowiły załącznik do Umowy o PPP, tak aby w ramach Postępowania, Partner Prywatny mógł zgłosić uwagi i komentarze przed złożeniem oferty.



Istotne warunki współpracy z Niezależnym Inżynierem

Umowa o PPP powinna uregulować kluczowe kwestie związane z Niezależnym Inżynierem takie, jak zakres jego zadań, okres obowiązywania umowy, wynagrodzenie, kary umowne czy odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie umowy, wymagane zabezpieczenia i ubezpieczenia w zakresie wykonywanej działalności.

UWAGA



Wynagrodzenie Niezależnego Inżyniera będzie regulować umowa z Niezależnym Inżynierem. Wynagrodzenie należne Niezależnemu Inżynierowi może być płatne przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego (w zależności od modelu wyboru). Wynagrodzenie Niezależnego Inżyniera za świadczenie usług stanowi koszt Projektu, który może być uwzględniony w ramach Opłaty za Dostępność.

Istotne jest także zapewnienie, że Niezależny Inżynier nie ma konfliktu interesu przy wykonywaniu swoich zadań na rzecz Projektu, a także że w całym okresie umowy będzie dysponował niezbędnym personelem, który będzie realizował zadania wskazane w umowie oraz zapewni dyspozycyjność danego personelu. Ze względu na długoterminowy charakter Umowy o PPP należy zapewnić elastyczność w zakresie możliwości zastępowania ekspertów.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Strony zobowiązują się współpracować z Niezależnym Inżynierem w dobrej wierze, a także nie wywierać wpływu na Niezależnego Inżyniera w sposób sprzeczny z Przepisami Prawa lub dobrymi obyczajami.

DOBRE PRAKTYKI



Warto dołączyć do umowy z Niezależnym Inżynierem odrębny załącznik wskazujący kluczowy personel Niezależnego Inżyniera, który będzie zaangażowany np. w Okresie Budowy oraz zawierający postanowienia co do zapewnienia stabilności zespołu.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



W szczególności zakres zadań Niezależnego Inżyniera w Okresie Budowy obejmować będzie następujące zadania:

- 1) ocena i zaopiniowanie Harmonogramu;
- 2) monitorowanie postępów Dokumentacji Projektowej i czuwanie, by Dokumentacja Projektowa była zgodna z Przepisami Prawa i Umową o PPP;
- 3) informowanie Podmiotu Publicznego o każdym żądaniu przez Partnera Prywatnego w zakresie odstępstw od Dokumentacji Projektowej, w stosunku do Umowy o PPP;
- 4) konsultowanie każdego żądania Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego dotyczącego odstępstw w stosunku do Dokumentacji Projektowej;
- 5) kontrola zgodności Robót, w tym materiałów, wykonawstwa i jakości, z Umową o PPP;
- 6) monitorowanie postępu Robót w stosunku do Harmonogramu;
- 7) monitorowanie skuteczności planu zapewniania jakości Generalnego Wykonawcy;
- 8) ocena okresowych raportów Partnera Prywatnego lub Generalnego Wykonawcy na temat Robót;
- 9) podjęcie czynności kontroli oraz wydawanie, zależnie od przesłanek, Protokołu Wstępnego Zakończenia Budowy, wraz z określeniem Robót i innych prac niezbędnych do uzyskania Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy oraz terminu wykonania tych Robót i innych prac uwzględniających ich zakres oraz możliwości techniczne i technologiczne ich wykonania, a także Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy;
- 10) uczestniczenie w zebraniach dotyczących postępu Robót oraz prowadzenie pełnej i prawidłowej dokumentacji wszelkich spotkań, inspekcji i dyskusji przeprowadzonych w ramach wykonywania obowiązków Niezależnego Inżyniera;
- 11) odbieranie zawiadomień i szczegółowych informacji na temat Przypadków Kompensacyjnych oraz Przypadków Dostosowania;
- 12) wydawanie Rozstrzygnięć Niezależnego Inżyniera w odniesieniu do Przypadków Kompensacyjnych oraz Przypadków Dostosowania;
- 13) wydawanie Rozstrzygnięć Niezależnego Inżyniera w odniesieniu do Poleceń Zmiany;
- 14) monitorowanie i weryfikacja prac podjętych jako Polecenie Zmiany;
- 15) zaopiniowanie projektu Instrukcji Utrzymania przed terminem przekazania opinii w sprawie Instrukcji Utrzymania przez Podmiot Publiczny;
- 16) kontaktowanie się ze Stronami w sprawach związanych z działaniami, jakie należy podjąć celem złagodzenia skutków wystąpienia Siły Wyższej;
- 17) powiadamianie Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego o każdym przypadku powzięcia przez Niezależnego Inżyniera informacji, że podwykonawcy Generalnego Wykonawcy nie zostali opłacony za należycie wykonane prace na podstawie umów podwykonawczych, za które Generalny Wykonawca otrzymał zapłatę.



Ogólne uprawnienia stron względem Niezależnego Inżyniera

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach rozstrzygnięcie Niezależnego Inżyniera może modyfikować prawa i obowiązki stron, skutkujące niekiedy (ale nie zawsze) koniecznością zmiany Umowy o PPP. Przy wykonywaniu ww. funkcji Niezależny Inżynier powinien działać w sposób bezstronny, w oparciu o profesjonalną wiedzę, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

Niezależny Inżynier powinien funkcjonować w sposób ciągły w Okresie Budowy, natomiast w Okresie Utrzymania mógłby być powoływany w przypadkach tego wymagających (ad hoc), z reguły dotyczyć to będzie kwestii w zakresie technicznym. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty związane z funkcjonowaniem Niezależnego Inżyniera, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści wynikających z tej instytucji.

1.14 Zmiany własnościowe Partnera Prywatnego (Spółki Projektowej)

Umowa o PPP czasem zawiera postanowienia dotyczące tzw. zmiany kontroli Spółki Projektowej (*ang. change of control*).

Podmioty Publiczne poprzez regulacje umowne chcą zapewnić sobie kontrolę nad określonymi zmianami własnościowymi Partnera Prywatnego. Zazwyczaj dotyczy to zbywania udziałów w Okresie Budowy.

DOBRE PRAKTYKI



Dobłą Praktyką jest, aby zmiany własnościowe po stronie Partnera Prywatnego były komunikowane Podmiotowi Publicznemu, lecz nie powinny być uzależnione od jego zgody. Swoboda obrotu udziałami po Okresie Budowy nie powinna być w żaden sposób ograniczana.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Zbycie lub obciążenie całości lub części Udziałów na rzecz osób trzecich wymaga poinformowania Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego o planowanym zbyciu Udziałów w terminie trzydziestu (30) dni przed planowaną datą zbycia Udziałów, a następnie o dokonaniu zbycia Udziałów w terminie [...] dni od dokonania zbycia Udziałów.

2. Okres Projektowania i Okres Budowy

2.1 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom IV: Część II Punkt 3.1 – Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU

Tom IV: Część II Punkt 3.2 – Harmonogram Etapu Inwestycyjnego

Budowa Infrastruktury Publicznej poprzedzona jest wykonaniem przez Partnera Prywatnego Prac Projektowych, w tym przygotowaniem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. W typowym Projekcie PPP wykonanie tych prac jest obowiązkiem Partnera Prywatnego i tym samym Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za zgodność Prac Projektowych z PFU oraz przepisami prawa.

UWAGA



Jeżeli w Umowie o PPP przewidziano, że Partner Prywatny zobowiązany jest realizować Budowę na podstawie Dokumentacji Projektowej Podmiotu Publicznego, ryzyko związane z Pracami Projektowymi ponosić będzie Podmiot Publiczny. Umowa o PPP powinna w takiej sytuacji regulować kwestię uprawnień do wykorzystania Dokumentacji Projektowej, której autorem nie jest Partner Prywatny np. poprzez przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych lub udzielenie licencji (w przypadku projektów wysoce ustandaryzowanych, co do których Podmiotowi Publicznemu zależy na zachowaniu majątkowych praw autorskich).

DOBRE PRAKTYKI



Dobłą praktyką jest przyjęcie odpowiedzialności przez Podmiot Publiczny za Dokumentację Projektową Podmiotu Publicznego przekazywaną Partnerowi Prywatnemu. W przeciwnym wypadku Partner Prywatny odpowiednio wyceni ryzyka związane z koniecznością wprowadzenia zmian do Dokumentacji Projektowej.

Umowa o PPP przewiduje określone uprawnienia Podmiotu Publicznego w zakresie weryfikowania należytego wykonywania Prac Projektowych, jednak uprawnienia te nie powinny przenosić ryzyka związanego z Pracami Projektowymi na Podmiot Publiczny.

Na podstawie przygotowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej Partner Prywatny powinien ponosić odpowiedzialność za pozyskanie odpowiednich Decyzji Administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie).

W Umowie o PPP w celu uniknięcia wątpliwości można zaznaczyć, że Partner Prywatny w Przedsięwzięciu sprawować będzie funkcję inwestora w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane i uzyskiwać będzie Decyzje Administracyjne w swoim imieniu i na swoją rzecz.

UWAGA



W sytuacji, w której zgodnie z Przepisami Prawa dana Decyzja Administracyjna będzie mogła zostać uzyskana jedynie przez Podmiot Publiczny, Partner Prywatny uzyska takie pozwolenie, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego oraz w tym celu Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu lub wskazanej przez Partnera Prywatnego osobie fizycznej niezbędnych, skutecznych pełnomocnictw, w tym do reprezentacji w postępowaniach administracyjnych.

W przypadku, gdy to Partner Prywatny jest zobowiązany do uzyskania Decyzji Administracyjnych, ryzyko ich niewydania lub wydania w sposób niezgodny z Przepisami Prawa lub poza terminem ustawowym alokowane powinno być po stronie Podmiotu Publicznego, z zastrzeżeniem, że powyższe ryzyko nie wynika z czynności lub zaniechania leżących po stronie Partnera Prywatnego (np. w przypadku złożenia przez Partnera Prywatnego wniosku zawierającego błędy formalne lub wniosku niekompletnego).

Partner Prywatny, kształtując swoją Ofertę, zakłada określone koszty w oparciu o typowe ryzyka związane z postępowaniami administracyjnymi. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, nieleżących po stronie Partnera Prywatnego, zaistnieje konieczność zmiany harmonogramu lub poniesienia dodatkowych kosztów, to Umowa o PPP powinna zakładać, że takie okoliczności są neutralne dla Partnera Prywatnego tj. harmonogram zostanie odpowiednio zaktualizowany oraz wynagrodzenie zostanie odpowiednio podwyższone.

Istotne jest również, aby Partner Prywatny przeniósł autorskie prawa majątkowe do wykonanej przez siebie Dokumentacji Projektowej w ramach procedury monitorowania i kontroli Prac Projektowych przewidzianej w Umowie o PPP – może okazać się to niezbędne w przypadku przebudowy czy modernizacji Infrastruktury Publicznej po przekazaniu jej Podmiotowi Publicznemu.

MAŁE PROJEKTY



W przypadku Małych Projektów za opracowanie Dokumentacji Projektowej również odpowiada Partner Prywatny.

Niemniej, w Małych Projektach znacznie częściej zdarza się, że Podmiot Publiczny dysponuje już gotową Dokumentacją Projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W takich przypadkach odpowiedzialność za Dokumentację Projektową spoczywać będzie na Podmiocie Publicznym.

2.2 Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV	
Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy techniczne	
Tom I: Część II Punkt 3.3 – Analizy ryzyka	
Tom IV: Część II Punkt 1.4 – Ryzyka i roszczenia	
Tom IV: Część II Punkt 2.4 – Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział	

Jak przedstawiono w powyższym punkcie, Dokumentacja Projektowa może zostać sporządzona przez Partnera Prywatnego albo przez Podmiot Publiczny.

W przypadku sporządzenia Dokumentacji Projektowej przez Partnera Prywatnego do ryzyk Podmiotu Publicznego (oraz możliwych przypadków kompensacyjnych) należy zaliczyć:

- 1) opóźnienia organów, które nie wynikają z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny;
- 2) stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmianę jakiejkolwiek Decyzji Administracyjnej, o ile nie wynika to z winy Partnera Prywatnego;
- 3) złożenie odwołania przez stronę trzecią od prawidłowo uzyskanej przez Partnera Prywatnego Decyzji Administracyjnej bądź złożenie zażalenia na wydane postanowienie, o ile nie wynika z winy Partnera Prywatnego;
- 4) bezpodstawną odmowę lub niewydanie przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej (np. przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, dystrybutora/operatora sieci elektroenergetycznej, gazu itp.) uzgodnień, zatwierdzeń lub opinii z przyczyn, które nie leżą po stronie Partnera Prywatnego;
- 5) zmianę prawa rozszerzającą obowiązki Partnera Prywatnego.

W przypadku sporządzenia Dokumentacji Projektowej przez Podmiot Publiczny, do ryzyk Podmiotu Publicznego (oraz możliwych przypadków kompensacyjnych) należy zaliczyć:

- 1) wady w Dokumentacji Projektowej (błędy, informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, np. w zakresie stanu Nieruchomości);
- 2) nieprzeniesienie autorskich praw majątkowych albo nieudzielenie licencji w wymaganym zakresie;
- 3) zmianę prawa rozszerzającą obowiązki Partnera Prywatnego.

2.3 Procedura monitorowania i kontroli Prac Projektowych

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV	
Tom IV: Część II Punkt 3.1 – Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU	

Zakończenie Prac Projektowych

Ryzyko związane z jakością Prac Projektowych w Umowie o PPP jest alokowane po stronie Partnera Prywatnego. To Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za realizację Robót na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej i tym samym wszelkie jej wady będą usuwane na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. Oczywiście Partner Prywatny przenosi ryzyka związane z Pracami Projektowymi na Podwykonawcę. Powyższe nie oznacza jednak, że na etapie wykonywania Prac Projektowych Podmiot Publiczny nie jest zainteresowany ich jakością. Dlatego Umowa o PPP powinna przewidywać określone uprawnienia Podmiotu Publicznego w zakresie weryfikowania należytego wykonywania Prac Projektowych, jednak uprawnienia te nie powinny przenosić ryzyka związanego z Pracami Projektowymi na Podmiot Publiczny. Dlatego też procedury zawarte w Umowie o PPP dotyczące weryfikacji Prac Projektowych nie mają charakteru procedur odbiorowych.

DOBRE PRAKTYKI



W Projektach PPP jakość Prac Projektowych jest weryfikowana na kilku poziomach. Podmiot Publiczny wykonuje swoje uprawnienia kontrolne oraz w zakresie monitorowania postępu i jakości prac często przy pomocy Niezależnego Inżyniera. Partner Prywatny kontroluje swojego Podwykonawcę. Prace Projektowe podlegają procedurze odbiorowej, a Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za ich jakość w określonym w umowie z Podwykonawcą okresie gwarancji.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Podmiot Publiczny oraz Niezależny Inżynier uprawniony będzie do monitorowania przebiegu prac nad Dokumentacją Projektową. W tym celu Partner Prywatny zapewni Podmiotowi Publicznemu lub Niezależnemu Inżynierowi, na jego żądanie, wgląd do przygotowywanej Dokumentacji Projektowej w terminie [...] (słownie: [...]) Dni Roboczych od dnia doręczenia Partnerowi Prywatnemu takiego żądania.
- 2) Podmiot Publiczny lub Niezależny Inżynier będzie mógł zgłaszać Partnerowi Prywatnemu pytania oraz uwagi dotyczące Dokumentacji Projektowej oraz przebiegu Prac Projektowych w sposób nieutrudniający ich prowadzenia.
- 3) W terminie [...] (słownie: [...]) Dni Roboczych od dnia doręczenia Niezależnemu Inżynierowi Dokumentacji Projektowej w formacie umożliwiającym jej odczytanie i analizę, Niezależny Inżynier będzie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń i uwag co do niezgodności Dokumentacji Projektowej z Umową o PPP.
- 4) Zastrzeżenia i uwagi Niezależnego Inżyniera, wskazujące na brak zgodności Dokumentacji Projektowej z Umową o PPP zostaną uwzględnione przez Partnera Prywatnego w terminie [...] (słownie: [...]) Dni Roboczych, chyba że Partner Prywatny w tym terminie w sposób jednoznaczny wykaże niezasadność zastrzeżeń i uwag Niezależnego Inżyniera. W takim przypadku Niezależny Inżynier może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części w terminie [...] (słownie: [...]) Dni Roboczych.

- 5) W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń i uwag Niezależnego Inżyniera, Niezależny Inżynier może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do tak zmienionej Dokumentacji Projektowej w terminie [...] (słownie: [...]). Nowe uwagi i zastrzeżenia Niezależnego Inżyniera nie mogą dotyczyć tej części Dokumentacji Projektowej, do której wcześniej nie wnosił on uwag i zastrzeżeń oraz kwestii, które w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów zostały rozstrzygnięte na korzyść Partnera Prywatnego.
- 6) W przypadku powstania sporu co do zasadności uwag lub zastrzeżeń Niezależnego Inżyniera lub Podmiotu Publicznego, spór ten zostanie poddany rozstrzygnięciu zgodnie z Procedurą Rozwiązywania Sporów. Jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, zastrzeżenia i uwagi Niezależnego Inżyniera okażą się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.
- 7) Żadna ocena Dokumentacji Projektowej dokonana przez Niezależnego Inżyniera lub Podmiot Publiczny nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za Prace Projektowe na mocy postanowień Umowy.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP w sektorze drogowym zaangażowanie doradcy technicznego Instytucji Finansujących było w ocenie Podmiotu Publicznego wystarczające na tyle, że w okresie Prac Projektowych nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do weryfikacji Dokumentacji Projektowej.

W zakresie Projektu Budowlanego stanowiącego wniosek o wydanie ZRID dokonał weryfikacji kontroli.

2.4 Teren Robót

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom IV: Część II Punkt 3.4 – Bezpieczeństwo robót

Umowa o PPP powinna przewidywać, że Podmiot Publiczny przekaze Partnerowi Prywatnemu protokolarnie Teren Budowy w terminie określonym w harmonogramie. W dniu przejęcia Terenu Budowy przez Partnera Prywatnego przechodzą na niego ryzyka i odpowiedzialność za Teren Budowy.

Klauzule umowne w tym zakresie powinny obejmować odpowiedzialność za należyte i zgodne z przepisami prawa przygotowanie, utrzymywanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy, w tym m.in.:

- właściwe oznakowanie Terenu Budowy;
- zapewnienie dozoru mienia na Terenie Budowy;
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- ochronę przeciwpożarową na Terenie Budowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Budowy przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robót Budowlanych;
- dbanie o porządek na Terenie Budowy, w tym uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót Budowlanych;
- wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym: wytyczenie geodezyjne obiektów w Terenie Budowy, wykonanie niwelacji Terenu Budowy, zagospodarowanie Terenu Budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby Robót;
- uregulowanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami (Partner Prywatny powinien zobowiązać się do gospodarowania odpadami zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa) oraz określenie zasad magazynowania odpadów na Terenie Budowy;
- zobowiązanie do uporządkowania i oczyszczenia Terenu Budowy, nieruchomości sąsiednich i dróg dojazdowych oraz w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód przez Partnera Prywatnego naprawienia takiej szkody.

2.5 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy techniczne

Tom IV: Część II Punkt 3.2 – Harmonogram Etapu Inwestycyjnego

Tom IV: Część II Punkt 3.3 – Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

Klauzule umowne dotyczące wykonywania Robót Budowlanych powinny obejmować m.in.:

- zobowiązanie Partnera Prywatnego do wykonania Robót Budowlanych w sposób zgodny z Umową, w tym z PFU, Decyzjami Administracyjnymi, harmonogramem, przepisami prawa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i wyburzeniowych;
- wykonanie inwentaryzacji Nieruchomości (a w uzasadnionych przypadkach nawet nieruchomości sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń ich właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi Robotami Budowlanymi);
- postanowienia nakładające na Partnera Prywatnego obowiązek przestrzegania zasad BHP;
- wymogi dot. personelu Partnera Prywatnego, co może być zasadne w przypadku skomplikowanych technologicznie projektów;
- uregulowanie kwestii dot. dostępu do mediów w okresie budowy (Podmiot Publiczny może udostępnić Partnerowi Prywatnemu dostęp do mediów, z zastrzeżeniem zwrotu kosztów);
- nałożenie dodatkowych obowiązków informacyjnych, np. Partner Prywatny może zostać zobowiązany do informowania Podmiotu Publicznego o każdym zagrożeniu wyrządzenia szkody w środowisku;
- częstotliwość przekazywania okresowych (np. miesięcznych) raportów z Budowy;

- obowiązek powołania kierownika budowy, posiadającego niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do kierowania Robotami Budowlanymi, a także zapewnienie nadzoru nad Robotami Budowlanymi przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia w odpowiednich specjalnościach;
- zobowiązanie Partnera Prywatnego do używania przy realizacji Robót Budowlanych jedynie nowych materiałów budowlanych, spełniających wymogi i standardy jakościowe odpowiednie dla Przedsięwzięcia oraz spełniających standardy polskie i Unii Europejskiej.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie o PPP (najczęściej jako przypadki kompensacyjne czy siła wyższa), Partner Prywatny powinien ponosić ryzyko wzrostu kosztów i opóźnień wykonywania Budowy.

Termin ukończenia Budowy powinien zostać określony w Umowie o PPP. Umowa o PPP powinna też określać konsekwencje i zasady wprowadzania zmian wynikających ze skrócenia lub wydłużenia Okresu Budowy.

Wysokość przewidzianej w Umowie o PPP kary umownej za zwłokę powinna zostać określona w sposób proporcjonalny i celowościowy, tak aby spełniała swoje funkcje, tj. funkcję prewencyjną, kompensacyjną i represyjną. Jednocześnie nie może być nadmierna, ponieważ będzie to skutkować wyższą ceną ofertową (Partner Prywatny, wyliczając cenę, będzie przyjmować określone założenia co do ewentualnych kar umownych) oraz finalnie może skutkować niemożnością dochodzenia kar umownych w pełnej wysokości na skutek – w przypadku sporu – zastosowania przez sąd instytucji miarkowania kary.

UWAGA



Projekty PPP mogą obejmować nie tylko inwestycje *greenfield*, ale również projekty *brownfield* obejmujące np. rozbudowę istniejącej infrastruktury. Tym samym w niektórych przypadkach rozbudowa czy modernizacja dotyczyć będzie funkcjonującej infrastruktury. W takich przypadkach Podmiot Publiczny powinien określić warunki i oczekiwania co do funkcjonowania istniejącej infrastruktury podczas Robót (np. na podstawie tymczasowej organizacji ruchu).

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami Podmiot Publiczny zaplanował rozbudowę istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W trakcie Budowy Podmiot Publiczny wymagał od Partnera Prywatnego ciągłej eksploatacji części instalacji i określił oczekiwane parametry co do ilości i kaloryczności przetwarzanych odpadów.

PRZYKŁAD



Innym przykładem może być remont albo rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej czy szynowej. W takich projektach Partner Prywatny przygotowuje projekt organizacji ruchu, który podlega uzgodnieniu z zarządcą drogi.

2.6 Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Robót

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy techniczne

Tom I: Część II Punkt 3.3 – Analizy ryzyka

Tom IV: Część II Punkt 1.4 – Ryzyka i roszczenia

Tom IV: Część II Punkt 2.4 – Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział

Do ryzyk standardowo przejmowanych przez Podmiot Publiczny w zakresie Robót należy zaliczyć:

- 1) nieprzekazanie Nieruchomości/Terenu Budowy przez Podmiot Publiczny w terminie wynikającym z harmonogramu;
- 2) zakłócenie prawa Partnera Prywatnego do korzystania z Nieruchomości (np. na skutek roszczeń podmiotów trzecich);
- 3) stan Nieruchomości inny niż wynikający z dokumentacji przekazanej Partnerowi Prywatnemu, np. w zakresie znalezisk archeologicznych, infrastruktury podziemnej nieujawnionej w mapach i rejestrach, zanieczyszczeń, nośności podłoża innej niż określonej w dokumentach Podmiotu Publicznego;
- 4) opóźnienie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających np. z umowy przyłączeniowej, co uniemożliwia ukończenie Projektu;
- 5) wystąpienie określonych warunków atmosferycznych (które nie będą kwalifikowane jako zdarzenie siły wyższej), uniemożliwiających realizację określonych Robót Budowlanych;
- 6) zmianę prawa rozszerzającą obowiązki Partnera Prywatnego.

Umowa o PPP z reguły definiuje tego typu zdarzenia jako przypadki kompensacyjne. Umowa o PPP powinna wprost określać, które sytuacje stanowią przypadek kompensacyjny.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia Partnera Prywatnego, że w dacie zawarcia Umowy posiada tytuł prawny niezbędny do realizacji Przedsięwzięcia oraz w dacie zawarcia Umowy:

- 1) nieruchomość jest wolna od praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie toczą się żadne postępowania sporne dotyczące tytułu własności do Nieruchomości ani nie są mu znane jakiegokolwiek roszczenia repriwatyzacyjne osób trzecich, które mogłyby zostać podniesione

w odniesieniu do Nieruchomości – jakiegokolwiek takie prawa lub roszczenia osób trzecich stanowić będą Przypadek Kompensacyjny;

- 2) w obrębie Nieruchomości nie znajduje się żadna podziemna infrastruktura techniczna, kolizyjna z Robotami, poza wykazaną w dokumentach Podmiotu Publicznego – natrafienie na niewykazaną w dokumentach Podmiotu Publicznego infrastrukturę techniczną podziemną kolizyjną z Robotami stanowi Przypadek Kompensacyjny;
- 3) nie zostały w gruncie Nieruchomości rozpoznane takie zanieczyszczenia, czy też działania, zdarzenia, zaniechania, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – konieczność podjęcia takich działań naprawczych w Nieruchomości stanowić będzie Przypadek Kompensacyjny;
- 4) nie rozpoznano w obrębie Nieruchomości żadnych Złazisk – natrafienie na Złazisko stanowi Przypadek Kompensacyjny;
- 5) potwierdza występowanie grup nośności podłoża w obrębie Nieruchomości jak wskazano w dokumentach Podmiotu Publicznego. Wystąpienie grupy nośności podłoża w obszarze Nieruchomości, powodującej konieczność poniesienia większych nakładów inwestycyjnych niż przyjęte w Ofercie, stanowi Przypadek Kompensacyjny.

Umowa o PPP określa również zasady zgłaszania oraz rozliczania przypadków kompensacyjnych (zob. Część II Punkt 5.2 Przypadek kompensacyjny i przypadek dostosowania).

2.7 Procedura monitorowania i kontroli Robót

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom IV: Część II Punkt 3.3 – Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

Tom IV: Część II Punkt 3.5 – Zakończenie robót budowlanych

Zakończenie Robót

W Projektach PPP procedury angażujące Podmiot Publiczny w odbiory Robót mają odmienny charakter od odbiorów Robót w tradycyjnych zamówieniach publicznych. Związane to jest przede wszystkim z okolicznością, że Podmiot Publiczny nie przejmuje odpowiedzialności za Infrastrukturę Publiczną po dokonanych odbiorze końcowym, płaci Wynagrodzenie w sposób okresowy i w wysokości zależnej od jakości świadczonych w przyszłości usług Utrzymania i Dostępności.

Odbiory w Projektach PPP nie mają na celu faktycznego przejęcia Infrastruktury Publicznej przez Podmiot Publiczny, lecz przede wszystkim dostarczenie Podmiotowi Publicznemu informacji na temat postępu Robót na danym ich etapie i umożliwienie mu na tym etapie zgłoszenia uwag, co nie może zwalniać Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za jakość Robót.

DOBRE PRAKTYKI



W Projektach PPP, podobnie jak w przypadku Prac Projektowych, jakość Robót jest weryfikowana na kilku poziomach, a Podmiot Publiczny wykonuje swoje uprawnienia kontrolne oraz w zakresie monitorowania postępu i jakości Robót często przy pomocy Niezależnego Inżyniera. Ponadto, Instytucje Finansujące kontrolują postęp Robót przy pomocy swojego doradcy technicznego, który w określonych w dokumentacji finansowania interwałach jest uprawniony i zobowiązany do wydawania certyfikatu potwierdzającego wykonanie określonych kamieni milowych lub ocenia progres Robót. Certyfikat jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty transzy przez Instytucje Finansujące.

Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych Robót przez cały Okres Obowiązywania Umowy w ramach odpowiedzialności za jakość Infrastruktury Publicznej. W Projektach, w których rolę inwestora pełnić będzie Podmiot Publiczny, odbiory dokonywane będą przez inspektora nadzoru zakontraktowanego przez Podmiot Publiczny na zasadach ogólnych.

W tych Projektach PPP, w których z punktu widzenia technicznego istotna jest dla Podmiotu Publicznego wzmożona kontrola spełnienia wymagań przez infrastrukturę, w Umowie o PPP znaleźć powinny się klauzule dotyczące procedury "odbiorów" Robót częściowych i ulegających zakryciu. Procedura taka uwzględniona może zostać w PFU w ramach specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów Robót Budowlanych.

Przeprowadzenie procedury odbiorowej i wydanie protokołu zakończenia Budowy nie powinno zwalniać Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za jakość Budowy i tym samym z zobowiązań dotyczących należytego Utrzymania Infrastruktury Publicznej. Ryzyko związane z Robotami jest alokowane bowiem po stronie Partnera Prywatnego. To Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za jakość Robót, która oceniana jest w szczególności na etapie Utrzymania i tym samym wszelkie ich wady będą usuwane na koszt oraz ryzyko Partnera Prywatnego. Partner Prywatny przenosi ryzyka związane z Robotami na Podwykonawcę.

Umowa o PPP przewiduje istotne zaangażowanie Podmiotu Publicznego i Niezależnego Inżyniera w procedurach odbiorowych przeprowadzanych przez Partnera Prywatnego. Na etapie odbiorów częściowych, w tym w odniesieniu do Robót ulegających zakryciu, przeprowadzanych pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podwykonawcami Podmiot Publiczny i Niezależny Inżynier są z reguły uczestnikami takich odbiorów z prawem do zgłaszania zastrzeżeń. Podobnie jest w przypadku odbioru końcowego.

Jakikolwiek udział Podmiotu Publicznego i Niezależnego Inżyniera w procedurach odbiorowych czy wykonywanie uprawnień kontrolnych lub weryfikujących nie powinny przenosić ryzyka związanego z Robotami na Podmiot Publiczny. Dlatego też procedury zawarte w Umowie o PPP dotyczące weryfikacji Robót nie mają charakteru procedur odbiorowych w rozumieniu umowy o roboty budowlane, nawet jeśli w taki sposób zostały nazwane w Umowie o PPP.

Umowy o PPP przewidują szczegółowe procedury kończące etap Robót, a w przypadku dużych Projektów z reguły uwzględniają w nich istotną rolę Niezależnego Inżyniera. Niezależny Inżynier wydaje tzw. certyfikat czy świadectwo zakończenia Budowy, który jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę do rozpoczęcia płatności Opłaty za Dostępność.

W niektórych Projektach PPP zasadne będzie rozważenie protokołu wstępnego zakończenia Robót jako dokumentu wystarczającego dla rozpoczęcia płatności ze strony Podmiotu Publicznego. Dotyczy to w szczególności takich projektów, w których Użytkownicy mogą korzystać z Infrastruktury Publicznej w sposób komfortowy w czasie kończenia drobnych Robót i usuwania wad nieistotnych.

PRZYKŁAD



W projektach drogowych może być zasadne udostępnienie Infrastruktury Publicznej Użytkownikom i rozpoczęcie płatności przy jednoczesnym prowadzeniu drobnych prac wykończeniowych. Dla Użytkowników bowiem drobne prace wykończeniowe (na przykład nasadzenia) nie mają najczęściej wpływu na możliwość bezpiecznego korzystania z drogi. Podejście takie nie byłoby rekomendowane dla budynków użyteczności publicznej, gdzie prowadzenie dalszych prac w budynku mogłoby naruszać zasady bezpieczeństwa oraz komfort Użytkowników.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Gdy Partner Prywatny uzna, że Budowa została ukończona, wówczas zawiadomi na piśmie Niezależnego Inżyniera oraz Podmiot Publiczny, wzywając do rozpoczęcia czynności kontrolnych.
- 2) Czynności kontrolne z wykonania Budowy zostaną przeprowadzone i zakończone przez Niezależnego Inżyniera oraz Podmiot Publiczny w terminie [...] dni od dnia otrzymania powiadomienia od Partnera Prywatnego.
- 3) Po uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym, Niezależny Inżynier w terminie [...] Dni Roboczych od zakończenia kontroli wykonania Budowy powiadomi Partnera Prywatnego o tym, że:
 - prace dotyczące zgłoszonej do czynności kontrolnych Budowy nie zostały nawet wstępnie ukończone. W takim przypadku (i) Infrastruktura Publiczna nie może być użytkowana do czasu uzyskania Protokołu Wstępnego Zakończenia Budowy albo Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy oraz (ii) Partner Prywatny będzie kontynuował Budowę, a w szczególności takie prace, jakie Niezależny Inżynier wskaże jako niezakończone i uniemożliwiające wydanie Protokołu Ostatecznego Zakończenia. Po zakończeniu takich prac Partner Prywatny ponownie złoży zawiadomienie o zakończeniu Budowy; albo
 - prace dotyczące zgłoszonej do czynności kontrolnych Budowy zostały wstępnie ukończone, tzn. niektóre pozostające do ukończenia Roboty są nadal wykonywane, ale Infrastruktura Publiczna może być użytkowana zgodnie z Przepisami Prawa (z zastrzeżeniem uzyskania przez Partnera Prywatnego Decyzji Administracyjnych, niezbędnych do użytkowania Infrastruktury Publicznej). W takiej sytuacji Niezależny Inżynier dołączy do takiego powiadomienia Protokół Wstępnego Zakończenia Budowy, o ile Partner Prywatny uzyskał Decyzje Administracyjne niezbędne do użytkowania Infrastruktury Publicznej. Protokół Wstępnego Zakończenia Budowy wskazywać będzie

zakres Robót i innych prac niezbędnych do uzyskania Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy oraz termin wykonania tych Robót i innych prac uwzględniający ich zakres oraz możliwości techniczne i technologiczne ich wykonania. Z chwilą zakończenia Robót wskazanych w Protokole Wstępnego Zakończenia Budowy, Partner Prywatny wystąpi do Niezależnego Inżyniera z wnioskiem o wydanie Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy; albo

- prace dotyczące zgłoszonej do czynności kontrolnych Budowy zostały ukończone zgodnie z Umową. W takiej sytuacji Niezależny Inżynier dołączy do takiego powiadomienia Protokół Ostatecznego Zakończenia Budowy, o ile Partner Prywatny uzyskał Decyzje Administracyjne niezbędne do użytkowania Infrastruktury Publicznej.
- 4) Wydanie Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy stanowi podstawę do rozpoczęcia otrzymywania przez Partnera Prywatnego Wynagrodzenia, natomiast nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za jakość Budowy i tym samym ze zobowiązań dotyczących należytego Utrzymania Infrastruktury Publicznej.
- 5) W przypadku, gdy Protokół Ostatecznego Zakończenia Budowy zostanie wydany przed terminem ustalonym w harmonogramie jako Data Zakończenia Budowy, wówczas Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do rozpoczęcia płatności od Daty Zakończenia Budowy ustalonej w harmonogramie.
- 6) Wydanie Protokołu Wstępnego Zakończenia Budowy może stanowić podstawę do rozpoczęcia otrzymywania przez Partnera Prywatnego Wynagrodzenia, jeżeli Roboty pozostające do wykonania nie będą utrudniać korzystania z Infrastruktury Publicznej Podmiotowi Publicznemu oraz Użytkownikom. Wydanie Protokołu Wstępnego Zakończenia Budowy nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za jakość Budowy i tym samym ze zobowiązań dotyczących należytego Utrzymania Infrastruktury Publicznej, jak również z wykonania prac przewidzianych w treści Protokołu Wstępnego Zakończenia Budowy.

3. Okres Utrzymania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.2.5 – Metodyka wyznaczania Kluczowych Wskaźników Efektywności
Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja techniczna
Tom IV: Część II Punkt 1.7 – Monitorowanie Dostępności i jakości świadczonych usług
Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Wstępne określenie Standardów Utrzymania
Tom IV: Część II Punkt 4.1 – Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej

3.1 Informacje ogólne

Świadczenie usług Utrzymania lub Zarządzania dotyczących składnika majątkowego, który jest wykorzystywany do realizacji Projektu PPP lub jest z nim związany jest nieodłącznym elementem definicji Przedsięwzięcia zawartej w art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP. Oznacza to, że w ramach każdego Projektu PPP musi zostać przewidziany komponent świadczenia przez Partnera Prywatnego usług Zarządzania lub Utrzymania. Takie usługi świadczone są w Okresie Utrzymania, który jest ze swej istoty okresem wieloletnim i w którym dochodzi między innymi do spłaty zaciągniętego przez Partnera Prywatnego Finansowania (w celu uprzedniego pokrycia kosztów Projektowania i Budowy).

Głównym celem Partnera Prywatnego w Okresie Utrzymania jest zatem spłata zaciągniętego Finansowania oraz osiągnięcie zysku z realizacji Przedsięwzięcia. Dopiero bowiem w Okresie Utrzymania Partner Prywatny otrzymuje Wynagrodzenie. Dlatego też Partnerzy Prywatni oraz Instytucje Finansujące zwracają szczególną uwagę na zadania i ryzyka stron Umowy o PPP w Okresie Utrzymania. W interesie Partnera Prywatnego i Instytucji Finansujących jest to, aby w Okresie Utrzymania uzyskać stały strumień przychodów z Przedsięwzięcia (np. Opłaty za Dostępność).

Interes strony prywatnej i Instytucji Finansujących musi jednak zostać pogodzony z celami Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania, które skupiają się wokół zapewnienia odpowiedniego standardu i jakości Utrzymania lub Zarządzania. Podmiot Publiczny bowiem decyduje się uiszczać Wynagrodzenie w Okresie Utrzymania, jednakże jest ustawowo zobowiązany (art. 7 ust. 2 Ustawy o PPP) do uzależnienia swoich płatności od faktycznej Dostępności Infrastruktury Publicznej (w Projektach PPP, w których ryzyko popytu ponosi Podmiot Publiczny). W interesie Podmiotu Publicznego leży to, by Infrastruktura Publiczna była dostępna. Dzięki temu możliwe jest właściwe korzystanie z niej przez Podmiot Publiczny czy innych użytkowników końcowych (np. mieszkańców załatwiających swoje sprawy w budynku urzędu gminy). Dostępność Infrastruktury Publicznej ściśle związana jest ze świadczeniem przez Partnera Prywatnego usług Utrzymania i Zarządzania. Prawidłowa ich realizacja powinna skutkować zapewnieniem Dostępności Infrastruktury Publicznej. Na Dostępność jednak wpływać mogą również okoliczności/przyczyny, za których wystąpienie nie odpowiada Partner Prywatny, np. nieprawidłowe korzystanie z Infrastruktury Publicznej przez Podmiot Publiczny.

Z powyższych przyczyn Umowa o PPP powinna określać szczegółowe obowiązki stron w Okresie Utrzymania, które związane będą z Zarządzaniem, Utrzymaniem oraz używaniem Infrastruktury Publicznej.

3.2 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania

Usługi wchodzące w zakres Utrzymania i Zarządzania

Umowa o PPP będzie precyzyjnie określać zakres świadczeń Partnera Prywatnego w Okresie Utrzymania.

W zależności od rodzaju Przedsięwzięcia usługi świadczone przez Partnera Prywatnego w Okresie Utrzymania określone w Umowie o PPP mogą obejmować:

- usługi związane z Zarządzaniem Infrastrukturą Publiczną (ang. *facility management, asset management*);
- usługi związane z Utrzymaniem należytego stanu technicznego Infrastruktury Publicznej (ang. *heavy maintenance*);
- usługi związane z Utrzymaniem elementów wyposażenia Infrastruktury Publicznej, zieleni (ang. *light maintenance*);
- usługi miękkie związane z Utrzymaniem, takie jak sprzątanie, catering, ochrona (ang. *soft services*).

UWAGA



Powyższa próba skatalogowania rodzaju usług Partnera Prywatnego nie wynika z jakiegokolwiek powszechnie uznanego podziału usług Partnera Prywatnego, ani też nie stanowi katalogu zamkniętego. W większości Projektów PPP usługi świadczone przez Partnera Prywatnego będą mogły zostać sklasyfikowane do jednego z powyższych rodzajów usług.

Usługi Zarządzania obejmują wszelkie usługi o charakterze zarządczym świadczone nie tylko w celu zapewnienia należytego wykonania pozostałych usług przez Partnera Prywatnego, ale też optymalnego wykorzystania Infrastruktury Publicznej pod kątem zarówno technicznym, jak i finansowym. W ramach usług Zarządzania Partner Prywatny odpowiedzialny będzie na przykład za skoordynowanie działań pomiędzy wszystkimi Podwykonawcami, optymalizację usług Utrzymania, realizację planów remontowych, umożliwienie wykonywania kontroli przez Podmiot Publiczny itd.

Przez usługi Utrzymania najczęściej rozumie się utrzymanie techniczne takie jak bieżąca konserwacja czy remonty.

W niektórych Projektach PPP można spotkać się z terminem "eksploatacja". Termin ten właściwszy jest dla projektów, w których z samej Infrastruktury Publicznej generowany jest przychód (np. autostrady płatne). Eksploatacja bowiem wiąże się zazwyczaj z pobieraniem określonych pożytków z Infrastruktury Publicznej.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora efektywności energetycznej Partner Prywatny został zobowiązany do zmodernizowania budynku, a następnie jego Utrzymania oraz Zarządzania nim. W zakres wchodziło zarządzanie zużyciem energii oraz zagwarantowanie ustalonych w Standardach Utrzymania KPI dotyczących oszczędności energii (uzależnionych od poziomu zużycia energii). Usługi Zarządzania zatem obejmowały, między innymi, monitoring zużycia energii na odpowiednim poziomie przez zainstalowane w budynku urządzenia, do których Utrzymania zgodnie ze Standardami Utrzymania był również zobowiązany Partner Prywatny. Jednocześnie Utrzymanie urządzeń na odpowiednim, wymaganym przez Standardy Utrzymania poziomie, wpływało na Zarządzanie zużyciem energii, a dokładnie na odpowiedni poziom poboru energii. W tym Projekcie PPP zatem Zarządzanie obejmowało optymalne wykorzystanie Utrzymywanej przez Partnera Prywatnego Infrastruktury Publicznej pod kątem zarówno technicznym, jak i finansowym.

UWAGA



Coraz rzadziej Umowy o PPP obejmują tzw. usługi miękkie, takie jak catering czy sprząatanie, ochrona.

W interesie Podmiotu Publicznego może być zachowanie kontroli nad usługami miękkimi między innymi z następujących powodów:

- optymalizacja związana z wykorzystaniem zasobów własnych (np. w przypadku spółek komunalnych zajmujących się utrzymaniem lekkim dróg);
- optymalizacja związana z możliwością powierzania określonych usług miękkich w ramach cyklicznych przetargów;
- elastyczność co do zmiany usługodawcy w przypadku niesatysfakcjonującej jakości świadczonych usług.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP w sektorze ochrony zdrowia pacjenci zgłaszali skargi odnośnie do jakości cateringu. Podmiot Publiczny nakładał Punkty Karne, lecz nie przynosiło to oczekiwanego rezultatu. W efekcie strony Umowy o PPP postanowiły wyłączyć usługi cateringu z Projektu PPP (w ramach polecenia zmiany). W ten sposób Podmiot Publiczny uzyskał elastyczność i mógł zmieniać firmy cateringowe, aby osiągnąć oczekiwany rezultat.

UWAGA



W Projektach Hybrydowych należyte świadczenie usług Utrzymania i Zarządzania będzie istotne dla zachowania okresu trwałości Projektu. Beneficjent funduszy UE zobowiązany jest zapewnić bowiem tzw. trwałość projektu tj. jego niezakłócone funkcjonowanie, oparte o uzyskane rezultaty, w okresie zazwyczaj 5 lat od rzeczowo-finansowego zakończenia realizacji dofinansowanego projektu.

Należy zaznaczyć, że w treści Umowy o PPP zazwyczaj wskazuje się jedynie ogólne postanowienia dotyczące Utrzymania i Zarządzania, natomiast szczegółowe postanowienia zawarte są w załącznikach do Umowy o PPP dotyczących Standardów Utrzymania (tj. postanowienia dotyczące szczegółowego zakresu, standardu, jakości, oczekiwanego poziomu świadczonych przez Partnera Prywatnego usług) oraz Mechanizmu Wynagradzania (tj. postanowienia dotyczące wpływu nienależytego świadczenia usług przez Partnera Prywatnego na Wynagrodzenie).

Poniżej przedstawiono przykładowe postanowienia ogólne, które mogą znaleźć się w Umowie o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Partner Prywatny zobowiązuje się do Utrzymywania oraz Zarządzania Infrastrukturą Publiczną w sposób zgodny ze Standardami Utrzymania, obowiązującymi Przepisami Prawa oraz należytą starannością.
- 2) Z wyjątkiem okoliczności wyraźnie w Umowie wyłączających taką odpowiedzialność, Partner Prywatny względem Podmiotu Publicznego ponosić będzie skutki nienależytego Utrzymania lub Zarządzania poprzez naliczanie Punktów Karnych, w wysokości określonej w Załączniku pt. Standardy Utrzymania i odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia zgodnie z Załącznikiem pt. Mechanizm Wynagradzania.

Szczegółowe regulacje dotyczące Utrzymania i Zarządzania powinny znaleźć się w załącznikach do Umowy o PPP dotyczących Standardów Utrzymania (dotyczące szczegółowego zakresu, standardu, jakości, oczekiwanego poziomu świadczonych przez Partnera Prywatnego usług) oraz Mechanizmu Wynagradzania (dotyczące wpływu nienależytego świadczenia usług przez Partnera Prywatnego na Wynagrodzenie).

Standardy Utrzymania

Umowa o PPP zawiera precyzyjne zobowiązania stron w zakresie Standardów Utrzymania. Rekomendowaną praktyką jest przygotowanie załącznika do Umowy o PPP, bowiem specyfika usług Zarządzania i Utrzymania jest bardzo szczegółowa i ma charakter techniczny. Wydzielenie szczegółowych postanowień dotyczących Standardów Utrzymania do załącznika jest rozwiązaniem korzystniejszym dla przejrzystości tekstu głównego Umowy o PPP oraz zawartych w nim zobowiązań stron.

Poniżej przedstawiono przykładowe postanowienia ogólne, które mogą znaleźć się w Umowie o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Partner Prywatny zobowiązuje się do utrzymywania Infrastruktury Publicznej w sposób zgodny ze Standardami Utrzymania, obowiązującymi Przepisami Prawa oraz należyłą starannością.
- 2) Partner Prywatny będzie utrzymywać Infrastrukturę Publiczną, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku pt. Standardy Utrzymania.
- 3) Z wyjątkiem okoliczności wyraźnie w Umowie wyłączających taką odpowiedzialność, Partner Prywatny względem Podmiotu Publicznego ponosić będzie skutki nienależytego Utrzymania poprzez naliczanie Punktów Karnych, w wysokości określonej w Załączniku pt. Standardy Utrzymania i odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia zgodnie z Załącznikiem pt. Mechanizm Wynagradzania.
- 4) Partner Prywatny zobowiązuje się do Zarządzania Infrastrukturą Publiczną w sposób zgodny z obowiązującymi Przepisami Prawa oraz należyłą starannością.
- 5) Partner Prywatny będzie zarządzać Infrastrukturą Publiczną zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku pt. Standardy Utrzymania.
- 6) Z wyjątkiem okoliczności wyraźnie w Umowie wyłączających taką odpowiedzialność, Partner Prywatny względem Podmiotu Publicznego ponosić będzie skutki nienależytego Zarządzania poprzez naliczanie Punktów Karnych, w wysokości określonej w Załączniku pt. Standardy Utrzymania i odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia zgodnie z Załącznikiem pt. Mechanizm Wynagradzania.

Załącznik do Umowy o PPP w omawianym zakresie powinien wskazywać wszystkie Standardy Utrzymania, do których zapewnienia zobowiązuje się Partner Prywatny oraz KPI albo częstotliwość wykonywania określonych czynności w ramach Utrzymania i Zarządzania tam, gdzie wskaźnik jakości (KPI) jest trudny lub niemożliwy do zastosowania.

PRZYKŁAD



W przypadku usług sprzątania niezwykle trudno jest ustalić KPI, w związku z czym najczęściej wskazuje się częstotliwość świadczenia usług np. sprzątanie toalet dwa razy dziennie.

Ponadto, należy przypisać określonym Standardom Utrzymania właściwy i oczekiwany czas reakcji, tj. okres, w którym Partner Prywatny powinien usunąć ewentualne uchybienie w zakresie Utrzymania lub Zarządzania, liczony od momentu powstania uchybienia.

W przypadku, gdy zamiast wskaźnika jakości zastosowano częstotliwość, wówczas czas reakcji nie ma zastosowania. Monitorowanie wykonania usług w przypadku czynności określonych poprzez częstotliwość jest oparte o raporty Partnera Prywatnego i wrywkowe kontrole Podmiotu Publicznego. Jest ono stosowane najczęściej, gdy pomiar efektu jest utrudniony lub niezasadny (np. czystość okien).

Ponadto, do każdego Standardu Utrzymania należy przypisać skutki niezachowania Standardu Utrzymania, względnie braku reakcji w określonym czasie reakcji, tj. określoną liczbę Punktów Karnych.

Dla niektórych Standardów Utrzymania należy określać tryb awaryjny w ramach czasu reakcji, tj. mający na celu to, aby w jak najkrótszym możliwym czasie Partner Prywatny doprowadził do należytego Standardu Utrzymania.

Dla przejrzystości można ująć powyższe kwestie w formie tabelarycznej, podzielonej na określone kategorie Standardów Utrzymania. Poniższa tabela zawiera kilka przykładowych Standardów Utrzymania i odpowiadających im KPI w celach poglądowych:

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA				
Lp.	Standard Utrzymania	Wskaźnik jakości (KPI)/ Częstotliwość	Czas reakcji	Punkty Karne
Czystość				
1.	Mycie podłóg w holu głównym i korytarzach	Kompleksowo codziennie po godzinach urzędowania	Nie dotyczy	[...] PK za każde uchybienie
2.	Mycie okien	Raz na pół roku w odstępach co najmniej 5 miesięcy	30 dni od zgłoszenia konieczności mycia okien	[...] PK za każde uchybienie
3.	Usuwanie odpadów (w tym cieczy) w holu głównym i korytarzach	Na podłogach nie mogą zalegać jakiekolwiek odpady, w tym ciecze	Tryb Awaryjny, nie dłuższy niż 15 minut	[...] PK za każde uchybienie
4.	Uzupełnianie środków czystości i higienicznych w toaletach (papier toaletowy, ręczniki, mydła)	Środki czystości mają być dostępne w godzinach Dostępności Infrastruktury Publicznej	15 minut od zgłoszenia braku	[...] PK za każde uchybienie
Utrzymanie zieleni				
1.	Koszenie trawy na trawnikach w obrębie Nieruchomości	W okresie od kwietnia do października raz w tygodniu	Nie dotyczy	[...] PK za każdy m ²
Utrzymanie techniczne				
1.	Malowanie ścian	30% powierzchni raz w roku – zakres według protokołu zapotrzebowania	Nie dotyczy	[...] PK za każdy m ² za każdy tydzień opóźnienia

		Można określić wymagania co do okresu w jakim należy przeprowadzić prace		
2.	Klimatyzacja	Sprawne i działające urządzenia klimatyzacyjne	1 godzina od zgłoszenia awarii	[...] PK za każdy dzień
Utrzymanie elementów wyposażenia				
1.	Meble w recepcji	Meble powinny być funkcjonalne, wolne od wad utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie	Naprawa 12 godzin od zgłoszenia wady	[...] PK za każde [...] godzin.
2.	Biały montaż w toaletach	Urządzenia powinny być funkcjonalne, wolne od wad utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie	Naprawa 12 godzin od zgłoszenia wady	[...] PK za każde [...] godzin

Konsekwencje niedotrzymania Standardów Utrzymania

Umowa o PPP określać musi odpowiedzialność za Utrzymanie zgodnie z określonymi w niej Standardami Utrzymania. Niedotrzymanie Standardów Utrzymania powinno być sankcjonowane poprzez odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia.

Zazwyczaj stosowanym rozwiązaniem jest naliczenie Partnerowi Prywatnemu tzw. Punktów Karnych. Wystąpienie któregośkolwiek ze zdarzeń stanowiących przesłankę naliczenia Punktów Karnych będzie skutkowało obciążeniem Partnera Prywatnego Punktami Karnymi (w związku z każdym takim zdarzeniem).

W Umowie o PPP lub załączniku należy również określić wartość 1 Punktu Karnego oraz zasady indeksacji tej wartości. Liczba Punktów Karnych pomnożona przez ich wartość będzie stanowić wartość pomniejszającą Opłatę za Dostępność.

Standardy Utrzymania oraz sankcje w postaci Punktów Karnych powinny motywować Partnerów Prywatnych do wykonywania zadań. Dlatego też liczba Punktów Karnych powinna być dostosowana do uchybienia w taki sposób, aby zapłata Punktów Karnych nie była korzystniejsza niż należyte wykonanie obowiązków przez Partnera Prywatnego.

W tym celu można przewidzieć odrębny KPI dotyczący powtarzających się cyklicznie takich samych uchybień (np. kilka razy w danym okresie) i przypisanie do niego większej liczby Punktów Karnych.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA				
Lp.	Standard Utrzymania	Wskaźnik jakości (KPI)/ Częstotliwość	Czas reakcji	Punkty Karne
Czystość				
1.	Mycie podłóg w holu głównym i korytarzach	Powtarzające się cyklicznie uchybienia (co najmniej 2 razy w okresie tygodnia)	Nie dotyczy	[...] PK za każde uchybienie

Wyłączenia naliczania Punktów Karnych

Umowa o PPP powinna przewidywać wyłączenia naliczania Punktów Karnych w określonych przez strony sytuacjach.

Poniżej przedstawiono przykładowy katalog wyłączeń naliczania Punktów Karnych dla celów poglądowych.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA	
Jeżeli niedotrzymanie Standardów Utrzymania zajdzie na skutek poniżej wskazanych przypadków, Podmiot Publiczny nie będzie uprawniony do naliczenia Punktów Karnych i obniżenia Wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie: 1) wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego, Siły Wyższej lub Polecenia Zmiany; 2) konieczność wykonania prac określonych w Protokole Wstępnego Zakończenia Budowy do czasu wydania Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy; 3) brak Dostępności, na skutek którego Wynagrodzenie zostało obniżone na zasadach określonych w Umowie.	

Ryzyko Dostępności

Umowa o PPP musi regulować kwestię Dostępności Infrastruktury Publicznej. Dostępność postrzegana jest jako możliwość niezakłóconego korzystania z Infrastruktury Publicznej przez Użytkowników.

UWAGA	
Dostępność Infrastruktury Publicznej może być postrzegana jako możliwość korzystania z niej (np. otwarte lub zamknięte sale operacyjne), ale też w szerszym kontekście jako korzystanie z niej z uwzględnieniem Standardów Utrzymania (np. czysta toaleta). W pierwszym przypadku Partner Prywatny otrzyma pomniejszone proporcjonalnie Wynagrodzenie z tytułu niedotrzymania oczekiwanego poziomu Dostępności. W drugim nałożone zostaną na niego Punkty Karne za niedotrzymanie KPI.	

W tekście głównym Umowy o PPP powinny znaleźć się ogólne zobowiązania Partnera Prywatnego dotyczące zapewnienia Dostępności oraz ogólne zasady dotyczące konsekwencji nienależytego świadczenia usług Dostępności (ograniczona Dostępność Infrastruktury Publicznej powinna powodować odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia). Poniżej przedstawiono przykładowe postanowienia ogólne, które mogą znaleźć się w Umowie o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Z zastrzeżeniem wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, Polecenia Zmiany, Siły Wyższej skutkujących ograniczeniem Dostępności lub innych okoliczności wskazanych wyraźnie w Umowie, Partner Prywatny ponosi ryzyko związane z Dostępnością Infrastruktury Publicznej.
- 2) Partner Prywatny zobowiązany jest do zapewnienia Dostępności Infrastruktury Publicznej dla Użytkowników w dniach i godzinach otwarcia dla Użytkowników, jak również dla Podmiotu Publicznego i jego pracowników w dniach i godzinach otwarcia dla Podmiotu Publicznego w sposób zgodny z postanowieniami Załącznika pt. Standardy Utrzymania.
- 3) Z wyjątkiem okoliczności wyraźnie w Umowie wyłączających taką odpowiedzialność, Partner Prywatny względem Podmiotu Publicznego ponosić będzie skutki ograniczenia Dostępności Infrastruktury Publicznej proporcjonalnie do zaistniałych uchybień, w sposób określony w Załączniku pt. Standardy Utrzymania poprzez odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia zgodnie z Załącznikiem pt. Mechanizm Wynagradzania.

Szczegółowe postanowienia dotyczące Dostępności, np. przypadki braku Dostępności i nienależytego świadczenia usług wpływających na zapewnienie Dostępności, powinny zostać określone w załączniku do Umowy o PPP. Zazwyczaj jest to załącznik dotyczący Standardów Utrzymania.

UWAGA



Sposób sformułowania klauzul umownych dotyczących Dostępności oraz jej wpływu na wysokość Wynagrodzenia ma istotny wpływ na przeniesienie na Partnera Prywatnego ryzyka Dostępności.

Konsekwencje braku Dostępności

Brak Dostępności powinien być sankcjonowany proporcjonalnie, zgodnie z zasadą "brak dostępności, brak płatności". Tym samym Wynagrodzenie należne Partnerowi Prywatnemu powinno być obniżone proporcjonalnie do braku Dostępności Infrastruktury Publicznej.

Brak Dostępności jest oceniany względem konkretnych elementów Infrastruktury Publicznej. Poniżej przedstawiono przykładowe postanowienia załącznika do Umowy o PPP opisujące przypadek braku Dostępności takich elementów Infrastruktury Publicznej.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Brak Dostępności występuje w następujących sytuacjach:

- 1) pomieszczenie jest w trakcie remontu;
- 2) pomieszczenie jest zalane;
- 3) niesprawna wentylacja lub ogrzewanie uniemożliwia korzystanie z pomieszczenia;
- 4) niesprawne oświetlenie (co najmniej ...% punktów oświetleniowych niedziałających) uniemożliwia korzystanie z pomieszczenia;
- 5) uszkodzona stolarka okienna (np. brak szyby) i drzwiowa (np. wyłamany zamek) uniemożliwia korzystanie z pomieszczenia (np. z toalety);
- 6) nieczynny dźwig osobowy lub inne urządzenia uniemożliwiające korzystanie z Infrastruktury Publicznej przez osoby niepełnosprawne;
- 7) inne przyczyny stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia (np. uszkodzona instalacja elektryczna, rysy konstrukcji nośnej budynku) uniemożliwiające korzystanie z Infrastruktury Publicznej.

Aby ustalić, jaka część Wynagrodzenia będzie podlegać obniżeniu zgodnie z zasadą "brak dostępności, brak płatności" należy każdemu elementowi Infrastruktury Publicznej, którego Dostępność jest oceniana (np. sale operacyjne, sale lekcyjne, recepcja, parking zewnętrzny) przypisać określoną wagę procentową. Dzięki temu, w przypadku zajścia braku Dostępności określonego elementu Infrastruktury Publicznej wiadome będzie o ile procent należy obniżyć należne Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenie (w okresie, w którym ten brak Dostępności wystąpił). Określenie wag procentowych jest istotne, bowiem nie zawsze każde pomieszczenie będzie w równym stopniu istotne z punktu widzenia funkcjonowania i korzystania z Infrastruktury Publicznej. Przykładowo w niskich budynkach użyteczności publicznej niedostępność dźwigów towarowych będzie miała znacznie mniejsze znaczenie w porównaniu do niesprawnego ogrzewania zimą. Możliwe jest przy tym różnicowanie wagi poszczególnych podobnych elementów Infrastruktury Publicznej (np. pomieszczeń – w budynkach użyteczności publicznej inaczej traktowana powinna być niedostępność głównego punktu informacyjnego, a inaczej pomieszczenia techniczno-administracyjnego).

Poniższa tabela zawiera kilka przykładowych wag w zakresie Dostępności określonych pomieszczeń w stosunku do całej Infrastruktury Publicznej.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Lp.	Część Infrastruktury Publicznej	Waga
1.	Pokoje przyjmowania interesantów (kategoria ważności 1)	5% (za każdy pokój)
2.	Pokoje przyjmowania interesantów (kategoria ważności 2)	1% (za każdy pokój)

3.	Główny punkt informacyjny	10%
4.	Toaleta (przy założeniu, że w budynku są cztery toalety)	5% za każde pomieszczenie
5.	Klatka schodowa	80% (przy założeniu, że niedostępność klatki uniemożliwia całkowite korzystanie z górnych kondygnacji obiektu)
6.	Parking zewnętrzny	20%

Należy również pamiętać, że brak Dostępności może dotyczyć całej Infrastruktury Publicznej lub jej części.

PRZYKŁAD



Z brakiem Dostępności mamy do czynienia na przykład w przypadku wyłączenia pasa ruchu w celu prowadzenia prac remontowych. W przypadku budynku użyteczności publicznej brak Dostępności oznaczać będzie niemożność korzystania z części lub wszystkich pomieszczeń budynku zgodnie z ich przeznaczeniem. Zdarzyć się może, iż brak Dostępności części Infrastruktury Publicznej oznaczać będzie *de facto* całkowity jej brak, np. brak Dostępności sal rozpraw w sądzie oznaczać może całkowitą nieprzydatność Infrastruktury Publicznej w tym czasie, pomimo że dostępne są pomieszczenia administracji; brak Dostępności wszystkich sal operacyjnych może być uznany za brak Dostępności szpitala, pomimo Dostępności pomieszczeń ambulatoryjnych.

Usprawiedliwiony brak Dostępności

Umowa o PPP przewiduje przypadki, w których Partner Prywatny nie będzie karany za brak Dostępności. Poniżej przedstawiono przykładowy katalog usprawiedliwionego braku Dostępności dla celów poglądowych.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Jeżeli brak Dostępności zajdzie na skutek poniżej wskazanych przypadków, Podmiot Publiczny nie będzie uprawniony do obniżenia Wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie:

- 1) w przypadku zaplanowanych remontów;
- 2) z uwagi na niedotrzymanie Standardów Utrzymania wynikające z wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, Siły Wyższej lub Polecenia Zmiany;
- 3) w przypadku niedotrzymania Standardów Utrzymania wynikającego z konieczności wykonania prac określonych w Protokole Wstępnego Zakończenia Budowy do czasu wydania Protokołu Ostatecznego Zakończenia Budowy;
- 4) w przypadku zamknięcia Infrastruktury Publicznej na skutek obowiązujących przepisów Prawa, decyzji Podmiotu Publicznego albo Organów Administracji z przyczyn nieleżących po stronie Partnera Prywatnego;

- 5) w przypadku ograniczenia Dostępności Infrastruktury Publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Partnera Prywatnego w wyniku działania innych podmiotów uprawnionych do działań skutkujących ww. ograniczeniem (np. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej).

3.3 Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania

Co do zasady, ryzyko Utrzymania lub Zarządzania powinien ponosić Partner Prywatny, a jedynie w przypadkach ściśle określonych w Umowie o PPP Podmiot Publiczny powinien przejąć jego określoną część. Oznacza to, że tylko w wyjątkowych sytuacjach Podmiot Publiczny będzie ponosił ryzyka w Okresie Utrzymania związane z Utrzymaniem i Zarządzaniem.

W Umowach o PPP zazwyczaj określa się, że Podmiot Publiczny ponosi następujące ryzyka w Okresie Utrzymania (co wiązać będzie się zwykle z zajściem przypadku kompensacyjnego):

- 1) ryzyko wandalizmu (szkód w Infrastrukturze Publicznej powstałych na skutek działań podmiotów, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności);
- 2) ryzyko znalezisk/archeologiczne;
- 3) ryzyko zmiany prawa;
- 4) ryzyko meteorologiczne (np. niemożliwość świadczenia usług z uwagi na temperatury powietrza przekraczające określony w Umowie o PPP próg i które utrzymują się przez określony w niej czas);
- 5) ryzyko działań podmiotów trzecich, które uniemożliwiają należyte świadczenie usług (np. gdy Podmiot Publiczny w części realizuje utrzymanie techniczne budynku, którego nienależyte wykonanie przez Podmiot Publiczny uniemożliwia dotrzymanie przez Partnera Prywatnego KPI w zakresie Utrzymania, bądź zmusza go do wykonania dodatkowych prac).

PRZYKŁAD



Partner Prywatny w hipotetycznym projekcie PPP został zobowiązany w Umowie o PPP do świadczenia usług związanych z Utrzymaniem należytego stanu technicznego serwerowni w budynku biurowym. Tymczasem za usługi związane z Utrzymaniem i Zarządzaniem elementami wyposażenia Infrastruktury Publicznej, takimi jak komputery i sieć (poza serwerownią) odpowiada Podmiot Publiczny. W budynku doszło do awarii komputerów, która spowodowała awarię całej sieci, a w konsekwencji nieodwracalne zmiany w systemach serwerowni. Partner Prywatny został zobowiązany przez Podmiot Publiczny do naprawy serwerowni, jednakże otrzymał za poniesione koszty naprawy rekompensatę, gdyż to awaria komputerów i sieci, za których Utrzymanie i Zarządzanie nie odpowiada Partner Prywatny, spowodowała awarię serwerowni.

W Umowach o PPP Podmiot Publiczny może przyjąć na siebie również określone zobowiązania, np. do:

- 1) zapewnienia infrastruktury Podmiotu Publicznego lub innego podmiotu, niezrealizowanej w ramach Przedsięwzięcia, która jest niezbędna do prawidłowego korzystania, Utrzymania lub Zarządzania Infrastrukturą Publiczną, a najczęściej jest wyłączona z zakresu Projektu (np. falochrony w przypadku portów morskich);

- 2) realizacji części usług z uwagi na ich istotne znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego czy innych celów Podmiotu Publicznego (np. usługi miękkie);
- 3) odpowiedniego ukształtowania infrastruktury otaczającej Infrastrukturę Publiczną lub przyjęcia określonych regulacji prawnych, które wpływają na możliwość korzystania z Infrastruktury Publicznej (np. polityka parkingowa),
- 4) w projektach z sektora transportu intermodalnego (np. centrach przeładunkowych) zazwyczaj konieczne jest zapewnienie określonej infrastruktury (np. dróg dojazdowych, odpowiedniego toru podejściowego do portu morskiego, falochronów), która nie jest zrealizowana w ramach Przedsięwzięcia. Jednocześnie infrastruktura ta jest kluczowa dla możliwości świadczenia usług przez Partnera Prywatnego (np. usług przeładunkowych w centrum przeładunkowym). W takim przypadku Partner Prywatny oczekuje, że Podmiot Publiczny weźmie na siebie ryzyko zapewnienia takiej infrastruktury. Partner Prywatny nie chce bowiem przejmować odpowiedzialności za realizację i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, której nie realizuje w ramach Projektu PPP,
- 5) w projektach z sektora drogowego należy rozważyć przypisanie zadania instalowania ekranów akustycznych po stronie Podmiotu Publicznego w związku z często zmieniającymi się przepisami prawa dotyczącymi wymogów akustycznych.

PRZYKŁAD

W hipotetycznym Projekcie PPP polegającym na budowie parkingu publicznego, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych i przepustowości ulic, wokół których dotychczas parkowano bardzo wiele pojazdów, Podmiot Publiczny zobowiązał się do przyjęcia określonej polityki parkingowej. Zgodnie z nią zakazano postoju i zatrzymywania się w określonej odległości od wybudowanego parkingu publicznego na części ulic. W pozostałych miejscach podwyższono opłaty za parkowanie, tak by były wyższe niż opłata za skorzystanie z wybudowanego parkingu.

4. Wynagrodzenie

4.1 Mechanizm Wynagradzania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.5 – Mechanizm Wynagradzania

Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

Tom IV: Część II Punkt 4.1.4 – Mechanizm wynagradzania

Tom IV: Część II Punkt 4.2 – Zarządzanie płatnościami i rozliczeniami

Informacje ogólne

Umowa o PPP powinna w sposób precyzyjny określać Mechanizm Wynagradzania, w tym wysokość składowych OzD, sposób zapłaty Wynagrodzenia, ewentualne potrącenia lub pomniejszenia. Ponadto Mechanizm Wynagradzania powinien uwzględniać uzgodnione mechanizmy waloryzacyjne. Z reguły Mechanizm Wynagradzania opisany jest w załączniku do Umowy o PPP.

Oplata za Dostępność

Umowa o PPP określa następujące elementy OzD:

- 1) opłatę za Prace Projektowe i Roboty Budowlane, zawierającą koszt nakładów inwestycyjnych oraz koszt Finansowania tych nakładów w Okresie Projektowania i Okresie Budowy;
- 2) opłatę za Usługę Finansową, polegającą na rozłożeniu płatności w czasie (nazywana często opłatą za rozłożenie w czasie);
- 3) opłatę za Utrzymanie i Zarządzanie.

Oplata za Dostępność zwykle należna jest dopiero po zakończeniu Okresu Budowy.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowi Oplata za Dostępność, która obejmuje:
 - Oplatę za Nakłady Inwestycyjne, składającą się z: wynagrodzenia za Prace Projektowe (Okres Projektowania) oraz wynagrodzenia za Nakłady Inwestycyjne (Okres Budowy);
 - Oplatę za Rozłożenie w Czasie;
 - Oplatę za Utrzymanie (Okres Utrzymania).
- 2) Sposób obliczania i płatności Wynagrodzenia został uregulowany w Załączniku pt. Mechanizm Wynagradzania.

- 3) Nieprzedstawienie przez Partnera Prywatnego wyliczeń, wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa poniżej, w sposób umożliwiający Podmiotowi Publicznemu ocenę prawidłowości wyliczenia Wynagrodzenia, powoduje przesunięcie terminu wymagalności roszczenia za dany okres rozliczeniowy do czasu wypełnienia przez Partnera Prywatnego wskazanych obowiązków wobec Podmiotu Publicznego, zgodnie z opisaną poniżej procedurą płatności. Jednakże Podmiot Publiczny może jedynie wstrzymać wypłatę spornych kwot lub części Wynagrodzenia, których prawidłowości nie można ocenić z uwagi na uchybienia Partnera Prywatnego w zakresie obowiązków, o których mowa powyżej.
- 4) Wynagrodzenie może zostać pomniejszone z tytułu Punktów Karnych oraz braku Dostępności, na zasadach określonych w Załączniku pt. Standardy Utrzymania oraz zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku pt. Mechanizm Wynagradzania.
- 5) W przypadku gdy w związku z zastosowaniem pomniejszeń kwota Wynagrodzenia za dany miesiąc przyjmie wartość ujemną, kwota ta podlega rozliczeniu w kolejnych terminach płatności Wynagrodzenia, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń Podmiotu Publicznego z tytułu pomniejszenia.
- 6) Wynagrodzenie podlega indeksacji na zasadach określonych w Załączniku pt. Mechanizm Wynagradzania.

Z reguły Umowa o PPP zawiera algorytm określający składowe OzD oraz mechanizm pomniejszeń.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Opłata za Dostępność będzie naliczana w Okresie Utrzymania zgodnie z następującym wzorem:

$$OzD_{r,m} = ONI_{r,m} + OFNI_{r,m} + OU_{r,m} - PK_{r,m} - PBD_{r,m}$$

gdzie:

$OzD_{r,m}$	OzD w miesiącu m roku r [PLN]
$ONI_{r,m}$	Opłata za Nakłady Inwestycyjne w miesiącu m roku r [PLN]
$OFNI_{r,m}$	Opłata za Rozłożenie w Czasie w miesiącu m roku r [PLN]
$OU_{r,m}$	Opłata za Utrzymanie w miesiącu m roku r [PLN]
$PK_{r,m}$	miesięczne pomniejszenia z tytułu Punktów Karnych [PLN]
$PBD_{r,m}$	miesięczne pomniejszenia z tytułu braku Dostępności [PLN]

Waloryzacja Opłaty za Dostępność

UWAGA



Art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP wyłącza zastosowanie do Umowy o PPP art. 436 pkt 4 lit. b) i art. 439-440 Ustawy PZP zawierających ustawowe regulacje mechanizmów waloryzacyjnych. Podmiot Publiczny nie musi zatem przestrzegać ścisłych reguł w tym zakresie, nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by wzorował postanowienia Umowy o PPP na rozwiązaniach ustawowych, jeżeli nie stoją one w sprzeczności ze specyfiką danego Przedsięwzięcia.

Umowa o PPP w Mechanizmie Wynagradzania uwzględnia jego waloryzację zarówno w odniesieniu do części OzD dotyczącej nakładów inwestycyjnych, jak również Utrzymania.

UWAGA



Partner Prywatny jest narażony na różnego rodzaju wahania rynku, skutkujące wzrostem lub obniżeniem kosztów realizacji nałożonych na niego zobowiązań wieloletnich. W umowach krótkoterminowych zdecydowanie łatwiej jest wycenić ryzyko takich wahań. W Umowach o PPP jest to zadanie bardzo trudne. Brak w Umowie o PPP mechanizmów waloryzacyjnych Wynagrodzenia ostatecznie może prowadzić do zwiększenia ceny wskazanej w Ofercie Partnera Prywatnego. Z pewnością bowiem przyjmie on pewne szacunki co do wahań rynkowych w całym okresie Umowy, które wpłyną na wysokość Wynagrodzenia wskazaną w Ofercie, co może prowadzić w skrajnych przypadkach do otrzymania bardzo drogiej Oferty (np. wykraczających poza przewidziany przez Podmiot Publiczny budżet Projektu). Aby częściowo zmitigować takie ryzyko ("przeszacowania" ceny ofertowej), w Umowach o PPP wprowadza się mechanizm indeksacji Wynagrodzenia. W takim przypadku, Partner Prywatny, przygotowując ofertę i Model Finansowy, jest w stanie nieco dokładniej oszacować kwotę Wynagrodzenia w poszczególnych latach obowiązywania Umowy.

UWAGA



Zazwyczaj waloryzacja odnosi się do konkretnych składowych Wynagrodzenia. W przypadku OzD może zatem ona się odnosić do wyszczególnionych w Mechanizmie Wynagradzania opłat.

Wskaźniki waloryzacyjne powinny zostać dobrane odpowiednio do specyfiki zakresu prac Partnera Prywatnego w Projekcie. Może być to zarówno koszyk różnych wskaźników z przypisanymi im wagami (koszyk waloryzacyjny) lub jeden wskaźnik. Konieczne jest jednak wskazanie takich wskaźników w Umowie o PPP (np. w załączniku dotyczącym Mechanizmu Wynagradzania).

W Umowach o PPP w odniesieniu do części Wynagrodzenia odpowiadającej opłacie za Prace Projektowe i Roboty Budowlane należy przewidzieć mechanizm waloryzacji.

UWAGA



Aktualnie, między innymi z uwagi na praktykę wykształconą podczas pandemii Covid-19 oraz w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie i spowodowanym tymi zdarzeniami wzrostem cen, zarówno w tradycyjnych zamówieniach publicznych i w ślad za tym w Umowach o PPP Wynagrodzenie za Prace Projektowe i Roboty podlega waloryzacji.

Zgodnie z przepisami Ustawy PZP mechanizm waloryzacji musi zostać przewidziany we wszystkich umowach zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy (por. art. 439 ust. 1 Ustawy PZP). Mimo że zastosowanie tego przepisu w stosunku do Umowy o PPP jest wyłączone na mocy Ustawy o PPP, to jednak stanowi on wskazówkę dla Podmiotów Publicznych. Skoro bowiem w klasycznych zamówieniach publicznych (np. dot. robót budowlanych) wymuszone jest stosowanie mechanizmu waloryzacji we wszystkich umowach, których okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, to także w Umowach o PPP część Wynagrodzenia odpowiadająca opłacie za Prace Projektowe i Roboty Budowlane powinna podlegać indeksacji. Zwykle bowiem w Projektach PPP Okres Projektowania oraz Okres Budowy trwają dłużej niż 6 miesięcy (około 1,5 - 3 lat w zależności od skali i stopnia złożoności Projektu PPP).

Kwestia waloryzacji Wynagrodzenia została uznana przez Eurostat jako niewpływająca na dług publiczny przy spełnieniu określonych warunków wskazanych w publikacji pt. Clarification on the application of a Guide to the statistical treatment of PPPs: responses to frequently asked questions, Eurostat, Directorate D – Government Finance Statistics (GFS).

Zazwyczaj w Umowach o PPP w odniesieniu do waloryzacji części Wynagrodzenia odpowiadającej opłacie za Prace Projektowe i Roboty Budowlane wskazywany jest koszyk waloryzacyjny. Zawarte w nim wskaźniki odpowiadają przede wszystkim różnym istotnym materiałom budowlanym, koniecznym do przeprowadzenia Robót, wskaźnikowi CPI czy przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono przykładowy koszyk waloryzacyjny do zastosowania do części OzD dotyczącej opłaty Prace Projektowe i Roboty Budowlane (tzw. opłaty za nakłady inwestycyjne).

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Wskaźnik waloryzacji Nakładów Inwestycyjnych dla danego kwartału "k" roku "r" Okresu Projektowania i Budowy, obliczony w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych w roku "r" dla kwartału "k" zgodnie z poniższym wzorem:

$$WNI_{k,r} = \left(\prod_{Q=1}^k \frac{BM_Q}{100} \right) - 1$$

gdzie BM_Q oznacza publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 50 dni po każdym kwartale wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych. W przypadku, gdy opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wyrażony jest w wartości procentowej, do obliczeń należy przyjąć wartość bezwzględną (np. dla wartości opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 2,5%, do obliczeń BM_Q należy przyjąć wartość 102,5).

W celu uniknięcia wątpliwości wskaźnik waloryzacji liczony jest dla każdego kwartału narastająco od dnia złożenia Oferty do ostatniego dnia Okresu Projektowania i Budowy. W przypadku, jeżeli pierwszy i ostatni kwartał nie pokrywają się z pełnym kwartałem kalendarzowym, wskaźnik waloryzacji dla niepełnego kwartału należy policzyć proporcjonalnie do liczby dni, za którą liczony jest ten wskaźnik.

DOBRE PRAKTYKI



Jeżeli Roboty Budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekraczają okres ustalony w Umowie o PPP na potrzeby waloryzacji opłaty za nakłady inwestycyjne (ONI), waloryzację należy przeprowadzać sukcesywnie po upływie danego okresu w odniesieniu do poniesionych na ten moment nakładów inwestycyjnych, a nie w oparciu o skumulowany wskaźnik waloryzacyjny na koniec Okresu Budowy.

W odniesieniu do części OzD dotyczącej Utrzymania koszyk waloryzacyjny będzie ustalany w oparciu o wskaźniki właściwe dla zakresu usług świadczonych w Okresie Utrzymania. Poniżej przedstawiono przykładowe postanowienia Umowy o PPP dotyczące wskaźników indeksacji, gdzie "r" oznacza rok, dla którego dokonywana jest indeksacja wynagrodzenia za Okres Utrzymania. Dane statystyczne, w oparciu o które dokonywana jest indeksacja dla roku "r", pochodzą z roku poprzedzającego rok "r", czyli "r-1". W przypadku, gdy Okres Utrzymania nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, wówczas waloryzacja Wynagrodzenia powinna być dokonana proporcjonalnie.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Wskaźnik indeksacji Opłaty za Utrzymanie oraz pomniejszeń z tytułu Punktów Karnych obliczany jest zgodnie z następującym wzorem:

$$J_r = \left(\prod_{r=1}^{r-1} \frac{CPI_r}{100} \right) \cdot [\bullet]\% + \frac{S_{r-1}}{S_0} \cdot [\bullet]\% + \left(\prod_{r=1}^{r-1} \frac{BM_r}{100} \right) \cdot [\bullet]\%$$

*Miejsca we wzorze pozostawione do wypełnienia powinny uwzględniać uzgodnione wagi poszczególnych wskaźników.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



J_r	wskaźnik indeksacji Opłaty za Utrzymanie oraz pomniejszeń z tytułu Punktów Karnych stosowany w roku "r".
CPI_r	wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku "r" (publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim do 31 stycznia roku "r+1").

S_r	przeciętna wysokość miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku "r" (publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS około 15 stycznia roku "r+1").
S_0	wynagrodzenie bazowe równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym rok złożenia Oferty.
BM_r	wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych w roku "r" uwzględniający wzrosty cen produkcji budowlano-montażowej w 4 kwartałach roku "r". Ze względu na fakt, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikuje jedynie wskaźniki kwartalne, BM_r należy obliczyć zgodnie ze wzorem: $BM_r = \left(\prod_{Q=1}^4 \frac{BM_Q}{100} \right) \cdot 100$ gdzie BM_Q oznacza publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 50 dni po każdym kwartale "Q" wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych w roku "r" dla kwartału "Q". W przypadku, gdy opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wyrażony jest w wartości procentowej, do obliczeń należy przyjąć wartość bezwzględną (np. dla wartości opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 2,5%, do obliczeń BM_Q należy przyjąć wartość 102,5).

UWAGA



W niektórych Przedsięwzięciach Podmioty Publiczne mogą dążyć do wyłączenia zysku Spółki Projektowej z waloryzacji części Wynagrodzenia odpowiadającej opłacie za Prace Projektowe i Roboty Budowlane.

W praktyce jest to trudne do zrealizowania, ponieważ Partnerzy Prywatni kalkulują stopę zwrotu z danego Przedsięwzięcia (w całym cyklu życia Projektu) w oparciu o własny know-how. Mogą oni zatem w różny sposób podchodzić do aspektów osiągania zysku z zarządzania Umową o PPP w Okresie Projektowania i Okresie Budowy, szczególnie w przypadku, gdy Podwykonawcami są podmioty z tej samej grupy kapitałowej lub długoletni dostawcy. Oznacza to, że faktyczny zysk Partnera Prywatnego może zostać ostatecznie skalkulowany w pozycjach kosztowych, które z punktu widzenia Podmiotu Publicznego nie będą oznaczone w Modelu Finansowym jako "zysk Partnera Prywatnego z Przedsięwzięcia". Zysk ten może być kalkulowany także globalnie przez Partnera Prywatnego w związku z zawarciem innych umów z podwykonawcami, które nie będą dotyczyły Przedsięwzięcia (np. umów w ramach grupy kapitałowej czy z wieloletnimi dostawcami dotyczących innych prac).

W Umowie o PPP należy ustalić częstotliwość waloryzacji. Zwykle odbywa się ona raz w roku, choć możliwa jest również waloryzacja przeprowadzana częściej.

PRZYKŁAD



Często wskaźnikami służącymi do waloryzacji Wynagrodzenia są wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, np. CPI lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Dziedzinowa Baza Wiedzy: <https://dbw.stat.gov.pl/>

UWAGA



W Umowie o PPP możliwe jest przewidzenie limitów waloryzacji. Nie jest to wymóg ustawy, jak w przypadku klasycznych zamówień publicznych, bowiem w zakresie Umów o PPP wyłączone jest stosowanie art. 439 PZP.

Należy jednak mieć na uwadze, że Podmiot Publiczny nie powinien ustalać limitów waloryzacji w odniesieniu do części Wynagrodzenia odpowiadającej opłacie za Utrzymanie. Jest ona bowiem płatna w wieloletnim okresie i ustalanie limitów jej waloryzacji jest nieadekwatne do potencjalnych wahań rynkowych, które trudne są do przewidzenia w całym Okresie Utrzymania.

Limit waloryzacji części Wynagrodzenia odpowiadającej opłacie za Projektowanie i Budowę jest spotykany w Umowach o PPP. Należy jednak pamiętać, że powinien on odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej.

Pomniejszenia Wynagrodzenia

Opłata za Dostępność w przyjętym w Umowie o PPP okresie rozliczeniowym może wymagać pomniejszenia ze względu na brak Dostępności Infrastruktury Publicznej oraz niedotrzymanie Standardów Utrzymania.

Jak wskazano w Części II Punkcie 3.2 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania Mechanizm Wynagradzania powinien uwzględniać pomniejszenie Wynagrodzenia w sytuacji niedotrzymania Standardów Utrzymania, zgodnie z określonymi w Umowie o PPP obiektywnymi i mierzalnymi kryteriami pomiaru jakości usług, tzw. KPI (np. w formie katalogu Punktów Karnych).

Punkt Karny powinien mieć w Umowie o PPP uzgodnioną wartość pieniężną, która w okresie obowiązywania Umowy jest indeksowana zgodnie z przyjętym wskaźnikiem indeksacji.

W celu wyliczenia pomniejszenia Wynagrodzenia, Punkty Karne w przyjętym okresie rozliczeniowym są sumowane, a następnie mnożone przez zindeksowaną wartość pieniężną i wynik takiej kalkulacji stanowi kwotę korekty Wynagrodzenia. W przypadku braku Dostępności Wynagrodzenie powinno zostać proporcjonalnie obniżone zgodnie z zasadami określonymi w Umowie (zob. Część II Punkt 3.2 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania).

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Urząd Zamówień Publicznych "Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa",
listopad 2022,

<https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-waloryzacyjne-dla-sektora-budownictwa>

4.2 Model Finansowy

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom II: Punkt 7.3.3 – Zgodność modelu finansowego z wymogami SWZ oraz Dokumentów
Koncesji

Tom IV: Część II Punkt 1.5 – Model Finansowy

Tom IV: Część II Punkt 4.3 – Refinansowanie

Załącznikiem do Umowy o PPP jest Model Finansowy składany przez Partnerów Prywatnych wraz z Ofertą, jeżeli był wymagany na etapie Postępowania. Model Finansowy przygotowywany jest na bazie szczegółowych wytycznych i założeń wskazanych w SWZ. W niektórych Projektach PPP Zamawiający nie wymagają składania modeli finansowych wraz z Ofertą, a jedynie rozbudowanego formularza ofertowego. W takich przypadkach wybrany Partner Prywatny dostarcza Model Finansowy w określonym terminie od zawarcia Umowy o PPP.

W kontekście Umowy o PPP Model Finansowy służy przede wszystkim rekalkulacji Opłaty za Dostępność w przypadku zaistnienia określonych w Umowie o PPP zdarzeń, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Projektu. Do tej grupy należą np. przypadki zewnętrzne takie jak przypadek kompensacyjny, polecenie zmiany, przypadek dostosowania, siła wyższa. Model Finansowy może być również aktualizowany w związku z realizacją zobowiązań stron, np. transakcji zabezpieczających stopy procentowe lub kursy walutowe w ramach Zamknięcia Finansowego oraz kolejnych w Okresie Obowiązywania Umowy lub pozyskanie preferencyjnego Finansowania lub dotacji. W takim przypadku Umowa o PPP przewidywać powinna procedurę aktualizacji Modelu Finansowego.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE



Jeżeli w Projekcie nie przewiduje się złożenia Modelu Finansowego wraz z Ofertą (np. Małe Projekty), a jedynie złożenie rozbudowanego formularza ofertowego Partnera Prywatnego, to wówczas aktualizacja OzD powinna następować w oparciu o waloryzację poszczególnych komponentów OzD zaprezentowanych w tym formularzu ofertowym. Do waloryzacji OzD należy wykorzystać wskazane w Umowie o PPP wskaźniki indeksacji (koszyk lub pojedynczy wskaźnik) oraz WIBOR (w przypadku zmiany stóp procentowych).

5. Przypadki zewnętrzne

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-IV



Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom IV: Część II Punkt 1.3.1 – Zmiany w Przedsięwzięciu

Tom IV: Część II Punkt 1.4.2 – Skutki finansowe ryzyk Podmiotu Publicznego

Tom IV: Część II Punkt 1.3.3 – Prawo interwencji Podmiotu Publicznego

5.1 Istota i cel przypadków zewnętrznych

Umowa o PPP powinna opisywać precyzyjnie skutki (finansowe i czasowe) określonych zdarzeń wpływających na zobowiązania stron Umowy, które nie wynikają z określonego działania lub zaniechania stron. Dla celów Wytycznych Tom III takie zdarzenia nazywane są łącznie mianem przypadków zewnętrznych.

Praktyka międzynarodowa wyodrębniła określone katalogi takich zdarzeń, które różnią się w zależności od jurysdykcji oraz konkretnego Projektu PPP. Przypadki zewnętrzne można przykładowo podzielić na następujące kategorie, które zwykle regulowane są w Umowach o PPP:

- 1) przypadki kompensacyjne (ang. *compensation events*);
- 2) przypadki dostosowania (ang. *adjustment events*);
- 3) siła wyższa;
- 4) zmiana prawa;
- 5) polecenie zmiany (ang. *change order*);
- 6) przypadek zwalniający (ang. *relief event*);
- 7) przypadki wydłużające termin (ang. *extention of time*).

Wskazany w Wytycznych Tom III katalog przypadków zewnętrznych, jak i poszczególnych sytuacji wystąpienia przypadków zewnętrznych, ma charakter wyłącznie przykładowy i należy go w sposób przemyślany włączyć do Umowy o PPP, tak aby odzwierciedlić specyfikę Projektu i zobowiązań stron.

Uregulowanie tych zagadnień jest ściśle związane z podziałem ryzyk, który jest jednym z istotnych elementów Umowy o PPP. Dzięki przewidzeniu w Umowie przypadków zewnętrznych możliwe jest wyłącznie odpowiedzialności jednej ze stron Umowy o PPP (zazwyczaj Partnera Prywatnego) z uwagi na zajęcie określonych jako takie przypadki w Umowie.

Wprowadzenie mechanizmu przypadków zewnętrznych odzwierciedla ideę PPP, zgodnie z którą Przedsięwzięcie ma być realizowane wspólnie przez Partnera Prywatnego i Podmiot Publiczny na zasadzie podziału zadań i ryzyk (art. 1 ust. 2 Ustawy o PPP).

Zgodnie z przepisem art. 433 pkt 1 i 3 Ustawy PZP Umowa o PPP nie może zawierać postanowień nakładających na Partnera Prywatnego odpowiedzialności za niezawinione naruszenie terminu ani za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Podmiot Publiczny. Przypadki zewnętrzne w swoich regulacjach wpisują się w zasady określone tym przepisem.

UWAGA



Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka często wprowadzana jest do Umów o PPP (np. za realizację Budowy w określonym terminie, za dotrzymanie Standardów Utrzymania). Granicą odpowiedzialności Partnera Prywatnego jest jednak wspomniana regulacja przepisu art. 433 pkt 1 i 3 Ustawy PZP, szczególnie gdy zajście określonych zdarzeń nie wynika z określonego działania lub zaniechania Partnera Prywatnego.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE



Podział i przypisanie określonych zdarzeń jako przypadków zewnętrznych w praktyce może się różnić. Przykładowo, w Umowach o PPP zawieranych na rynkach innych niż polski przewiduje się czasami zdarzenia określone mianem istotnych negatywnych działań Podmiotu Publicznego (ang. *Material Adverse Government Actions/MAGA*), które ujmowane są jako odrębna podstawa do rozliczenia z Partnerem Prywatnym. Z uwagi jednak na zbliżony charakter MAGA i przypadku kompensacyjnego czy przypadku wydłużającego termin, możliwe jest także uwzględnienie zdarzeń mających charakter istotnych negatywnych działań Podmiotu Publicznego w katalogu przypadków kompensacyjnych. Tak często dzieje się na rynku polskim.

W Umowach o PPP można wyodrębnić kategorię zdarzeń zewnętrznych, które skutkują zwolnieniem Partnera Prywatnego z określonych konsekwencji niewykonywania Umowy o PPP. Przykładem takich zdarzeń są chociażby przypadki usprawiedliwionego braku Dostępności lub usprawiedliwionego niedotrzymania Standardów Utrzymania, w której to sytuacji Partner Prywatny nie jest karany obniżeniem Wynagrodzenia.

Jednocześnie wystąpienie przypadku zwalniającego nie upoważnia Partnera Prywatnego do odszkodowania, ale powoduje przesunięcia terminów (jeżeli wpłynęło na terminy). Ponadto, brak świadczenia ze strony Partnera Prywatnego spowodowany wystąpieniem przypadku zwalniającego nie może stanowić podstawy do jednostronnego rozwiązania Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Umowa o PPP przewiduje zwolnienie Partnera Prywatnego ze świadczenia usług wnoszenia całości lub części opłaty eksploatacyjnej w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, polecenia zmiany, określonych warunków atmosferycznych.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE



Innym sposobem ujmowania przypadków zwalniających w Umowach o PPP, stosowanym powszechnie na innych rynkach jest definiowanie i katalogowanie przypadków zwalniających jako odrębnej kategorii przypadków zewnętrznych (jak na przykład przypadki kompensacyjne).

DOBRE PRAKTYKI



Zastosowanie w Umowie o PPP możliwie szerokiego katalogu przypadków zewnętrznych oraz postanowień dotyczących ich rozpatrywania usprawnia zarządzanie Umową o PPP, zmniejsza ryzyko sporów pomiędzy stronami oraz długotrwałych negocjacji dotyczących sposobu rozstrzygnięcia konkretnych sytuacji.

Umowa o PPP powinna zawierać możliwie precyzyjne i jednoznaczne postanowienia dotyczące wystąpienia przypadków zewnętrznych i zrekompensowania ich skutków (w tym sposób ustalenia skutków zdarzenia, sposób wykazania wpływu na zobowiązania wynikające z Umowy, sposób procedowania roszczenia oraz tryb dokonania zmiany zobowiązań stron). Z uwagi bowiem na to, że odpowiedzialność stron Umowy opiera się zasadniczo na ogólnych zasadach kontraktowych, zastosowanie mechanizmu, powodującego obciążenie jednej lub obu stron odpowiedzialnością za wystąpienie przypadku zewnętrznego, która to odpowiedzialność zazwyczaj wykracza poza normalną odpowiedzialność kontraktową (co do zasady w polskim prawie opartą na zasadzie winy), wymaga wyraźnego wskazania w treści Umowy.

UWAGA



W sytuacji, gdy przypadki zewnętrzne dotyczyć będą kwestii istotnych, jak na przykład wynagrodzenie czy terminy realizacji zadań, wówczas każdorazowo należy przeanalizować ewentualną konieczność zmiany Umowy o PPP.

5.2 Przypadek kompensacyjny i przypadek dostosowania

Cel i definicja przypadku kompensacyjnego

DEFINICJA



Przypadek Kompensacyjny – oznacza wystąpienie zdarzenia wyraźnie wskazanego jako Przypadek Kompensacyjny w Umowie, powodującego podwyższenie kosztów, zmianę terminów wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego lub inne skutki określone zgodnie z Umową.

UWAGA



Celem wprowadzenia przypadku kompensacyjnego do Umowy o PPP jest spowodowanie korekty odpowiednich zobowiązań każdej ze stron, w tym w zakresie terminów wykonania zobowiązań (np. zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego), wynikających z Umowy o PPP, w celu spowodowania, aby Partner Prywatny w zakresie Przedsięwzięcia znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki przypadek kompensacyjny nie nastąpił. Oznacza to, że poza kosztami, również wszelkie korzyści, jakie Partner Prywatny uzyskał wraz z wystąpieniem przypadku kompensacyjnego powinny być ujęte przy obliczaniu jego wartości (np. wypłata odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia).

Na skutek zajścia przypadku kompensacyjnego Partnerowi Prywatnemu może przysługiwać rekompensata oraz zmiana terminów realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

W Umowie o PPP należy szczegółowo opisać wszystkie przypadki kompensacyjne, tak aby strony były w pełni świadome, jakie zdarzenia mogą uprawniać Partnera Prywatnego do rekompensaty lub zmiany terminów.

PRZYKŁAD



Przykłady przypadków kompensacyjnych:

- prawa lub roszczenia osób trzecich do Nieruchomości, na której posadowiona ma być Infrastruktura Publiczna;
- natrafienie na znalezisko (np. archeologiczne);
- wystąpienie ryzyka geologicznego;
- pogorszenie stanu Nieruchomości od dnia złożenia Oferty;
- uniemożliwienie wykonywania Robót Budowlanych, ze względu na prace wykonywane przez podmioty trzecie (np. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej);
- ujawnienie infrastruktury technicznej skutkujące koniecznością jej przełożenia, przebudowy lub usunięcia;
- wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niesprzyjające temperatury, uniemożliwiające ukończenie Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego w terminie określonym w harmonogramie;
- niezyskanie w terminie określonym w harmonogramie Decyzji Administracyjnych z przyczyn nieleżących po stronie Partnera Prywatnego;
- zmiana prawa;
- nieprawdziwość oświadczeń i zapewnień Podmiotu Publicznego;
- niezasadność zastrzeżeń i uwag zgłaszanych przez Podmiot Publiczny lub Niezależnego Inżyniera, ustalona w wyniku procedury rozwiązywania sporów;

- niemożliwość korzystania z infrastruktury Podmiotu Publicznego niezbędnej do realizacji Projektu (np. drogi dostępne).

Cel i definicja przypadku dostosowania

DEFINICJA



Przypadek Dostosowania – oznacza wystąpienie zdarzenia wyraźnie wskazanego jako Przypadek Dostosowania w Umowie, powodującego obniżenie kosztów, zmianę terminów wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego lub inne skutki określone zgodnie z Umową.

Przypadek dostosowania ujmowany jest w praktyce międzynarodowej jako zdarzenie powodujące po stronie Partnera Prywatnego obniżenie określonych kosztów wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego. Zasadą jest, że wystąpienie przypadku dostosowania powoduje korektę odpowiednich zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego, wynikających z Umowy o PPP (tj. obniżkę), w celu spowodowania, aby Partner Prywatny znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki przypadek nie nastąpił.

PRZYKŁAD



Przykłady przypadków dostosowania:

- 1) zmiana prawa;
- 2) ustalenie, że założony obowiązek zapłaty podatku VAT nie powstanie (uzyskanie interpretacji);
- 3) faktyczne warunki są korzystniejsze niż w dokumentach Podmiotu Publicznego (np. geologiczne).

Progi kwotowe dla przypadków kompensacyjnych i przypadków dostosowania

Czasami w Umowach o PPP wskazuje się, że przypadek kompensacyjny i przypadek dostosowania zachodzą, jeżeli dojdzie do odpowiednio podwyższenia lub obniżenia kosztów netto (bez podatku VAT) wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego o więcej niż przewidziany próg kwotowy. Oznacza to, że strony nie mogą powoływać się na przypadek kompensacyjny lub przypadek dostosowania, a tym samym nie dojdzie do zmiany Wynagrodzenia czy zmiany terminów, jeżeli jego wartość nie przekroczy określonej w Umowie kwoty. Takie rozwiązanie powoduje, że Partnerzy Prywatni w ramach swoich Ofert oszacują ryzyko związane z niemożliwością zgłoszenia przypadku kompensacyjnego i przypadku dostosowania w sytuacji, w której nie zostanie osiągnięty próg kwotowy. Wpłynie to niewątpliwie na zwiększenie ceny wskazanej w Ofercie.

DOBRE PRAKTYKI



Przyjęcie rozwiązania, w którym brak jest minimalnego progu kwotowego przypadku kompensacyjnego i przypadku dostosowania może wpłynąć pozytywnie na wycenę ryzyk prowadzoną przez Partnera Prywatnego, a w konsekwencji na obniżenie ceny ofertowej. Podmiot Publiczny w rezultacie będzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty w dokładnej wysokości na dany moment wystąpienia przypadku kompensacyjnego. Ustanowienie progów spowoduje, że cała wartość progu zostanie wliczona do Oferty.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Umowa o PPP wprowadzała próg, po przekroczeniu którego Podmiot Publiczny zobowiązany był do rozliczenia przypadku kompensacyjnego w wysokości 500.000 PLN rocznie. Umowa przewidywała 10 letni Okres Obowiązywania Umowy. Partner Prywatny założył w cenie ofertowej dodatkowe 5 mln PLN. Łączna wartość przypadków kompensacyjnych w tym Projekcie przez cały Okres Obowiązywania Umowy nie przekroczyła 1,5 mln PLN.

DOBRE PRAKTYKI



Jeżeli Umowa o PPP nie przewiduje progu istotności, wówczas dobrą praktyką jest kumulowanie zgłoszeń przypadków kompensacyjnych, o ile to jest możliwe i rozpoczęcie procedury uzgadniania skutków przypadków kompensacyjnych, gdy ich łączna szacowana przez Partnera Prywatnego wartość przekroczy określony próg. Wówczas próg istotności nie będzie odnosić się do roszczenia Partnera Prywatnego, tylko do rozpoczęcia realizacji procedury przypadku kompensacyjnego.

Powyższe dotyczy również przypadku, gdy na moment zgłoszenia przypadku kompensacyjnego (np. zmiana prawa) trudno jest określić jego ostateczną wartość i inne skutki. Wówczas procedura uzgadniania skutków powinna rozpocząć się w momencie, gdy są one możliwe do precyzyjnego określenia.

Procedura ustalenia i rozliczenia przypadków kompensacyjnych i przypadków dostosowania

Umowa o PPP powinna dokładnie określać procedurę ustalania skutków wystąpienia przypadków kompensacyjnych oraz przypadków dostosowania.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Partner Prywatny zawiadomi Niezależnego Inżyniera oraz Podmiot Publiczny o wystąpieniu zdarzenia, które może stanowić Przypadek Kompensacyjny tak szybko, jak to praktycznie możliwe, ale nie później niż w terminie [...] Dni Roboczych po dowiedzeniu się o wystąpieniu zdarzenia. Uznaje się, że niezachowanie przez Partnera Prywatnego powyższego terminu zawiadomienia oznacza rezygnację z dochodzenia skutków prawnych danego Przypadku Kompensacyjnego.
- 2) Tak szybko, jak to możliwe, po otrzymaniu lub przesłaniu powiadomienia o wystąpieniu zdarzenia, które może stanowić Przypadek Kompensacyjny i następnie na koniec każdego kolejnego okresu [...] Dni Roboczych, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Kompensacyjnego, Partner Prywatny przekaże Niezależnemu Inżynierowi oraz Podmiotowi Publicznemu szczegółowe informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, dotyczące Przypadku Kompensacyjnego, w tym:
 - czynności podjęte przez Partnera Prywatnego w celu minimalizowania skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego;
 - oszacowanie skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego oraz konsekwencji dla wykonywania Robót Budowlanych lub wykonywania przez Partnera Prywatnego jego pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy;
 - kwoty wydatków, jakie Partner Prywatny poniósł lub których poniesienia się spodziewa, bądź też których spodziewa się nie ponosić, w wyniku wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego.
- 3) Wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego spowoduje korektę odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron, w tym w zakresie terminów wykonania zobowiązań Stron lub zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego, wynikających z niniejszej Umowy w celu spowodowania, aby Partner Prywatny w zakresie Przedsięwzięcia znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki Przypadek Kompensacyjny nie nastąpił (tj. w szczególności nie zmieni się EIRR).
- 4) Korekta nastąpi poprzez zrekompensowanie Partnerowi Prywatnemu szkody powstałej w wyniku wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego poprzez:
 - zapłatę rekompensaty, skutkującej przywróceniem sytuacji gospodarczej (finansowej) Partnera Prywatnego, w jakiej Partner Prywatny znajdowałby się, gdyby nie nastąpił taki Przypadek Kompensacyjny;
 - zmianę zobowiązań Stron, w tym terminów wynikających z Umowy.
- 5) Ocena stopnia pogorszenia sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego będzie dokonywana w szczególności w oparciu o wyniki Modelu Finansowego (łącznie z jego aktualizacjami), stanowiącego podstawę Oferty złożonej przez Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem między innymi:
 - spadku oraz wzrostu kosztów związanych ze skutkami wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, ponoszonych przez Partnera Prywatnego, związanych

- lub wynikających z Budowy oraz Utrzymania Infrastruktury Publicznej, a także w zakresie kosztów ogólnych, kosztów finansowych itp.;
- wszelkich koniecznych i uzasadnionych czynności podjętych w celu złagodzenia lub zniesienia skutków danego Przypadku Kompensacyjnego.
- 6) W zakresie, w jakim Partner Prywatny nie będzie w stanie wykonywać swoich zobowiązań wynikających z Umowy i pozostających w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, Partner Prywatny będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania (w tym z naliczania Punktów Karnych) do czasu ustania trwania tego Przypadku Kompensacyjnego lub jego skutków.
- 7) Partner Prywatny zobowiązany jest podjąć możliwe działania w celu łagodzenia lub równoważenia skutków Przypadku Kompensacyjnego.
- 8) Jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga wypłaty rekompensaty, wówczas Niezależny Inżynier w terminie 30 dni od otrzymania informacji od Partnera Prywatnego dotyczącej Przypadku Kompensacyjnego i następnie na koniec każdego kolejnego okresu [...] dni, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Kompensacyjnego, wyda rozstrzygnięcie Niezależnego Inżyniera, w którym ustali wysokość (kwotę) takiej rekompensaty po uzyskaniu stanowisk obu Stron oraz z uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczenia Przypadku Kompensacyjnego określonych w Umowie.
- 9) Rekompensata zostanie skalkulowana z uwzględnieniem następujących elementów:
- uzasadnionych i koniecznych kosztów wynikających z takiego Przypadku Kompensacyjnego dla Partnera Prywatnego;
 - kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowego Finansowania przez Partnera Prywatnego oraz zawarcia dodatkowych Transakcji Zabezpieczających dla dodatkowego Finansowania, o ile będzie to niezbędne;
 - zwiększenia lub zmniejszenia kosztów Utrzymania;
 - kosztów każdej czynności podjętej przez Partnera Prywatnego w ramach swoich kompetencji w celu łagodzenia lub równoważenia skutków Przypadku Kompensacyjnego;
 - zaniechania przez Partnera Prywatnego działań mających na celu łagodzenie lub równoważenie skutków Przypadku Kompensacyjnego (nie zostanie uwzględniona szkoda, która by nie powstała, gdyby Partner Prywatny podjął takie działania);
 - utraty przychodów Partnera Prywatnego powstałej w wyniku opóźnienia Daty Zakończenia Budowy;
 - w przypadku, gdyby kwota ta podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zostanie ona powiększona o należny podatek VAT.
- 10) W miarę możliwości Niezależny Inżynier dokona kalkulacji wartości Przypadku Kompensacyjnego z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym i powszechnie stosowanym w branży budownictwa katalogu nakładów roboczych i cen.

- 11) Jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga zmiany sposobu wykonywania obowiązków Stron wynikających z Umowy innych aniżeli zobowiązanie do zapłaty rekompensaty, w tym w szczególności, gdy wymaga dokonania korekty zmiany terminów wynikających z Umowy, Niezależny Inżynier ustali zmieniony sposób wykonywania danych obowiązków Stron.

Poniżej przedstawiono modelowe rozwiązania w zakresie procedury ustalania i rozliczania przypadków dostosowania.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) W przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić Przypadek Dostosowania, Partner Prywatny zawiadomi Niezależnego Inżyniera oraz Podmiot Publiczny o wystąpieniu takiego zdarzenia tak szybko, jak to praktycznie możliwe, ale nie później niż w terminie [...] Dni Roboczych po dowiedzeniu się o wystąpieniu takiego zdarzenia. Niezachowanie przez Partnera Prywatnego powyższego terminu skutkować będzie naliczeniem Punktów Karnych w wysokości określonej w Załączniku pt. Standardy Utrzymania.
- 2) Wystąpienie Przypadku Dostosowania spowoduje korektę odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron, w tym zobowiązań finansowych Partnera Prywatnego, wynikających z niniejszej Umowy w celu spowodowania, aby Partner Prywatny w zakresie Przedsięwzięcia znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki Przypadek Dostosowania nie nastąpił.
- 3) Ocena stopnia polepszenia sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego będzie dokonywana w oparciu w szczególności o wyniki Modelu Finansowego (łącznie z jego aktualizacjami) stanowiącego podstawę Oferty złożonej przez Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem spadku oraz wzrostu kosztów ponoszonych przez Partnera Prywatnego związanych lub wynikających z Budowy oraz Utrzymania, a także w zakresie kosztów ogólnych, kosztów finansowych itp.
- 4) Partner Prywatny przekaze Niezależnemu Inżynierowi szczegółowe informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, dotyczące Przypadku Dostosowania, w tym:
 - oszacowanie skutków wystąpienia Przypadku Dostosowania oraz konsekwencji dla wykonywania jakichkolwiek prac, w tym Robót Budowlanych lub wykonywania przez Partnera Prywatnego jego pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy;
 - kwoty wydatków, jakich Partner Prywatny nie poniósł lub które ulegną zmniejszeniu, bądź też których spodziewa się nie ponieść, w wyniku wystąpienia Przypadku Dostosowania.
- 5) Niezależny Inżynier, po uzyskaniu stanowisk Stron oraz w oparciu o uzyskane informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, określi sposób uwzględnienia skutków wystąpienia Przypadku Dostosowania, przy czym w pierwszej kolejności uwzględni skutki powodujące obniżkę, wskazując jej kwotę i terminy jej realizacji, a w następnej dokona określenia zmiany sposobu wykonywania innych obowiązków Stron.

- 6) W miarę możliwości Niezależny Inżynier dokona kalkulacji wartości Przypadku Dostosowania, z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym i powszechnie stosowanym w branży budownictwa katalogu nakładów roboczych i cen.
- 7) Jeśli wystąpienie Przypadku Dostosowania wymaga skorygowania sposobu wykonywania obowiązków Stron wynikających z Umowy innych aniżeli zobowiązanie do zapłaty, w tym w szczególności, gdy wymaga dokonania korekty terminów wynikających z Umowy, Niezależny Inżynier ustali zmieniony sposób wykonywania danych obowiązków Stron.

5.3 Siła wyższa

W ramach Umów o PPP siłę wyższą definiuje się najczęściej jako zdarzenia mające istotny wpływ na wykonywanie Umowy, na które żadna ze stron nie ma wpływu, ani też nie mogła się przeciwko nim zabezpieczyć przed zawarciem Umowy i których żadna ze stron nie mogła uniknąć czy im zapobiec oraz które nie zostały wywołane przez żadną ze stron.

DEFINICJA



Siła Wyższa - oznacza następujące zdarzenia zewnętrzne, mające istotny wpływ na wykonywanie Umowy (inne niż Przypadek Kompensacyjny, Zmiana Prawa, Przypadek Zwalniający lub inne zdarzenie bądź okoliczności, których ryzyko zostało przyjęte przez Strony Umowy w sposób inny niż w ramach postanowień dotyczących Siły Wyższej), (i) na które żadna ze Stron nie ma wpływu, (ii) przeciw któremu żadna ze Stron nie mogła się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy o PPP, (iii) którego żadna ze Stron nie mogła uniknąć lub mu zapobiec oraz (iv) które nie zostało wywołane przez żadną ze Stron, w szczególności:

- 1) wojnę lub inne działania wojskowe, inwazję, bunt, akty terroru, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową i każde inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu;
- 2) eksplozję amunicji, eksplozję jądrową, wypadek skutkujący skażeniem radioaktywnym lub chemicznym;
- 3) wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, między innymi takiej jak pożar, powódź, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, burza, huragan lub innego nadzwyczajnego zjawiska atmosferycznego;
- 4) strajk, wywierający istotny wpływ na działalność Partnera Prywatnego (z wyjątkiem strajku pracowników Partnera Prywatnego lub Podwykonawców).

W definicji siły wyższej powinno wyłączać się z niej znane stronom skutki zaistniałych już zdarzeń, które potencjalnie mogły wpływać na Projekt, jak działania wojenne w kraju sąsiadującym.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Strony przyjmują, iż znane im w dacie złożenia Oferty skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie nie stanowią Siły Wyższej.

Definicja siły wyższej w Umowie PPP powiązana bywa z tzw. przypadkami nieubezpieczalnymi – tj. zdarzeniami, które nie są obejmowane ochroną ubezpieczeniową na rynku ubezpieczeń (albo składki ubezpieczeniowe w tym zakresie są zaporowe). Wynika to z faktu, iż właściwie ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej dotyczy tylko takich właśnie sytuacji nieubezpieczalnych. W przypadku wystąpienia pozostałych, koszty ewentualnej materializacji danego ryzyka zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeniowy.

UWAGA



Uregulowanie przypadków siły wyższej w Umowie PPP jest istotne, bowiem umowa ta ma charakter wieloletni. Stąd też ryzyko zajścia zdarzeń o takiej charakterystyce w długim okresie obowiązywania Umowy rośnie. W polskiej praktyce kontraktowej najczęściej wskazuje się cechy wyróżniające siłę wyższą i otwarty katalog przykładowych zdarzeń stanowiących siłę wyższą. Jest to modelowe i rekomendowane rozwiązanie, gdyż trudno jest jednoznacznie określić zamkniętą listę przypadków siły wyższej.

PRZYKŁAD



Przykładem przypadku siły wyższej był wybuch pandemii Covid-19 i jej negatywne konsekwencje wpływające na wykonanie zobowiązań stron umów, w tym Umów o PPP (np. załamanie łańcuchów dostaw, opóźnienia w dostawach, wzrost cen). Było to niewątpliwie zdarzenie, na które żadna ze stron nie miała wpływu, przeciw któremu żadna ze stron nie mogła się zabezpieczyć przed zawarciem umowy i którego żadna ze stron nie mogła uniknąć lub mu zapobiec oraz które nie zostało wywołane przez żadną ze stron. Zdarzenie to umożliwiała powołanie się przez strony na siłę wyższą i dostosowanie swoich zobowiązań do zaistniałej sytuacji (np. zmiana terminów realizacji Robót).

Niewykonanie Umowy z powodu siły wyższej powoduje najczęściej brak odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu – brak jest obowiązku zapłaty odszkodowania, również w formie kary umownej. W Umowach o PPP regułą jest, że ryzyko związane ze skutkami wystąpienia siły wyższej dzielone jest pomiędzy obie strony. Konkretnie rozwiązania związane z usunięciem skutków siły wyższej zależne są od specyfiki Projektu PPP i analizy konkretnego przypadku, jednakże zazwyczaj przewiduje się możliwość zmiany zobowiązań stron bądź wypowiedzenia Umowy.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



1) W przypadku:

- niezgodnienia przez Strony działań koniecznych do podjęcia w celu ograniczenia skutków Siły Wyższej oraz warunków kontynuowania wykonywania Umowy w terminie [...] dni liczonych od daty zawiadomienia o wystąpieniu Siły Wyższej, jeżeli przypadek Siły Wyższej nadal trwa lub

- gdy Partner Prywatny nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z uwagi na Siłę Wyższą przez okres dłuższy niż [...] dni,

wówczas, każda ze Stron uprawniona będzie do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- 2) Niewykonanie niniejszej Umowy przez Strony spowodowane Siłą Wyższą będzie usprawiedliwione i takie niewykonanie nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w zakresie, w jakim Partner Prywatny nie będzie w stanie wykonywać któregoś ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu wystąpienia lub skutków Siły Wyższej, Partner Prywatny będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania do czasu ustania trwania Siły Wyższej i jej skutków, a jeśli Siła Wyższa lub jej skutki będą uprawniać Podmiot Publiczny do naliczenia Punktów Karnych ani Punkty Karne, ani pomniejszenia Wynagrodzenia nie zostaną naliczone z powodu takiego przypadku Siły Wyższej. W celu uniknięcia wątpliwości Podmiot Publiczny nie będzie zwolniony z wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych względem Partnera Prywatnego na podstawie niniejszego Punktu.
- 3) Strony zobowiązane są i uprawnione do podjęcia niezbędnych i możliwych działań w celu miarkowania zakresu lub skutków zdarzenia, które może stanowić przypadek Siły Wyższej.

5.4 Zmiana prawa

Praktyką na rozwiniętych rynkach PPP jest wskazywanie w Umowach o PPP postanowień przypisujących stronom ryzyko konkretnych zmian prawa (ang. *change in law*), które mogą mieć miejsce po określonej dacie (np. po dacie złożenia Oferty) i które spełniają określone w Umowie kryteria.

DEFINICJA



Zmiana Prawa - oznacza wejście w życie, zmianę lub uchylenie po dacie złożenia Oferty Przepisów Prawa.

DEFINICJA



Istotna Zmiana Prawa oznacza:

- 1) Zmianę Prawa, niemającą charakteru powszechnego, a dotyczącą w sposób selektywny i niekorzystny:
 - Przedsięwzięcia; lub
 - przedsięwzięć podobnych do Przedsięwzięcia; lub
 - Partnera Prywatnego, a nie innych podmiotów;

- 2) Zmianę Prawa wpływającą na inne koszty Przedsięwzięcia niż ogólne koszty operacyjne związane z prowadzeniem takiego rodzaju działalności jak Przedsięwzięcie, której nie dało się przewidzieć w dacie złożenia Oferty;
- 3) Zmianę Prawa, polegającą na zmianie wysokości stawki podatku VAT (w tym, wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT), znajdującą zastosowanie do wyliczenia Opłaty za Dostępność bądź jakiegokolwiek innej płatności należnej Partnerowi Prywatnemu od Podmiotu Publicznego zgodnie z Umową;
- 4) Zmianę Prawa polegającą na zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- 5) Zmianę Prawa polegającą na zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Podejście do ryzyka związanego ze zmianami prawa powinno być uzależnione od rodzaju możliwych zmian i ich potencjalnego wpływu na dany Projekt PPP.

Zazwyczaj skutki zajścia określonych przypadków związanych ze zmianą prawa określa się w Umowie o PPP analogicznie do skutków innych przypadków zewnętrznych mogących powodować zmiany w Projekcie PPP, np. stanowić podstawę do podniesienia przez Partnera Prywatnego roszczenia w ramach uprawnień związanych z wystąpieniem przypadku kompensacyjnego.

Modelowym rozwiązaniem w Umowach o PPP jest ponoszenie przez Podmiot Publiczny ryzyka związanego nie z każdą zmianą prawa, a jedynie z istotną zmianą prawa, tj. taką, która ma charakter selektywny i dyskryminujący oraz taką, która wpływa na inne koszty niż koszty eksploatacyjne, które Partner Prywatny powinien ponosić w ramach normalnego ryzyka gospodarczego jakie ponoszą przedsiębiorcy. Istotna zmiana prawa jest typowym ryzykiem przenoszonym na Podmiot Publiczny w Umowach o PPP.

UWAGA



W niektórych sytuacjach wpływ zmiany prawa na koszty podatkowe Projektu może zostać złagodzony poprzez uzyskanie interpretacji ogólnej lub indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić także dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. W sprawach dotyczących przyjęcia właściwych stawek podatku VAT możliwe jest skorzystanie z instytucji wiążącej informacji stawkowej. Należy jednocześnie wskazać, że praktyka interpretacyjna może także przyczyniać się do materializacji ryzyka zmiany prawa, o ile strony Umowy o PPP przyjęły inną interpretację w momencie zawarcia Umowy o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Istotna Zmiana Prawa stanowi Przypadek Kompensacyjny albo Przypadek Dostosowania i do ustalenia skutków Zmiany Prawa stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Przypadku Kompensacyjnego lub Przypadku Dostosowania.

5.5 Polecenie zmiany

Umowa o PPP może przewidywać uregulowania dotyczące polecenia zmiany względem sposobu wykonywania Umowy o PPP, w tym sposobu wykonywania Prac Projektowych, Robót Budowlanych, Utrzymania lub Zarządzania. Polecenie zmiany następuje przez jego wydanie przez Podmiot Publiczny z własnej inicjatywy lub na wniosek Partnera Prywatnego.

DEFINICJA



Polecenie Zmiany - oznacza polecenie dokonania zmiany względem sposobu wykonywania Umowy o PPP, w tym sposobu wykonywania Prac Projektowych, Robót Budowlanych, Utrzymania lub Zarządzania, skierowane przez Podmiot Publiczny do Partnera Prywatnego.

Powszechną praktyką jest, że Partner Prywatny ma prawo do odszkodowania za skutki polecenia zmiany. W przypadku, gdy uwzględnienie polecenia zmiany skutkować będzie zwiększeniem lub zmniejszeniem kosztów Partnera Prywatnego, wówczas do rozliczenia takiego polecenia zmiany zwykle stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przypadku kompensacyjnego lub przypadku dostosowania, tak aby Partner Prywatny pozostał w takiej samej sytuacji ekonomicznej, jak gdyby polecenie zmiany nie miało miejsca.

Umowa powinna przewidywać szczegółową procedurę ustalania wartości polecenia zmiany oraz tryb dokonania zmiany zobowiązań stron. Polecenie zmiany jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy możliwość jego wydania w konkretnej sytuacji została przewidziana wprost w Umowie o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) W dowolnym czasie po Dacie Wejścia w Życie, Podmiot Publiczny z własnej inicjatywy lub na wniosek Partnera Prywatnego może wydać Partnerowi Prywatnemu polecenie dokonania zmiany względem zakresu lub sposobu wykonywania zobowiązań Partnera Prywatnego, w tym sposobu wykonywania Prac Projektowych, Robót Budowlanych, Utrzymania lub Zarządzania.
- 2) Polecenie Zmiany powinno co najmniej zawierać:
 - szczegółowy zakres Polecenia Zmiany;
 - opis skutków Polecenia Zmiany w odniesieniu do zobowiązań Partnera Prywatnego (w tym zmiany Harmonogramu, jakie prawdopodobnie Polecenie Zmiany spowoduje);
 - wysokości łącznych kosztów, które Polecenie Zmiany może spowodować;

- wraz z dokumentacją ich dotyczącą.
- 3) Polecenie Zmiany zostanie zgłoszone Niezależnemu Inżynierowi w celu ustalenia wartości Polecenia Zmiany zgodnie z odpowiednio stosowanymi postanowieniami dotyczącymi Przypadku Kompensacyjnego lub Przypadku Dostosowania.
 - 4) Na żądanie Partnera Prywatnego Strony podejmą dyskusję na temat zamiennych rozwiązań wykonania prac, które spełniałyby cele Podmiotu Publicznego wskazane w Poleceniu Zmiany.
 - 5) O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Partner Prywatny nie będzie zobowiązany do przystąpienia do realizacji Polecenia Zmiany do czasu uzgodnienia przez Strony wysokości, warunków i terminów rozliczenia Polecenia Zmiany przez Strony lub koniecznych zmian w Harmonogramie, przedłużenia Okresu Projektowania i Budowy (o ile to będzie konieczne) i Okresu Utrzymania, zmian w Standardach Utrzymania (o ile to będzie konieczne) oraz innych warunków, na jakich Polecenie Zmiany będzie wykonywane. Uzgodnienie będzie dokonane w formie pisemnej.
 - 6) Partnerowi Prywatnemu nie będzie wolno zawiesić, wstrzymać, przerwać ani w inny sposób opóźnić Robót ani Utrzymania z tego względu, że oczekuje na uzgodnienie warunków Polecenia Zmiany, chyba że Podmiot Publiczny wystąpi z takim żądaniem na piśmie. Powyższe stanowić będzie Przypadek Kompensacyjny.
 - 7) Strony ustalą, z pomocą Niezależnego Inżyniera:
 - w przypadku zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego - wartość prac objętych Poleceniem Zmiany z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kosztów ujętych w Ofercie Partnera Prywatnego i w Modelu Finansowym, a następnie; z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym i powszechnie stosowanym w branży budownictwa katalogu nakładów roboczych i cen;
 - w przypadku innych obowiązków Partnera Prywatnego – koszt wykonania przez Partnera Prywatnego określonych czynności związanych z Poleceniem Zmiany, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kosztów ujętych w ofercie Partnera Prywatnego i w Modelu Finansowym, a następnie z uwzględnieniem przeciętnych cen rynkowych zbliżonych czynności, określonych w oparciu o badanie rynku.

6. Procedura rozwiązywania sporów

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-IV



Tom IV: Część II Punkt 1.3.2 – Rozwiązywanie sporów

6.1 Ogólne informacje

Każda Umowa o PPP powinna zawierać postanowienia regulujące procedurę rozwiązywania sporów. Obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa tylko ze względów praktycznych. Zwykle bowiem, procedury rozwiązywania sporów konstruowane są jako wielostopniowe klauzule, zgodnie z którymi ewentualne wszczęcie postępowania sądowego lub arbitrażowego musi być poprzedzone próbą polubownego zakończenia sporu.

Stwarza to okazję dla stron do szybszego i tańszego rozwiązania konfliktu, a w efekcie ma pozytywny wpływ na możliwość kontynuowania Umowy o PPP. W Umowach o PPP oraz w obrocie gospodarczym klauzule arbitrażowe są równouprawnioną alternatywą dla ścieżki sądowej.

W projektach PPP najpowszechniej obecnie stosowaną procedurą rozwiązywania sporów jest trzystopniowa procedura obejmująca konsultacje, etap ekspercki i postępowanie formalne.

Schemat 1. Trzystopniowa Procedura Rozwiązywania Sporów



6.2 Konsultacje

Etap konsultacyjny powinien być pierwszym etapem procedury rozwiązywania sporów w Umowach o PPP. W jego ramach przedstawiciele stron powinni przez określony czas prowadzić rozmowy mające na celu wypracowanie rozwiązania kompromisowego, akceptowalnego dla stron. Istotne jest, aby czas przeznaczony na konsultacje był stosunkowo krótki i wynosił przykładowo dwa tygodnie. Jeżeli w tak określonym, krótkim terminie przedstawicielom stron nie uda się wypracować odpowiedniego rozwiązania, etap konsultacyjny powinien zostać zakończony i strony powinny przejść do kolejnego etapu procedury rozwiązywania sporów.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów w związku z niniejszą Umową, w szczególności, gdy:

- spór związany jest z treścią postanowień Umowy lub sposobem jej wykonywania;
- spór dotyczy obowiązywania, ważności lub skuteczności Umowy.

Strony będą czynić starania, aby rozwiązać spór w drodze konsultacji.

O zamiarze podjęcia konsultacji Strona zawiadamia drugą Stronę poprzez złożenie pisemnego wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

Rozpoczęcie konsultacji następuje w terminie [...] Dni Roboczych od chwili doręczenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji drugiej Stronie.

W razie, gdy Strony nie osiągną porozumienia w terminie [...] dni od rozpoczęcia konsultacji ani nie zgodzą się wspólnie na przedłużenie tego terminu, każda ze Stron może zażądać przekazania sporu do rozstrzygnięcia przez Zespół Niezależnych Ekspertów.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE



Alternatywnie do konsultacji między stronami, Umowa o PPP przewidywać może, że pierwszym etapem procedury rozwiązywania sporów będą mediacje prowadzone przez mediatora (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego). W Umowie o PPP należy zawrzeć wtedy klauzulę mediacyjną, a także postanowienia regulujące sposób wyboru takiego mediatora. W szczególności wskazać można podmiot, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie mediacji (np. Sąd Polubowny przy Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Centrum Mediacji Lewiatan lub inny określony przez strony podmiot). Wzory klauzul mediacyjnych znajdują się na stronach internetowych odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie mediacji.

6.3 Etap ekspercki

W ramach etapu eksperckiego strony przekazują rozstrzygnięcie zaistniałego między nimi sporu do profesjonalnego, niezależnego podmiotu.

W ramach tego etapu, ekspert lub zespół ekspertów analizuje przedmiot sporu i wydaje arbitralną decyzję co do jego rozstrzygnięcia. Jeżeli decyzja eksperta lub zespołu ekspertów jest niesatysfakcjonująca dla którejkolwiek ze stron, może ona żądać wszczęcia formalnego postępowania w ramach etapu trzeciego.

Stosując takie rozwiązanie, należy pamiętać, aby Umowa o PPP zawierała dokładne postanowienia związane z wyborem ekspertów. W zakresie grona osób, z których eksperci będą wylaniani, można przykładowo ograniczyć ich wybór do osób wpisanych na listę arbitrów w danym sądzie polubownym czy na listę biegłych sądowych z danego zakresu. Jeśli chodzi o samą procedurę wyboru ekspertów, standardowo przyjętym rozwiązaniem jest wskazanie jednego eksperta przez Podmiot Publiczny, jednego eksperta przez Partnera Prywatnego oraz jednego eksperta w ramach jednomyślności stron. Procedura ta może podlegać różnym modyfikacjom, należy jednak pamiętać, żeby zastrzec w Umowie o PPP, iż jeśli sam wybór ekspertów okaże się niemożliwy, strony przejdą do kolejnego etapu procedury rozwiązywania sporów.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE



W zależności od uwarunkowań danego Projektu, etap ekspercki może przybrać inną formę lub zostać całkowicie zastąpiony inną metodą rozwiązywania sporu. Alternatywą dla rozstrzygnięcia eksperta lub zespołu ekspertów może być przykładowo poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Niezależnego Inżyniera lub skierowanie sporu do koncyliacji prowadzonej przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4 Postępowanie sądowe

Umowa o PPP przewiduje, że po wyczerpaniu polubownej ścieżki rozwiązywania sporów, jeśli strony nadal nie osiągnęły porozumienia, spór powinien zostać oddany pod rozstrzygnięcie sądu – zazwyczaj będzie to sąd powszechny, choć nie ma przeciwwskazań, aby postępowanie w ramach tego etapu toczyło się przed sądem arbitrażowym. W przypadku oddania sporów pod jurysdykcję sądu arbitrażowego należy pamiętać o uwzględnieniu w Umowie odpowiedniej klauzuli arbitrażowej (zapisu na sąd polubowny), właściwego dla danego sądu. Poniżej przedstawiono przykładowo modelową klauzulę arbitrażową Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
<https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/>

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
<https://sakiq.pl/arbitraz>

Centrum Mediacji Lewiatan,
<https://lewiatan.org/centrum-mediacji-lewiatan/>

7. Zmiany Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP Tom I-IV



Tom IV: Część II Punkt 1.3.3 – Prawo interwencji Podmiotu Publicznego

7.1 Umowne przesłanki zmiany. Procedura zmiany Umowy

Umowa o PPP, w związku z art. 455 Ustawy PZP, powinna przewidywać możliwość wprowadzenia przez strony zmiany Umowy o PPP w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości Wynagrodzenia, jeśli łącznie spełniają one następujące warunki:

- określają rodzaj i zakres zmian;
- określają warunki wprowadzenia zmian;
- nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy.

UWAGA



Strony są upoważnione do daleko posuniętej ingerencji w treść Umowy o PPP, w tym do dokonania zmian istotnych, o ile w ogłoszeniu o zamówieniu lub w innych dokumentach zamówienia przewidziany został odpowiedni mechanizm wprowadzania takich zmian. Mechanizm ten powinien przybrać postać skonkretyzowanych postanowień Umowy o PPP, z góry ustalających warunki, których spełnienie umożliwi zmianę postanowień umownych (tj. przesłanki zmiany Umowy), a także rodzaj (tj. istotna lub nieistotna) i zakres takich zmian (tj. skutki ich wprowadzenia, np. zmiana Wynagrodzenia, zmiana terminów wynikających z Umowy). Granicą takiej ingerencji w pierwotną treść Umowy o PPP jest zakaz zmiany jej ogólnego charakteru (art. 455 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy PZP).

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres zmian może zostać określony w jednym postanowieniu umownym i nie musi być każdorazowo wskazywany przy konkretnej przesłance zmiany Umowy.

Umowy o PPP przewidują z reguły dość szeroki katalog możliwych zmian do Umowy o PPP. Jest to konieczne z uwagi na zapewnienie odpowiedniej elastyczności w Projekcie PPP i umożliwienie dostosowywania długoterminowej Umowy o PPP do zmieniających się okoliczności.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Partner Prywatny nie dotrzymywał KPI i szybko osiągnął poziom kar uprawniających Podmiot Publiczny do wypowiedzenia umowy. Ustalono, że czasy reakcji i napraw zostały określone na poziomie niemożliwym do zrealizowania przy dołożeniu należytej staranności. Między innymi z uwagi na obiektywne, zewnętrzne i niezależne od Partnera Prywatnego czynniki, czasy reakcji w utrzymaniu były zbyt krótkie. Umowa o PPP

przewidywała możliwość zmiany umowy w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Partnera Prywatnego dotrzymanie KPI stało się obiektywnie niemożliwe. Strony uzgodniły, że czasy reakcji powinny zostać dostosowane w taki sposób, aby z jednej strony zabezpieczyć interes Podmiotu Publicznego, a z drugiej strony dostosować do faktycznych możliwości po stronie Partnera Prywatnego.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Bez uszczerbku dla obowiązku lub uprawnienia dokonywania zmian Umowy w sposób zgodny z przepisami Ustawy PZP, Strony niniejszym uzgadniają, że wszelkie zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Partnera Prywatnego, są dopuszczalne także na podstawie niniejszego Punktu w zakresie zmiany Wynagrodzenia, Harmonogramu, Prac Projektowych, Robót, Utrzymania, Zarządzania oraz zasad Dostępności, w następujących sytuacjach:
 - jest to konieczne z uwagi na ostateczne Decyzje Administracyjne, uzgodnienia i opinie wydane w związku z realizacją przedmiotu Umowy; lub
 - wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek wystąpienia Siły Wyższej; lub
 - będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; lub
 - w przypadku wydania Polecenia Zmiany, wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania lub Siły Wyższej, których rozliczenie pomiędzy Stronami zgodnie z warunkami określonymi niniejszą Umową powoduje konieczność Zmiany Umowy; lub
 - Zmiana Umowy zostanie uzgodniona w formie ugody lub ustalona w ramach rozstrzygnięcia lub wyroku wydanych zgodnie z Procedurą Rozwiązywania Sporów; lub
 - w przypadku zmiany Finansowania; lub
 - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na uzasadnione wymagania Instytucji Finansującej.
- 2) Strony uzgadniają, iż dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie Partnera Prywatnego na innego partnera prywatnego, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, pod warunkiem, że nowy partner prywatny będzie spełniał warunki określone w SWZ. Zmiana Partnera Prywatnego będzie w szczególności możliwa w wykonaniu Umowy Bezpośredniej.
- 3) W przypadku, gdy zmiana Umowy skutkować będzie zmianą Wynagrodzenia, Strony zastosują reguły obliczania Wynagrodzenia opisane w Załączniku pt. Mechanizm Wynagradzania.
- 4) W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany Umowy, o których mowa wyżej, Strona, której dotyczą te okoliczności przedstawi na piśmie drugiej Stronie propozycję zmiany Umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Druga Strona jest obowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu [...] Dni

Roboczych ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie. W przypadku niejasności lub potrzeby dokonania uzgodnień Strony spotkają się w celu ustalenia wspólnej treści zmian Umowy.

Umowa o PPP zawierać będzie zwykle także postanowienia wskazujące jakie czynności stron nie będą wymagały zawarcia aneksu do Umowy, pomimo że ich wykonanie powoduje zbliżone skutki (np. wzrost Wynagrodzenia). W tym zakresie należy zwrócić uwagę na precyzję takich postanowień.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy:

- aktualizacja Modelu Finansowego i wynikająca z niej rekalkulacja Wynagrodzenia dokonana w sposób przewidziany niniejszą Umową;
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy (np. zmiana adresów);
- zmiana osób wskazanych do kontaktu;
- zmiana siedziby i adresu i innych danych teleadresowych Stron.

7.2 Ustawowe przesłanki zmiany Umowy o PPP

Należy zaznaczyć, że tylko nieistotne zmiany Umowy o PPP oraz te przewidziane w Umowie o PPP w sposób opisany powyżej mogą być swobodnie wprowadzane przez strony.

Zgodnie bowiem z art. 454 Ustawy PZP istotna zmiana Umowy o PPP wymaga przeprowadzenia nowego Postępowania. Zmiana jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter Umowy o PPP zmienia się w sposób istotny w stosunku do jej pierwotnej wersji, a w szczególności, jeżeli zmiana:

- 1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w Postępowaniu, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
- 2) narusza równowagę ekonomiczną stron Umowy o PPP na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej wersji;
- 3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy o PPP;
- 4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PPP.

Na podstawie przepisu z art. 455 Ustawy PZP przeprowadzenie nowego Postępowania nie będzie konieczne, a więc zmiana Umowy będzie dopuszczalna (poza przesłankami wskazanymi w Umowie o PPP) w następujących sytuacjach:

- 1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
 - jeżeli taka możliwość została przewidziana w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych; lub

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy PZP; lub
- w wyniku przejęcia przez Podmiot Publiczny zobowiązań wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy PZP;

UWAGA



Z uwagi na fakt, iż art. 465 ust. 1 Ustawy PZP jest wyłączony w przypadku Projektów PPP również przesłanka określona powyżej nie będzie mieć do nich zastosowania. Oznacza to, iż na tej podstawie prawnej Podmiot Publiczny nie będzie mógł przejąć np. umowy o Roboty Budowlane zawartej przez Partnera Prywatnego z Generalnym Wykonawcą. Będzie to jednak możliwe na podstawie postanowień Umowy o PPP, jeżeli taka przesłanka zostanie przewidziana w katalogu umownych przesłanek zmian Umowy.

- 2) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub Robót Budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
 - wzrost ceny (Wynagrodzenia) spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
- 3) jeżeli konieczność zmiany Umowy o PPP spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy o PPP, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy o PPP;
- 4) jeżeli zmiana Umowy o PPP dotyczy zamówień, których łączna wartość jest mniejsza niż Progi Unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy o PPP, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na Roboty Budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy o PPP.

UWAGA



Należy podkreślić, że w przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy o PPP w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy PZP, a po dokonaniu zmiany Umowy o PPP zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

8. Ubezpieczenia

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-IV



Tom IV: Część II Punkt 1.3.4 - Ubezpieczenia

8.1 Ubezpieczenia

Umowa o PPP powinna przewidywać zobowiązanie Partnera Prywatnego w zakresie zawarcia określonych umów ubezpieczenia w odniesieniu do Robót oraz Infrastruktury Publicznej. Partner Prywatny powinien być zobowiązany nieprzerwanie utrzymywać wymagane umowy ubezpieczenia, na warunkach zgodnych z Umową o PPP, przez cały Okres Obowiązywania Umowy.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Partner Prywatny zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności dotyczącej Infrastruktury Publicznej z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami, którzy gwarantują wykonanie umowy ubezpieczenia w sposób należyte zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie oraz z sumą ubezpieczenia/sumą gwarancyjną w wysokości określonej w Załączniku pt. "Ubezpieczenie".
- 2) Partner Prywatny zobowiązuje się nieprzerwanie utrzymywać wymagane umowy ubezpieczenia, na warunkach zgodnych z Umową o PPP.
- 3) Partner Prywatny w terminie [...] Dni Roboczych przed datą wygaśnięcia każdej kolejnej polisy w zakresie umów ubezpieczenia, jest zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu nowej kopii polisy, obejmującej okres bezpośrednio następujący po okresie zakończenia ważności poprzedniej polisy wraz z dowodem opłaty należnych składek lub przedłużenia istniejącej polisy wraz z dowodem opłaty należnych składek.
- 4) Na każde wezwanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej i dowód opłacenia składki.
- 5) W przypadku niedopełnienia przez Partnera Prywatnego obowiązku zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku pt. "Ubezpieczenie" lub umowa albo umowy nie zostały przedłużone lub Partner Prywatny nie opłacił składki ubezpieczeniowej, Podmiot Publiczny zawrze umowę lub umowy ubezpieczenia, w zakresie, o którym mowa w Załączniku pt. "Ubezpieczenie", na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego.

UWAGA



Nie wszystkie z oferowanych przez zakłady ubezpieczeń typów polis są niezbędne z punktu widzenia Podmiotu Publicznego i konkretnego Projektu PPP.

W niektórych przypadkach może okazać się, że lepszym rozwiązaniem jest zobowiązanie Partnera Prywatnego do ubezpieczenia danego ryzyka. Innym razem korzystniejsze może okazać się zawarcie polisy bezpośrednio przez Podmiot Publiczny.

Należy pamiętać, że oferta zakładów ubezpieczeniowych jest ograniczona poprzez różnego rodzaju limity odpowiedzialności oraz przypadki wyłączające. Może okazać się, że oczekiwany przez Podmiot Publiczny zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo kosztowny lub wręcz niedostępny na rynku. Podmiot Publiczny nie może wymagać od Partnera Prywatnego zawarcia polisy na warunkach, które nie są oferowane na rynku ubezpieczeniowym.

Dlatego Podmioty Publiczne powinny w odniesieniu do konkretnego Projektu PPP pozyskać adekwatne informacje i rekomendacje od brokera ubezpieczeniowego. Aby broker ubezpieczeniowy w odpowiedni sposób sformułował zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej, konieczna jest ścisła współpraca z Podmiotem Publicznym i jego doradcą technicznym.

Na przykład często Podmioty Publiczne zawierają ubezpieczenie majątkowe dotyczące Infrastruktury Publicznej i w tym zakresie Umowy o PPP nie przewidują już takiego obowiązku po stronie Partnera Prywatnego. Rozwiązanie takie jest efektywniejsze, ponieważ Podmioty Publiczne uzyskują korzystniejsze warunki ubezpieczenia swoich aktywów.

Umowa Bezpośrednia może przewidywać wyrażenie zgody Podmiotu Publicznego na cesję wymagalnych wierzytelności z umowy ubezpieczenia na rzecz Instytucji Finansujących z umów ubezpieczenia majątkowego Przedsięwzięcia.

Do najbardziej podstawowych typów ubezpieczeń, jakie posiadać powinien Partner Prywatny, należy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w całym Okresie Obowiązkiwania Umowy oraz ubezpieczenie od ryzyk budowlanych i budowlano-montażowych (CAR) w Okresie Budowy. W zależności od specyfiki danego Przedsięwzięcia, uzasadnione może być zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia właściwych dla określonego rodzaju działalności (np. ubezpieczenie mienia w transporcie, tzw. Marine/CARGO, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej).

Umowa o PPP (czy to w samej treści, czy też w specjalnie wydzielonym załączniku) powinna zawierać wytyczne dotyczące określenia wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej, a także inne postanowienia wyznaczające istotne dla Podmiotu Publicznego wymogi, które spełnić muszą umowy ubezpieczenia zawierane przez Partnera Prywatnego (przykładowo zakaz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających). Umowa o PPP powinna zawierać także opis procedury zatwierdzania przez Podmiot Publiczny zawieranych przez Partnera Prywatnego umów ubezpieczenia.

Klauzule dotyczące ubezpieczeń powinny być konsultowane z brokerem ubezpieczeniowym i zatwierdzane przy jego udziale.

DOBRE PRAKTYKI



W praktyce rynkowej zarówno postanowienia dotyczące ubezpieczeń, jak i sama treść konkretnych polis jest często przedmiotem negocjacji i dyskusji. Zdarza się, że oczekiwaniem stron jest, aby to doradca techniczny lub doradca prawny weryfikowali przedstawiane polisy. Jest to podejście nieprawidłowe, gdyż nie mieści się to w zakresie świadczonego przez te podmioty doradztwa. W związku z tym dobrą praktyką jest zatrudnienie przez wszystkie strony swoich brokerów ubezpieczeniowych, którzy będą w stanie w sposób należyty odnieść się do przedstawianych polis i ich zgodności ze standardami rynkowymi oraz indywidualnymi wymogami istotnymi z punktu widzenia danego projektu. Podmiot Publiczny powinien wymagać, aby osoby wyznaczone przez brokera, którzy wspierają go w Projekcie PPP pozostali niezależni i wolni od konfliktu interesów (tj. nie podejmowali działań doradcy ubezpieczeniowego po stronie Partnera Prywatnego, również po zawarciu Umowy o PPP).

Broker opiera swoje rekomendacje na podstawie informacji co do potrzeb i zakresu ubezpieczenia uzyskanych od Podmiotu Publicznego. W praktyce przed sformułowaniem swoich rekomendacji broker przedstawia Podmiotowi Publicznemu listę pytań dostosowanych do przedmiotu ubezpieczenia.

PRZYKŁAD



Przykładowa lista pytań od brokera ubezpieczeniowego wraz z komentarzem:

- Jaka jest szacowana wartość Prac Projektowych, Robót Budowlanych oraz potencjalna skala szkód, które może spowodować Partner Prywatny w Okresie Utrzymania (chodzi o szkody poniesione przez Podmiot Publiczny oraz osoby trzecie)?
- Czy Budowa będzie realizowana w sąsiedztwie innych obiektów, w przypadku których może dojść do istotnych szkód poniesionych przez osoby trzecie (np. w wyniku tego, że dźwиг budowlany spadnie na sąsiadujący z Terenem Budowy obiekt budowlany)?
- Jeśli Projekt PPP jest realizowany w ramach istniejącego obiektu budowlanego (np. podlega przebudowie), jaka jest wartość majątku, który może ulec szkodzie w ramach realizacji Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego?

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli na określenie adekwatnego limitu odpowiedzialności w ramach polisy od odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji Robót Budowlanych oraz w Okresie Utrzymania.

- W przypadku, gdy mamy do czynienia z kilkoma obiektami ubezpieczonymi w ramach jednej Umowy o PPP, czy dopuszczamy, żeby polisa odejmowała jeden zbiorczy limit odpowiedzialności dla całości Przedsięwzięcia, czy też będziemy wymagali oddzielnego zabezpieczenia dla poszczególnych obiektów?

W pierwszym przypadku oferta ubezpieczeniowa może okazać się istotnie tańsza, niemniej jednak wiąże się to z większym ryzykiem związanym z tym, że istotna szkoda na jednym z obiektów wyczerpie limit, którym objęte są pozostałe budynki.

- Czy zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien obejmować utracone zyski związane z działalnością prowadzoną przez Podmiot Publiczny?

W przypadku niektórych typów projektów Podmiot Publiczny może prowadzić określoną działalność gospodarczą. Wówczas materializacja danego ryzyka, które chcemy ubezpieczyć, może wiązać się nie tylko ze szkodą w majątku, ale również w utraconych zyskach związanych z koniecznością ograniczenia tej działalności (np. w wyniku błędów w utrzymaniu technicznym przez Partnera Prywatnego doszło do zamknięcia pływalni na kilka tygodni, co spowodowało istotne straty w przychodach po stronie Podmiotu Publicznego).

9. Zakończenie Umowy o PPP

9.1 Wypowiedzenie Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom IV: Część II Punkt 5.1 – Decyzje Podmiotu Publicznego w związku z Zakończeniem Umowy o PPP

Umowa o PPP może zakończyć się przed jej wykonaniem z różnych przyczyn, określonych zarówno w przepisach powszechnie obowiązujących, jak i wskazanych w Umowie (np. na skutek wypowiedzenia przez jedną ze stron). Z reguły przedterminowo Umowę o PPP kończą następujące zdarzenia:

- 1) zgodne oświadczenia stron o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem;
- 2) jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron o wypowiedzeniu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy;
- 3) jednostronne oświadczenie woli Podmiotu Publicznego o odstąpieniu od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

UWAGA



W Umowach o PPP w Polsce zdarza się podział przesłanek oraz sposobu zakończenia Umowy o PPP w zależności od etapu, w jakim projekt się znajduje. I tak na etapie inwestycyjnym Umowy o PPP regulują przesłanki oraz sposób odstąpienia od Umowy o PPP (właściwe dla dzieła oraz Robót Budowlanych), natomiast na etapie operacyjnym przesłanki oraz sposób wypowiedzenia Umowy o PPP (właściwe dla umów zlecenia, czy szerzej o świadczenie usług).

Z uwagi jednak na to, że Umowy o PPP mają charakter kompleksowy, a wykonanie Prac Projektowych oraz Robót ma służyć należytemu wykonywaniu Utrzymania i zapewnieniu Dostępności, rozdzielanie trybów zakończenia Umowy o PPP w zależności od etapu nie wydaje się uzasadnione. Większość ostatnio zawieranych Umów o PPP w Polsce przewiduje przesłanki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron w okresie całej Umowy o PPP bez przypisywania poszczególnym etapom odrębnym trybów zakończenia Umowy o PPP.

UWAGA



Poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie o PPP może ona zostać rozwiązana jednostronnie przez Podmiot Publiczny na podstawie samej Ustawy PZP, nawet jeśli taka przesłanka nie została uwzględniona w Umowie o PPP. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Podmiot Publiczny może mianowicie odstąpić od Umowy o PPP w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy o PPP nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

jej zawarcia, lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W praktyce Projektów PPP w Polsce Podmioty Publiczne nigdy nie skorzystały z tej przesłanki zakończenia Umowy. Wynika to między innymi z faktu, że sytuacja, w której w interesie publicznym byłoby zakończenie przedterminowe Projektu PPP jest niezwykle rzadka. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność zmiany przeznaczenia Infrastruktury Publicznej z uwagi na bezpieczeństwo Państwa. Skutki takiego zakończenia są dla Podmiotu Publicznego bardzo dotkliwe (konieczność rozliczenia za wykonane Prace Projektowe i Roboty).

UWAGA



Interesu publicznego nie należy utożsamiać z interesem ekonomicznym. Motywacją Podmiotu Publicznego do przejęcia Projektu nie powinna być okoliczność, że poziom popytu jest wyższy niż zakładano w ramach analiz.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora transportu (autostrady) opartym o pobór Opłat od Użytkowników (ryzyko popytu po stronie Partnera Prywatnego) faktyczny popyt przewyższyło istotnie to prognozowane. Podmiot Publiczny (z jurysdykcji spoza UE) skorzystał ze swobodnego prawa do odstąpienia od Umowy za zapłatą odstępnego. Projekt ten był jedynym rentownym projektem w portfolio Partnera Prywatnego i jego przejęcie przez Podmiot Publiczny uniemożliwiło subsydiowanie skrócone pozostałych projektów realizowanych przez Partnera Prywatnego. W rezultacie Partner Prywatny zmuszony był do przedterminowego zakończenia innych Projektów PPP.

Prawo odstąpienia od Umowy przysługujące Podmiotowi Publicznemu przewidziane zostało także w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Prawo to przysługuje niezależnie od postanowień Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (i) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454-455 Ustawy PZP (przy czym w tym przypadku odstąpienie dotyczy tylko samej zmiany, a nie pierwotnej Umowy o PPP); (ii) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy PZP, (iii) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Podmiot Publiczny udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami Umów o PPP takie odstąpienie od Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny wiąże się z koniecznością rozliczenia z Partnerem Prywatnym analogicznym do przypadku wypowiedzenia Umowy o PPP z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego.

W Projektach PPP istotna jest ich trwałość i stabilność. Dlatego wszelkie działania skutkujące przedterminowym rozwiązaniem Umowy o PPP, jak wypowiedzenie czy odstąpienie od umowy,

z reguły poprzedzane są czynnościami mającymi na celu usunięcie przyczyn ewentualnego zakończenia Umowy o PPP.

Tym samym w Umowach o PPP uwzględnia się szereg postanowień zabezpieczających nieprzerwane świadczenie usług publicznych, takich jak na przykład mechanizmy naprawcze dodatkowo regulowane często w Umowie Bezpośredniej, czy mechanizmy umożliwiające zaniechanie określonych działań, które stanowiłyby przesłankę jednostronnego rozwiązania Umowy.

Przede wszystkim kluczowe jest gruntowne przemyślenie przesłanek przedterminowego rozwiązania Umowy o PPP, tak aby ograniczyć w maksymalnym stopniu ryzyko przedterminowego zakończenia Umowy o PPP z przyczyn błahych i dających się naprawić w ramach mechanizmów naprawczych.

DOBRE PRAKTYKI



Z uwagi na dotkliwe skutki wypowiedzenia Umowy o PPP oraz podejście oparte na ochronie stabilności Projektu PPP, w Umowach o PPP powinno się raczej unikać katalogu otwartego przesłanek wypowiedzenia, w tym klauzul generalnych (np. rażące naruszenie Umowy o PPP).

Dobrą praktyką jest stosowanie w Umowach PPP zamkniętej listy enumeratywnie wymienionych przesłanek wypowiedzenia przy jednoczesnym zastosowaniu okresów naprawczych, w czasie których strona naruszająca Umowę o PPP może usunąć zaistniałe naruszenia i doprowadzić do stanu zgodnego z Umową.

Umowa o PPP w zakresie przesłanek wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego powinna uwzględniać konkretne przykłady mierzalnych i istotnych naruszeń z jego strony.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Podmiot Publiczny ma prawo wypowiedzieć Umowę w następujących okolicznościach:

- 1) Partner Prywatny jest w zwłoce w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dłużej niż [...] dni;
- 2) Partner Prywatny jest w zwłoce o dłużej niż dziewięćdziesiąt [...] dni z zakończeniem Robót;
- 3) Partner Prywatny jest w zwłoce w rozpoczęciu Utrzymania dłużej niż [...] dni;
- 4) Naliczenia względem Partnera Prywatnego więcej niż [...] Punktów Karnych, przy czym dla celów niniejszego postanowienia, każdy Punkt Karny wygasa po upływie 12 miesięcy, liczonych od dnia jego naliczenia. Jeżeli w okresie wypowiedzenia liczba Punktów Karnych będzie z uwagi na ich wygaśnięcie w trakcie okresu wypowiedzenia, mniejsza niż wskazana powyżej, jako przesłanka wypowiedzenia, Podmiot Publiczny cofnie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy;
- 5) Nałożenia na Partnera Prywatnego Kar Umownych o łącznej wartości przekraczającej [...] % Nakładów Inwestycyjnych.

Okresy naprawcze poprzedzające wypowiedzenie Umowy o PPP z reguły są przedmiotem analizy i badania przez doradcę technicznego Instytucji Finansujących w celu oceny czy okres ten jest

wystarczający. Negatywna ocena prowadzić może do konieczności wydłużenia tego okresu w ramach zmiany Umowy o PPP.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Przed skorzystaniem przez Stronę z prawa do wypowiedzenia Umowy, z powodu okoliczności, o których mowa odpowiednio w Punktach [wypowiedzenie z winy Partnera Prywatnego], Strona zamierzająca wypowiedzieć Umowę udzieli drugiej Stronie przez pisemne zawiadomienie dodatkowego terminu w wymiarze niezbędnym do niezwłocznego usunięcia naruszeń i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową, nie krótszym niż [...] dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Po bezskutecznym upływie tego okresu Strona zamierzająca wypowiedzieć Umowę będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

W okresie wypowiedzenia Umowy Strony powinny wykonywać swoje zobowiązania określone Umową, a ponadto powinny przystąpić do procedury zakończenia Umowy w zakresie przekazania wykonanych Robót Budowlanych (Okres Projektowania i Okres Budowy) lub Infrastruktury Publicznej (Okres Utrzymania), a także ustalenia kwoty rozliczenia i formalnego zakończenia Umowy o PPP.

9.2 Rozliczenie stron na wypadek wcześniejszego zakończenia Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

Tom IV: Część II Punkt 5.5 – Zakończenie Umowy o PPP przed terminem i rozliczenia finansowe

W Umowie o PPP niezwykle ważne jest uregulowanie w sposób szczegółowy kwestii rozliczeń pomiędzy stronami na wypadek jej wcześniejszego zakończenia.

W odmiennym przypadku wartość rozliczenia poddana byłaby rozstrzygnięciu w trybie rozwiązywania sporów, a brak odpowiednich regulacji w Umowie o PPP oznaczałby brak jej Bankowości.

UWAGA



Sposób rozliczenia Projektu PPP na wypadek Zakończenia Umowy może mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia Bankowości Projektu PPP, a tym samym uzyskania przez Partnera Prywatnego niezbędnego Finansowania. Regulacje Umowy o PPP dotyczące rozliczenia na wypadek przedterminowego rozwiązania Umowy o PPP są jednymi z najbardziej kluczowych dla Instytucji Finansujących oceniających projekt PPP pod kątem jego Bankowości. Dlatego też, nawet w przypadku rozwiązania Umowy o PPP z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, Umowa o PPP powinna przewidywać płatność dla Partnera Prywatnego odpowiadającą zaangażowanemu Finansowaniu z pomniejszeniem

nałych kar umownych. Ponadto, zasadą jest, iż przedterminowe rozwiązanie Umowy o PPP nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia Podmiotu Publicznego.

Najbardziej powszechnym w Umowach o PPP w Polsce modelem ustalania wartości płatności należnej Partnerowi Prywatnemu na wypadek rozwiązania Umowy o PPP jest model oparty o wartość wykonanych przez Partnera Prywatnego Prac Projektowych oraz Robót. Wówczas rozliczenie bazowe uwzględnia wartość dotychczas wykonanych i udokumentowanych prac, czyli to co w efekcie procedury zwrotu zostanie przekazane Podmiotowi Publicznemu. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego często uwzględnia się rozliczenie oparte o wartość zobowiązań wobec Instytucji Finansujących.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Wysokość Bazowej Kwoty Rozliczenia będzie równa wartości poniesionych na przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub realizację Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego Nakładów Inwestycyjnych wykonanych zgodnie z Umową i Dokumentacją Projektową, których poniesienie do Daty Rozwiązania Umowy na przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub realizację Robót Budowlanych będzie znajdowało potwierdzenie w wykonanych pracach i które Partner Prywatny będzie w stanie wykazać fakturami lub rachunkami.

Podmioty Publiczne w Umowach o PPP chcą zabezpieczyć się przed skutkami uzgadniania harmonogramu płatności pomiędzy Partnerem Prywatnym a Generalnym Wykonawcą w sposób nieodpowiadający postępowi Robót. W tym celu na okoliczność rozliczenia bazowego ustalane są górne limity płatności za określony zakres Robót, np.:

- Prace Projektowe – 4%;
- etap przygotowawczy – 4%;
- Roboty ulegające zakryciu – 50%;
- pozwolenie na użytkowanie – 42%.

Często dyskutowanym zagadnieniem jest również kwestia rozliczenia za materiały budowlane zamówione przez Partnera Prywatnego, a niewykorzystane w ramach Robót Budowlanych. Partnerzy Prywatni oczekują zwrotu poniesionego kosztu, tym bardziej że nie są w stanie wykorzystać zamówionych materiałów w innych projektach. Podmioty Publiczne z kolei często nie są zainteresowane ponoszeniem ryzyka związanego z jakością i zabezpieczeniem zamówionych materiałów. Decyzja co do postanowień w tym zakresie powinna zależeć od konkretnego przypadku/Projektu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Partner Prywatny jeszcze na etapie projektowania zakontraktował dostawę stali z uwagi na dynamiczny wzrost cen stali w tamtym okresie, przy jednoczesnym braku dostępności tego materiału. Na etapie projektowania doszło do rozwiązania Umowy o PPP z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego. Umowa nie przewidywała rozliczenia zamówionych materiałów. W przypadku tego konkretnego projektu,

z uwagi na nagły wzrost cen stali Partner Prywatny był w stanie zagospodarować zamówiony materiał i nie poniósł szkody.

UWAGA

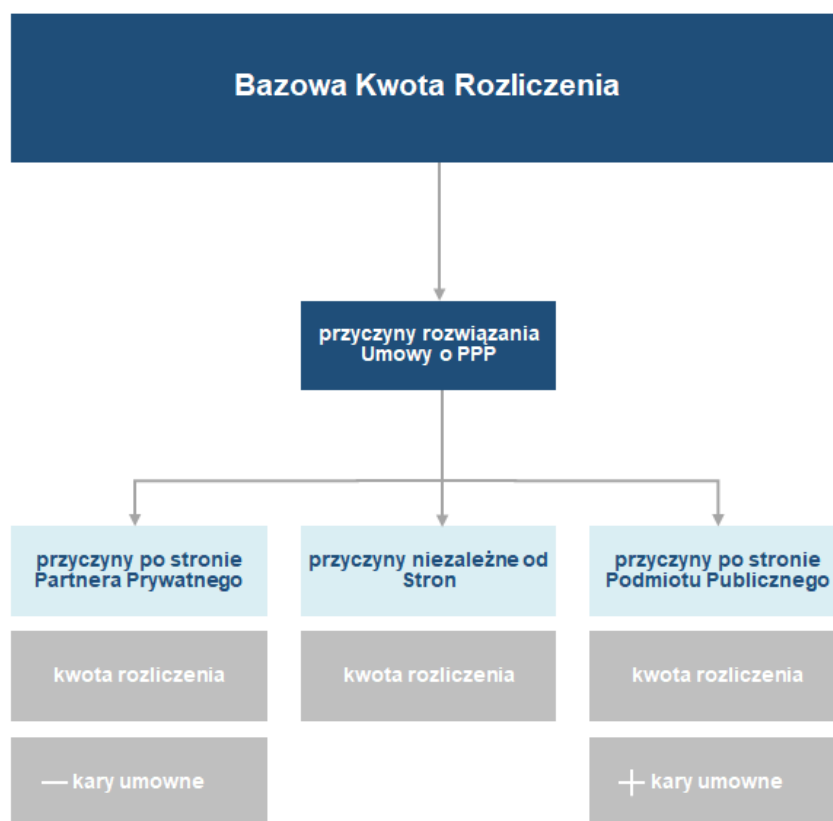
Podejście oparte o wartość zobowiązań wobec podmiotów finansujących projekt (ang. *financing-based compensation*) najczęściej jest stosowane w Dużych Projektach, podczas gdy podejście oparte o wartość wykonanych prac w Małych Projektach.

W podejściu opartym o zwrot finansowań, w przypadku rozwiązania Umowy z winy Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny z reguły uzyskuje zwrot wszystkich kosztów, jakie zmuszony będzie ponieść w zaistniałej sytuacji, jak również określoną część utraconych przychodów (często w postaci kar umownych). Dlatego zwracana jest równowartość wykorzystanego finansowania senioralnego (kredyty bankowe), podporządkowanego (pożyczki od wspólników/akcjonariuszy Spółki Projektowej) oraz kapitału własnego (kapitał, IRR). Dodatkowo zwracane są także koszty podmiotów trzecich (ang. *breakage costs*), np. związane z koniecznością wcześniejszej spłaty zadłużenia, rozwiązania umów z Podwykonawcami czy demobilizacją personelu.

Wartość kwoty rozliczenia powinna uwzględniać przyczyny rozwiązania Umowy o PPP:

- 1) rozwiązanie Umowy o PPP z przyczyn niezależnych od stron (np. siła wyższa, porozumienie stron Umowy) – wówczas kwota bazowa rozliczenia pozostanie bez zmian;
- 2) rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego – wówczas kwota bazowa rozliczenia zostanie pomniejszona o karę umowną należną Podmiotowi Publicznemu od Partnera Prywatnego;
- 3) rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego – wówczas kwota bazowa rozliczenia zostanie powiększona o karę umowną należną Partnerowi Prywatnemu od Podmiotu Publicznego.

Schemat 2. Kwota Rozliczenia



ŹRÓDŁA INFORMACJI



International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Guidance on PPP Contractual Provisions, 2017 Edition, str. 65

UWAGA



Wcześniejsze Zakończenie Umowy w przypadku, gdy mamy do czynienia z Projektem Hybrydowym, może mieć istotne konsekwencje dla podmiotu, który jest beneficjentem, jak też dla całego Projektu PPP.

Jeżeli zakończenie Umowy następuje przed Okresem Utrzymania Infrastruktury Publicznej, a Partner Prywatny udokumentował poniesienie określonych wydatków w Okresie Budowy, środki finansowe z funduszy UE mogą mu zostać wypłacone z rachunku powierniczego.

9.3 Zwrot Infrastruktury Publicznej

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom IV: Część II Punkt 5.2 – Przygotowanie Podmiotu Publicznego do przejęcia Infrastruktury Publicznej

Tom IV: Część II Punkt 5.3 – Przekazanie uprawnień, dokumentacji i wiedzy

Tom IV: Część II Punkt 5.4 – Zwrot Infrastruktury Publicznej – ocena stanu technicznego

Tom IV: Część II Punkt 5.6 – Zakończenie Umowy o PPP i zwrot Infrastruktury Publicznej

Umowa o PPP reguluje kwestię oceny stanu Infrastruktury Publicznej na koniec Okresu Obowiązywania Umowy. Najczęściej w Umowach o PPP określane jest to "zwrotem Infrastruktury Publicznej", jakkolwiek w praktyce często nie dochodzi do przeniesienia posiadania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Umowa o PPP powinna określić procedurę zwrotu Infrastruktury Publicznej oraz wymagania jakie powinna spełniać w momencie jej zwrotu po zakończeniu Umowy o PPP. Zasadniczo należy przyjąć, że stan techniczny Infrastruktury Publicznej powinien umożliwiać dalsze bezpieczne jej użytkowanie.

Umowa o PPP powinna określać wymagania, jakie ma spełniać Infrastruktura Publiczna w momencie jej zwrotu w przypadku wcześniejszego zakończenia Umowy. Należy przyjąć, że stan techniczny Infrastruktury Publicznej powinien wynikać wyłącznie z jej zużycia przy prawidłowo prowadzonym Utrzymaniu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP w sektorze drogowym Umowa o PPP przewidywała bardzo ograniczone uregulowania dotyczące stanu Infrastruktury Publicznej po zakończeniu Umowy o PPP. W rezultacie niemożliwe było określenie ewentualnych roszczeń Podmiotu Publicznego na moment zwrotu pomimo przeprowadzonej inwentaryzacji i zidentyfikowaniu jakości Infrastruktury gorszej niż mogło to wynikać z normalnego jej użytkowania. W rezultacie uzgodnienia zawarte pomiędzy stronami miały charakter zmiany Umowy o PPP i wymagały zgodnej woli obu stron Umowy o PPP.

UWAGA



Podmiot Publiczny nie powinien oczekiwać, że Infrastruktura Publiczna w momencie zwrotu będzie w stanie technicznym nieuwzględniającym zwykłego zużycia. Wymóg ten skutkowałby bowiem koniecznością przeprowadzenia jej generalnego remontu przed zwrotem. Koszty takiego remontu są trudne do oszacowania przez Partnera Prywatnego na etapie składania Oferty. Podejście to wymagałoby szczegółowego uregulowania w Umowie o PPP kwestii

związanych z rozliczeniem remontu (np. poprzez fundusz remontowy). W związku z tym Podmiot Publiczny poniosłby dodatkowe koszty remontu nieuwzględnione w Ofercie.

Umowa o PPP powinna określać procedurę dla oceny stanu technicznego Infrastruktury Publicznej, w tym określenie:

- 1) kiedy zostanie przeprowadzona kontrola stanu technicznego (np. 6 miesięcy przed zakończeniem umowy o PPP);
- 2) kto dokona oceny stanu technicznego (np. niezależny audytor zatrudniony przez Podmiot Publiczny);
- 3) co będzie stanowiło punkt odniesienia dla ustalenia wymagań jakościowych (PFU, normy, przepisy prawa budowlanego, czy powinno zostać uwzględnione naturalne zużycie obiektu wynikające z prawidłowej eksploatacji);
- 4) jak powinien wyglądać raport z kontroli i kiedy powinien zostać przekazany Partnerowi Prywatnemu;
- 5) w jaki sposób i w jakim terminie Partner Prywatny ma prawo odnieść się do wyników kontroli.

Umowa o PPP powinna również regulować przypadek, gdy rzeczywisty stan techniczny Infrastruktury Publicznej nie będzie spełniał wymagań określonych w Umowie o PPP. W takim przypadku Partner Prywatny zobowiązany powinien być do doprowadzenia Infrastruktury Publicznej do wymaganego stanu pod rygorem zapłaty kar umownych oraz odszkodowania przewyższającego kary umowne.

UWAGA



Elementem istotnym przy zwrocie Infrastruktury Publicznej jest przekazanie *know-how* w zakresie jej Utrzymania oraz praw własności przemysłowej, w tym licencji.

10. Prawa własności intelektualnej

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom IV: Część II Punkt 5.3 – Przekazanie uprawnień, dokumentacji i wiedzy

10.1 Prawa autorskie, licencje

W Umowie o PPP należy uregulować kwestię praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach Projektu i ewentualnie kwestię udzielania licencji zarówno przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu, jeżeli wymaga tego specyfika projektu, jak też przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu.

Należy podkreślić, że przeniesienie praw autorskich zakłada wyzbycie się praw do nich przez podmiot będący autorem utworów, zaś licencja umożliwia autorowi dalszą ich eksploatację. Przy opracowywaniu postanowień Umowy o PPP dotyczących własności intelektualnej należy w pierwszej kolejności ustalić, jakie utwory powstaną w wykonaniu Umowy o PPP. Pozwoli to na określenie właściwych pól eksploatacji, które powinny być objęte przeniesieniem praw lub licencją (ustawa o prawie autorskim przewiduje inne pola eksploatacji w przypadku dokumentacji i inne w przypadku oprogramowania).

Istotnym zagadnieniem jest również ustalenie, jaki zakres praw autorskich do utworów przysługuje Partnerowi Prywatnemu oraz jaki zakres praw może być udzielony Podmiotowi Publicznemu. Należy mieć na uwadze, że zakres praw przenoszonych lub udzielonych licencji nie może być szerszy niż zakres praw przysługujących Partnerowi Prywatnemu.

Jeżeli okaże się, że przeniesienie praw autorskich na Podmiot Publiczny do danych utworów nie będzie możliwe lub celowe, właściwym rozwiązaniem będzie udzielenie licencji. Przy tym, jeśli dochodzi do udzielenia dalszej licencji, Podmiot Prywatny (jako licencjobiorca) musi upewnić się, że nabył od podmiotu trzeciego uprawnienie do udzielania dalszych licencji w odpowiednim zakresie.

Ponadto, strony powinny uregulować w Umowie kwestię wykonywania praw zależnych oraz praw autorskich osobistych. Przyznanie Podmiotowi Publicznemu prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych na określonych polach eksploatacji umożliwi temu podmiotowi rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów (w tym m.in. ich tłumaczenie, przenoszenie na inne nośniki lub dokonywanie szerszych adaptacji). Uzyskanie upoważnienia do wykonywania praw autorskich osobistych w praktyce umożliwia swobodne dokonywanie modyfikacji utworów.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP postanowienia Umowy o PPP przewidują, że Partner Prywatny przenosi na Podmiot Publiczny autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej, instrukcji Utrzymania oraz innych utworów pozyskanych w wykonaniu Umowy o PPP z momentem ich ustalenia w jakiegokolwiek postaci. Jednocześnie Podmiot Publiczny udziela Partnerowi Prywatnemu licencji do korzystania z utworów i ich opracowań na czas wykonywania Umowy o PPP.

Umowa o PPP zawiera także postanowienie wskazujące, że zamiast przeniesienia autorskich praw majątkowych możliwe jest udzielenie Podmiotowi Publicznemu nieodpłatnej licencji, jeśli będzie to wystarczające do prawidłowego użytkowania danego elementu przedsięwzięcia. Możliwość ta nie dotyczy jednak Dokumentacji Projektowej. Podczas dialogu konkurencyjnego omawiane było także zastosowanie specjalistycznych systemów, m.in. systemu BIM na etapie inwestycyjnym czy rozmaitych systemów kontroli spełnienia wskaźników efektywności w ramach etapu operacyjnego.

Szczególnych uregulowań wymagać będą przedsięwzięcia, w których Partner Prywatny zapewniać będzie konkretne oprogramowanie w Okresie Utrzymania – np. w zakresie systemów zgłaszania awarii, kontroli dostępu, monitoringu, sterowania klimatyzacją i tym podobnych. Istotne wtedy jest zapewnienie, że Podmiot Publiczny, wraz ze zwrotem Infrastruktury Publicznej, pozyska odpowiedni tytuł prawny do korzystania z tego oprogramowania – najczęściej w postaci zapewnienia przez Partnera Prywatnego licencji na korzystanie z niego – w tym od podmiotu trzeciego.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Dla uniknięcia wątpliwości Partner Prywatny oraz Podmiot Publiczny potwierdzają, iż przeniesienie Praw Własności Intelektualnej, o którym mowa w niniejszym Punkcie, nie skutkuje przeniesieniem na Podmiot Publiczny praw do narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how użytych przez Partnera Prywatnego przy realizacji Umowy i nie ogranicza Partnera Prywatnego w żaden sposób w używaniu wyżej wymienionych narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how w jego działalności na rzecz innych podmiotów.

UWAGA



W Umowach o PPP obejmujących świadczenie usług na istniejącej Infrastrukturze Podmiotu Publicznego (np. system poboru opłat od użytkowników dróg) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe udzielenie licencji przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu. Należy mieć na uwadze, że licencje zawarte na czas określony dłuższy niż 5 lat po upływie tego okresu przekształcają się w licencje zawarte na czas nieoznaczony. W takim przypadku Partner Prywatny będzie oczekiwał stosownych zobowiązań Podmiotu Publicznego do udzielenia kolejnej licencji terminowej.

PRZYKŁAD

W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora oświetlenia drogowego przewidywał duży udział systemów IT niezbędnych do zarządzania energią. Ponieważ po Okresie Obowiązywania Umowy system oświetlenia, którego istotną częścią był system zarządzania energią przechodził na Podmiot Publiczny niezwykle istotne było uwzględnienie w Umowie prawidłowo skonstruowanych postanowień dotyczących uprawnień do dalszego korzystania i używania tych systemów przez Podmiot Publiczny lub kolejnego operatora systemu.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Ochrona danych osobowych

W Umowie o PPP należy uwzględnić kwestie związane z ochroną danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonania przedmiotu Umowy PPP strony będą przekazywać sobie dane osobowe, Umowa o PPP powinna zawierać regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodne z RODO oraz przepisami krajowymi.

Przed przystąpieniem do projektowania Umowy o PPP należy rozstrzygnąć, w jakim charakterze Podmiot Publiczny będzie występował w relacji z Partnerem Prywatnym w odniesieniu do przetwarzania (operacji na) danych osobowych.

Rozstrzygnięcie tej kwestii będzie decydowało o tym, jakie obowiązki będą ciążyły na Podmiocie Publicznym, a jakie na Partnerze Prywatnym oraz jakie postanowienia będzie zawierała Umowa o PPP. Podmiot Publiczny może w tej relacji pełnić trzy role:

- 1) administratora;
- 2) współadministratora;
- 3) podmiotu przetwarzającego.

Należy pamiętać, że przyjęcie określonej roli w stosunku do danych osobowych będzie skutkowało nie tylko powstaniem określonych obowiązków we wzajemnych relacjach pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, ale będzie także skutkowało nałożeniem odpowiednich obowiązków publicznoprawnych określonych w RODO.

Administratorem jest ten podmiot, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, jest to ten podmiot, który określa "jak" i "dlaczego" dane osobowe będą przetwarzane.

Współadministratorami są z kolei te podmioty, które wspólnie decydują o sposobach i celach przetwarzania. Zakres zastosowania tej koncepcji wzbudza pewne wątpliwości w określonych scenariuszach faktycznych, jednakże zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związek pomiędzy współadministratorami nie musi być bardzo ścisły tj. aby zostać uznanym za współadministratora wystarczy, że dany podmiot ma jedynie określony wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez inny podmiot (współadministratora). Co więcej wystarczy, że wpływ ten będzie przejawiał się jedynie na niektórych etapach przetwarzania.

Podmiotem przetwarzającym będzie natomiast ten podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie (w imieniu) administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub odpowiednich klauzul w tym zakresie w umowie głównej, zgodnie z art. 28 RODO. Zakres swobody decyzyjnej podmiotu przetwarzającego jest znacznie ograniczony i, co do zasady, może sprowadzać się jedynie do wyboru środków przetwarzania (np. monitoring będzie prowadzony przy użyciu kamer X oraz systemu monitoringowego Y), o ile takie uprawnienie zostało na podmiot przetwarzający sędowane przez administratora. Nawet jednak w takiej sytuacji administrator powinien sprawować kontrolę nad wykorzystywanymi przez podmiot przetwarzający środkami i to do niego powinna należeć ostateczna decyzja co do ich wykorzystania.

DOBRE PRAKTYKI



Należy pamiętać, że pojęcie administratora jest pojęciem funkcjonalnym, którego funkcją jest przypisanie odpowiedzialności temu podmiotowi, który faktycznie decyduje o tym, co będzie się działo z danymi osobowymi, tak aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę osobom których dane będą przetwarzane.

O tym który podmiot będzie administratorem (współadministratorem), a który podmiotem przetwarzającym mogą decydować przepisy prawa powszechnie obowiązującego wskazujące na dany podmiot jako administratora danych. Gdy takich przepisów brak, konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu faktycznego w celu ustalenia, gdzie leży faktyczne, a nie jedynie formalne, władztwo nad danymi osobowymi.

Aby rozstrzygnąć jaką rolę faktycznie pełni dany podmiot, pomocne będzie ustalenie, który podmiot decyduje o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, tj. o:

- celu przetwarzania;
- kategoriach danych osobowych, które będą przetwarzane;
- kategoriach operacji na danych koniecznych do realizacji celu (np. zbieranie, łączenie, przesyłanie, modyfikowanie itd.);
- tym, które podmioty będą miały dostęp do danych osobowych;
- czasie przetwarzania (np. przechowywania) danych osobowych;
- technicznych środkach przetwarzania (np. jakie oprogramowanie, komputer, kamera).

Przy ustalaniu faktycznej roli danego podmiotu należy wziąć pod uwagę całość okoliczności. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na to, kto komu wydaje instrukcje w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz jaki jest stopień ich szczegółowości. Im bardziej sprecyzowane polecenia, a tym samym mniejsza swoboda podmiotu, który otrzymuje polecenie, tym bardziej jest prawdopodobne, że podmiot wydający polecenie jest administratorem, a podmiot realizujący polecenie jest podmiotem przetwarzającym.

Należy pamiętać, że postanowienia Umowy łączącej Podmiot Publiczny z Partnerem Prywatnym nie są przesądzające dla ustalenia faktycznej roli tych podmiotów w przetwarzaniu danych osobowych. Postanowienia te mogą pełnić jednak rolę pomocniczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą tu wystąpić cztery podstawowe sytuacje (w świetle RODO możliwe jest również występowanie w kilku rolach jednocześnie, ale taki model występuje rzadziej):

- 1) Podmiot Publiczny jest administratorem danych, natomiast Partner Prywatny jest podmiotem przetwarzającym;
- 2) sytuacja odwrotna, tj. Partner Prywatny jest administratorem, a Podmiot Publiczny jest podmiotem przetwarzającym;
- 3) Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny są współadministratorami danych osobowych;

- 4) Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny są odrębnymi administratorami w stosunku do tych samych danych osobowych (wykorzystują je, każdy w swoim własnym celu). Pomiędzy tymi podmiotami dochodzi do udostępnienia (a nie powierzenia) danych osobowych.

W kontekście Umowy o PPP najbardziej prawdopodobne będzie wystąpienie sytuacji (1) lub (4), chociaż nie można oczywiście z góry wykluczyć wystąpienia sytuacji odmiennych. Umowa o PPP przewiduje wystąpienie tylko tych dwóch sytuacji.

PRZYKŁAD



Przykład powierzenia przetwarzania danych osobowych (sytuacja (1)): Podmiot Publiczny zleca Partnerowi Prywatnemu instalację i obsługę systemu kontroli dostępu do obszaru/pomieszczeń służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i informacji. Podmiot Publiczny określa, po co i jakie dane osobowe będą przetwarzane przez Partnera Prywatnego (np. imię, nazwisko, nr identyfikatora). Wyłącznym uprawnieniem Podmiotu Publicznego powinno także być uprawnienie do decydowania o tym, jak długo dane te będą przechowywane oraz kto będzie miał do nich dostęp.

Przykład udostępnienia danych osobowych (sytuacja (2)): Podmiot Publiczny udostępnia dane osobowe swoich pracowników Partnerowi Prywatnemu w celu wykonania wspólnego zadania.

Jeżeli chodzi o sytuację (1), tj. gdy Podmiot Publiczny powierza przetwarzanie danych osobowych Partnerowi Prywatnemu, RODO wprost wymaga zawarcia klauzuli powierzenia przetwarzania określającej co najmniej elementy wskazane w przepisie art. 28 RODO.

Sytuacja (2) tj. gdy Podmiot Publiczny udostępnia dane osobowe Partnerowi Prywatnemu nie wymaga regulacji umownej (obowiązek taki nie wynika wprost z RODO). Jednakże, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, rekomendowane jest zawarcie pewnych regulacji w tym zakresie, aby ograniczyć swobodę Podmiotu Prywatnego w dysponowaniu otrzymanymi danymi oraz zapewnić ich bezpieczeństwo.

Przed zawarciem Umowy z Podmiotem Prywatnym Podmiot Publiczny powinien zweryfikować, czy Partner Prywatny zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Weryfikacja ta może zostać przeprowadzona np. poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza przez Partnera Prywatnego i ocenę jego odpowiedzi przez Podmiot Publiczny. Weryfikacja taka może zostać pominięta, jeżeli podmiot będzie legitymował się odpowiednim certyfikatem (o którym mowa w RODO).

Należy pamiętać, że o ile weryfikacja ta jest obowiązkowa tylko w przypadku powierzenia przetwarzania (art. 28 RODO) to jednak przeprowadzanie takiej weryfikacji jest rekomendowane także w przypadku udostępnienia danych.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



European Data Protection Board's Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR adopted on 02 September 2020, Handbook on European data protection law 2018 edition

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (C-210/16)

11.2 Poufność

Umowa o PPP powinna regulować zasady zachowania poufności danych uzyskanych w ramach realizacji Umowy, w tym zasady dozwolonego ujawnienia danych. Umowa powinna również wskazywać na informacje, które nie mogą być zastrzeżone jako poufne z uwagi na ich charakter (przykładowo podlegają one ujawnieniu zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej).

11.3 Zawiadomienia

Umowa o PPP powinna zawierać informacje dotyczące sposobu doręczania korespondencji w związku z realizacją postanowień Umowy i momentu, który strony uznają za doręczenie, dane adresowe stron, obowiązek stron informowania o zmianie danych i skutków niedokonania takiej zmiany (uznanie korespondencji za doręczoną w przypadku jej wysłania na ostatni znany adres) itp.

11.4 Język i prawo właściwe

W przypadku Umowy o PPP zawieranej z podmiotem mającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uniknięcia wątpliwości, warto zawrzeć w umowie klauzulę wskazującą na właściwość prawa polskiego.

Jeżeli Umowa o PPP dotyczy Projektu PPP, o którego realizację ubiega się kilkoro zagranicznych wykonawców, Umowa o PPP może być sporządzona w więcej niż jednej wersji językowej. Warto jednak zawrzeć w Umowie o PPP w takim wypadku klauzulę wskazującą na to, która wersja językowa jest wersją rozstrzygającą w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami.

11.5 Forma i egzemplarze

W przypadku Umowy o PPP zawieranej w formie pisemnej warto zawrzeć w niej klauzulę wskazującą na liczbę podpisywanych egzemplarzy.

Jeżeli Umowa o PPP ma zostać podpisana w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, warto również wskazać na taką formę podpisania w końcowych postanowieniach. Ponieważ podpisywanie umowy w tej formie odbywa się zwykle obiegowo, warto także wskazać, że za datę zawarcia Umowy o PPP poczytuje się datę złożenia ostatniego podpisu (przykład odpowiedniego postanowienia zamieszczono poniżej).

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



Niniejsza Umowa została podpisana w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych (QES). Za datę zawarcia niniejszej Umowy poczytuje się datę złożenia ostatniego podpisu.

PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA



- 1) Strony ustalają, że na potrzeby wszelkich zawiadomień dokonywanych na podstawie lub w związku z Umową, wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujące adresy stron:
 - dla Podmiotu Publicznego:
[nazwa]
[adres], [kod pocztowy, miejscowość]
Dw: [osoby kontaktowe]
[adres e-mail];
 - dla Partnera Prywatnego:
[nazwa]
[adres], [kod pocztowy, miejscowość]
Dw: [osoby kontaktowe]
[adres e-mail].
- 2) Strony zobowiązane są powiadamiać się niezwłocznie o wszelkich zmianach danych adresowych i kontaktowych, a w przypadku zaniechania tego obowiązku i do czasu dokonania stosownego powiadomienia, wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, skierowana pod dotychczas znane adresy uważana będzie przez Strony za skutecznie doręczoną.
- 3) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
- 4) Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim i dwóch egzemplarzach w języku angielskim, po jednym egzemplarzu w każdej wersji językowej dla każdej ze Stron.
- 5) Umowa została sporządzona zgodnie z prawem polskim i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
- 6) W przypadku uznania całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień Umowy, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się, że podejmą działania, aby postanowienia Umowy uznane za nieważne zastąpić odpowiednimi ważnymi postanowieniami, które będą możliwie maksymalnie oddawały pierwotną intencję Stron.

12. Załączniki do Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-IV



Tom II: Punkt 6.5 – Opracowanie ostatecznej Dokumentacji Postępowania

Umowa o PPP powinna zawierać listę załączników oraz stanowić, że załączniki stanowią integralną część Umowy. Poniżej znajduje się lista typowych Załączników do Umowy o PPP wraz z opisem Załączników, które nie zostały omówione w powyższych punktach Wytycznych.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych Robót Budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy PZP, Podmiot Publiczny opisuje przedmiot zamówienia za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Szczegółowy zakres i formę PFU określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wzory Raportów

Jeżeli Podmiot Publiczny nałoży na Partnera Prywatnego obowiązki w zakresie raportowania i sprawozdawczości, to Umowa o PPP powinna dokładnie określać jakie elementy mają zawierać raporty, których Podmiot Publiczny wymaga od Partnera Prywatnego. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie przez Podmiot Publiczny wzoru raportu i załączenie go do Umowy o PPP. Zob. również Część II Punkt 1.11 Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP.

Harmonogram

Zob. Część II Punkt 2.5 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót.

Standardy Utrzymania, Zarządzanie i Zasady Dostępności

Zob. Część II Punkt 3.2 Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania.

Wymagania przy zwrocie Infrastruktury Publicznej

Zob. Część II Punkt 9.3 Zwrot Infrastruktury Publicznej.

Ubezpieczenia

Zob. Część II Punkt 8.1 Ubezpieczenia.

Rozliczenia na wypadek Przedterminowego Zakończenia Umowy

Zob. Część II Punkt 9.2 Rozliczenie stron na wypadek wcześniejszego zakończenia Umowy.

Mechanizm Wynagradzania

Zob. Część II Punkt 4.1 Mechanizm Wynagradzania.

Procedura Rozwiązywania Sporów

Zob. Część II Punkt 6 Procedura rozwiązywania sporów.

Zakres Umowy Bezpośredniej

Zob. Część II Punkt 1.10 Umowa Bezpośrednia.